

dad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro Estado Nacional como parte de la Comunidad Internacional.

33. Que en consecuencia los hechos por los cuales se condenó a Arancibia Clavel, ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse, con lo cual no se da una aplicación retroactiva de la convención, sino que ésta ya era la regla por costumbre internacional vigente desde la década del '60, a la cual adhería el Estado argentino.

34. Que comprendido entonces que para la época en que fueron ejecutados los hechos investigados eran considerados crímenes contra la humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos vinculante para el Estado argentino, de ello se deriva como lógica consecuencia la inexorabilidad de su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad, como fuera expresado en el precedente publicado en Fallos: 318: 2148.

35. Que este criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al manifestar "Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos...las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú..." (conf. CIDH, caso "Barrios Altos", sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C Nº 75 —LA LEY, 2001-D, 558—).

36. Que en virtud del precedente mencionado, tomando en cuenta que el Estado argentino ha asumido frente al orden jurídico interamericano no sólo un deber de respeto a los derechos humanos, sino también un deber de garantía: "en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención, cumplida por

un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención" (CIDH, caso "Velázquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988, considerando 172, serie C Nº 4).

A partir de dicho fallo quedó claramente establecido el deber del Estado de estructurar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del poder público, de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención. Desde este punto de vista, la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional (conf. CIDH, caso "Barrios Altos", sentencia del 14 de marzo de 2001, considerando 41, serie C Nº 75; caso "Trujillo Oroza vs. Bolivia" — Reparaciones; sentencia del 27 de febrero de 2002, considerando 106, serie C Nº 92; caso "Benavides Cevallos" — cumplimiento de sentencia, resolución del 9 de septiembre de 2003, considerandos 6 y 7).

37. Que en virtud de las consideraciones realizadas corresponde declarar que el hecho que diera lugar a la condena de Arancibia Clavel por el delito de asociación ilícita, reviste la calidad de crimen contra la humanidad y, por lo tanto, resulta imprescriptible.

38. Que, en tales condiciones, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto por el art. 62 inc. 2 en función del art. 210 del Código Penal corresponde declarar que la acción penal no se ha extinguido respecto de Enrique Lautaro Arancibia Clavel, por cuanto las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno

quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" (leyes 24.584 y 25.778).

Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Vuelvan los autos al tribunal de

origen a fin de que por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. — Enrique S. Petracchi (según su voto). — Augusto C. Belluscio (en disidencia). — Carlos S. Fayt (en disidencia). — Antonio Boggiano (según su voto). — Adolfo R. Vázquez (en disidencia). — Juan C. Maqueda (según su voto). — E. Raúl Zaffaroni. — Elena I. Highton de Nolasco.

Omissis...

7. SIMÓN, JULIO

ACCION PENAL

Amnistía — Cámara de Casación Penal — Casación — Constitución Nacional — Constitucionalidad — Convención Americana sobre Derechos Humanos — Corte Interamericana de Derechos Humanos — Corte Suprema de Justicia de la Nación — Cuestión federal — Culpabilidad — Defensa en juicio — Delitos de lesa humanidad — Derecho internacional público — Derecho penal internacional — Derechos Humanos — Doctrina de la Corte Suprema — Excepción de falta de legitimación — Facultades del Poder Legislativo — Fuero penal — Fuerzas armadas — Fuerzas armadas y de seguridad — Ley de obediencia debida — Ley de punto final.

Hechos:

La Cámara de Apelaciones confirmó el auto de procesamiento con prisión preventiva de un militar por crímenes contra la humanidad. Contra esa resolución la defensa interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar parcialmente al recurso y, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y, asimismo, la constitución de la ley 25.779 que declara la nulidad absoluta e insanable de las leyes mencionadas.

1. La progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos con el rango establecido por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional ya no autoriza al Estado a tomar decisiones - en el caso, la Corte Suprema declaró la invalidez constitucional de las leyes 23.492 y 23.521 de punto final y de obediencia debida (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos de esa naturaleza.

2. Es inadmisibile el recurso extraordinario en cuanto al agravio fundado en la falta de legitimación del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales para ejercer el rol de querellante en el proceso tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 de punto final y de obediencia debida 492 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), respectivamente, pues la decisión que rechaza la excepción de falta de acción y acepta el rol de parte querellante no constituye sentencia definitiva, en tanto no pone término al pleito ni impide su continuación.

3. Si bien en el ámbito de la justicia penal nacional, la Cámara Nacional de Casación Penal es tribunal superior de la causa cuando se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de la Corte Suprema por vía extraordinaria, frente a la imposibilidad jurídica de reeditar la instancia casatoria, pues el imputado agotó y consintió la denegación de esta vía de impugnación, su conducta no puede jugar en contra del ejercicio de su derecho de defensa — a los fines del remedio federal intentado —, ya que en definitiva su proceder se ajustó a las reglas estable-

cidas y aceptadas por la doctrina imperante.

4. Las leyes 23.492 y 23.521 —de punto final y de obediencia debida (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548)— que intentaron dejar atrás los enfrentamientos entre "cíviles y militares", en cuanto se orientan, como toda amnistía, al "olvido" de graves violaciones a los derechos humanos, se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables —arg. art. 75, inc. 22, Constitución Nacional—.
5. La circunstancia de que leyes orientadas hacia el olvido de graves violaciones a los derechos humanos —en el caso, leyes 23.492 y 23.521 de punto final y de obediencia debida (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), respectivamente— puedan ser calificadas como "amnistías" ha perdido toda relevancia en cuanto a su legitimidad, pues, en la medida en que dichas normas obstaculizan el esclarecimiento y la efectiva sanción de actos contrarios a los derechos reconocidos en los tratados internacionales en la materia —art. 75, inc. 22 Constitución Nacional—, impiden el cumplimiento del deber de garantía a que se ha comprometido el Estado argentino, y resultan inadmisibles.
6. La inadmisibilidad de las disposiciones de amnistía y prescripción, así como el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que tiendan a impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos configura un aspecto central de la jurisprudencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos, cuyos alcances —en el caso, con relación a la impugnación constitucional de las leyes 23.492 y 23.521 de obediencia debida y de punto final (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), respectivamente— no pueden ser soslayados.
7. Corresponde declarar de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 —de punto final y de obediencia debida— (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual
8. Corresponde declarar la validez de la ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843), por medio de la cual el Poder Legislativo declara insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521 —de punto final y de obediencia debida— (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), pues su contenido coincide con lo que los jueces deben declarar con relación a las leyes referidas y, en la medida en que las leyes deben ser efectivamente anuladas, declarar la inconstitucionalidad de dicha norma para luego resolver en el caso tal como ella lo establece constituiría un formalismo vacío.
9. La ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843), por medio de la cual el Poder Legislativo declara insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521 —de punto final y de obediencia debida— (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), es el de intentar dar cumplimiento a los tratados constitucionales en materia de derechos humanos por medio de la eliminación de todo aquello que pudiera aparecer como un obstáculo para que la justicia argentina investigue debidamente los hechos alcanzados por dichas leyes y, de este modo, subsanar la infracción al derecho internacional que ellas continúan representando.
10. Cabe declarar la inaplicabilidad de las leyes 23.492 y 23.521 —denominadas respectivamente "de punto final" y "de obediencia debida"— (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) respecto de quien fuera imputado por crímenes de lesa humanidad, pues corresponde aplicar el principio de imprescriptibilidad de los delitos en cuestión derivado tanto del derecho internacional consuetudinario cuanto de la Convención de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (del voto del doctor Boggiano).
11. Las leyes 23.492 y 23.521 —denominadas respectivamente "de punto final" y "de obediencia debida" (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548)— resultan inaplicables respecto de quien fuera imputa-

condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

do por crímenes de lesa humanidad, toda vez que la inaplicabilidad de las normas de derecho interno de prescripción de los delitos de lesa humanidad tiene base en el derecho internacional ante el cual el derecho interno es sólo un hecho (del voto del doctor Boggiano).

12. El desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos impone en la etapa actual del acelerado despertar de la conciencia jurídica de los Estados de investigar los hechos que generaron las violaciones a aquéllos, identificar a sus responsables, sancionarlos y adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación —en el caso, se declaró la inaplicabilidad de las leyes 23.492 y 23.521 denominadas respectivamente "de punto final" y "de obediencia debida"— (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), a fin de evitar la impunidad y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción (del voto del doctor Boggiano).
13. Los delitos contra el derecho internacional, contra la humanidad y el derecho de gentes pueden ser juzgados aún fuera del país en el que se hubiesen cometido de acuerdo a la teoría de la jurisdicción universal —en el caso, se declaró la inaplicabilidad de las leyes 23.492 y 23.521 denominadas respectivamente "de punto final" y "de obediencia debida" (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548)—, toda vez que los mismos violan una norma de "ius cogens" y en modo sistemático lesionan el derecho internacional (del voto del doctor Boggiano).
14. Cabe declarar la inconstitucionalidad de la ley 23.521 (Adla, XLVII-B, 1548), conocida como ley de obediencia debida, en cuanto establece que quienes a la fecha de la comisión del hecho ilícito hubieran revestido la calidad de oficiales, suboficiales o personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o Penitenciarias, no son punibles por los delitos establecidos en el art. 10 de la ley 23.049 (Adla, XLIV-A, 8) por entender que habían obrado en virtud de obediencia debida, toda vez que la presunción exculpatória "iure et de iure" consagrada en la norma impugnada importa la invasión por parte del Poder Legislativo de funciones propias del Po-

der Judicial, en clara violación al art. 116 de la Constitución Nacional (del voto del doctor Maqueda).

15. La ley de punto final —ley 23.492 (Adla, XLVII-A, 192)— debe ser considerada una ley de amnistía encubierta, no sólo porque el fin invocado por el Poder Ejecutivo Nacional para sancionarla fue la "consolidación de la paz social y reconciliación nacional", sino también porque el ámbito de aplicación de la referida norma se limitó a hechos del pasado, quedando vedada su aplicación a casos futuros (del voto del doctor Maqueda).
16. Las leyes 23.492 y 23.521 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), conocidas como leyes de punto final y obediencia debida respectivamente, desconoce todo rol a las víctimas del terrorismo de Estado y a sus familiares de acudir a los tribunales a solicitar el esclarecimiento y sanción penal de los responsables, a pesar de ser éstos afectados directos (del voto del doctor Maqueda).
17. Resulta válida la ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843) que declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, pues sin perjuicio de que el Poder Judicial es el órgano facultado para declarar la eventual inconstitucionalidad de las leyes impugnadas, ello no obsta a que el Poder Legislativo pueda dar cuenta del grado de adecuación constitucional de su accionar, ya que el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional obliga a todos los poderes del Estado en su ámbito de competencias a hacer posible la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales (del voto del doctor Maqueda).
18. El delito de privación ilegítima de la libertad previsto en los arts. 141, 142 y 144 bis del Cód. Penal contiene una descripción lo suficientemente amplia como para incluir aquellos supuestos específicos denominados "desaparición forzada de personas" (del voto del doctor Maqueda).
19. La desaparición forzada de personas no sólo configura un crimen de lesa humanidad para la ley internacional, sino que dicha conducta se encuentra también tipificada en el delito de privación ilegítima de la libertad establecido en los arts. 141, 142 y 144 bis del Cód. Penal, lo cual implica preservar el principio de le-

270

- galidad cuyo fin es que cualquiera que vaya a cometer un acto ilegal esté advertido con anterioridad por la norma que esa conducta constituye delito y que su realización conlleva una pena (del voto del doctor Maqueda).
20. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se vincula con la obligación de los Estados nacionales de adoptar las medidas tendientes a la persecución de este tipo de delitos con el consiguiente deber de no imponer restricciones, de fundamento legislativo, sobre la punición de los responsables de tales hechos (del voto del doctor Maqueda).
21. Los principios que en el ámbito nacional se utilizan para justificar el instituto de la prescripción no resultan aplicables a los delitos de lesa humanidad, pues la imprescriptibilidad de estos delitos aberrantes opera como una cláusula de seguridad tendiente a evitar que los restantes mecanismos adoptados por el derecho internacional se vean burlados mediante el mero transcurso del tiempo (del voto del doctor Maqueda).
22. La ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843) al conferir jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad ha sumado al deber de punición que corresponde a los tribunales, la presencia de una norma positiva de derecho internacional que consagra la imposibilidad de considerar extinguida la acción penal por prescripción respecto de los delitos de lesa humanidad (del voto del doctor Maqueda).
23. El sistema internacional de protección de los derechos humanos impide a los Estados disponer medidas que excluyan la persecución penal tendiente a investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y el eventual castigo de los responsables de dichos crímenes (del voto del doctor Maqueda).
24. La sanción y vigencia de las leyes 23.492 y 23.521 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) en tanto impedían llevar adelante las investigaciones necesarias para identificar a los autores y partícipes de graves delitos perpetrados durante el último gobierno de facto, y aplicarles las sanciones penales correspondientes, resultan claramente violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (del voto del doctor Maqueda).
25. Las leyes 23.492 de "punto final" y 23.521 de "obediencia debida" (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) son inconstitucionales en cuanto violan normas de derecho internacional público y han perdido todo efecto en función de la inexequibilidad dispuesta por la ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843), por lo que debe cancelarse cualquier efecto directo de ellas o de los actos en ellas fundados, que constituya un obstáculo para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina (del voto del doctor Zaffaroni).
26. El Congreso de la Nación no ha excedido el marco de sus atribuciones legislativas al establecer la inexequibilidad de las leyes 23.492 y 23.521 mediante la ley 25.779 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548; LXIII-E, 3843), pues se ha limitado a sancionar una ley cuyos efectos se imponen por mandato internacional, la cual pone en juego la esencia misma de la Constitución Nacional y la dignidad de la Nación Argentina (del voto del doctor Zaffaroni).
27. La sanción de la ley 25.779 en cuanto dispone la inexequibilidad de las leyes 23.492 de "punto final" y 23.521 de "obediencia debida" (Adla, LXIII-E, 3843; XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), elimina toda duda respecto de la cancelación de los efectos de las mismas y permite la unidad de criterio en todo el territorio y en todas las competencias, resolviendo dificultades que podría generar las diferencias de opiniones en el sistema de control difuso de constitucionalidad que nos rige (del voto del doctor Zaffaroni).
28. Los objetivos del Preámbulo de la Constitución Nacional serían negados en la medida en que se interpretase cualquiera de sus normas obligando a los jueces a admitir o legitimar una pretendida incapacidad de la Nación Argentina para el ejercicio de su soberanía —en el caso, respecto de la validez constitucional de las leyes 23.492 de "punto final" y 23.521 de "obediencia debida" (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548)—, con la consecuencia de que cualquier otro país pueda ejercerla ante su omisión, en razón de violar el mandato internacional de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio por sus habitantes y ciudadanos (del voto del doctor Zaffaroni).
29. El Congreso Nacional no se encontraba habilitado para dictar las leyes 23.521 y 23.492 (Adla, XLVII-B, 1548; XLVII-A, 192); y al hacerlo ha vulnerado no sólo principios constitucionales sino también los tratados internacionales de derechos humanos, generando un sistema de impunidad con relación a delitos considerados como crímenes de lesa humanidad, del que se deriva la posibilidad cierta y concreta de generar responsabilidad internacional para el Estado argentino (del voto de la doctora Highton de Nolasco).
30. Las leyes 23.521 y 23.492 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) son violatorias del principio de igualdad ante la ley, ya que aparejan un tratamiento procesal de excepción para los sujetos amparados y, de manera simultánea, privan a las víctimas de los hechos, o a sus deudos, de la posibilidad de acudir a la justicia para reclamar el enjuiciamiento y punición de los actos ilícitos que los dañan (del voto de la doctora Highton de Nolasco).
31. Debe consagrarse la validez constitucional de la ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843) que declaró "insanablemente nulas" las leyes 23.521 -ley de obediencia debida- y 23.492 -ley de punto final- (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), pues los legisladores han tenido en mira subsanar la infracción al derecho internacional de los derechos humanos que éstas contenían y cumplir de manera debida las obligaciones asumidas a través de los tratados internacionales de derechos humanos, eliminando todo aquello que pudiera constituir un impedimento normativo para avanzar en la investigación y punición de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina, extremo que no había sido cubierto por la ley 24.592 cuyo art. 2 derogaba esas normas (del voto de la doctora Highton de Nolasco).
32. Las leyes 23.492 y 23.591 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) resultan violatorias de derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que importa que no sólo desconocen las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito regional americano sino las de carácter mundial, por lo cual se impone restarles todo valor en cuanto a cualquier obstáculo que de éstas pudiera surgir para la investigación y alcance regular de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina. (del voto del doctor Lorenzetti).
33. El Congreso Nacional, mediante la sanción de la ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843) que declaró "insanablemente nulas" las leyes 23.492 y 23.591 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) permite la unidad de criterio en todo el territorio y en todas las competencias, resolviendo las dificultades que podría generar la diferencia de criterios en el sistema de control difuso de constitucionalidad que nos rige, y brinda al Poder Judicial la seguridad de que un acto de tanta trascendencia resulte del funcionamiento armónico de los tres poderes del Estado y no dependa únicamente de la decisión judicial (del voto del doctor Lorenzetti).
34. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.591 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) no constituye violación del principio "nulla poena sine lege", en la medida en que los crímenes de lesa humanidad siempre estuvieron en el ordenamiento y fueron reconocibles para una persona que obrara honestamente conforme a los principios del estado de derecho (del voto del doctor Lorenzetti).
35. En los procesos penales por delitos de lesa humanidad, los imputados no pueden oponerse a la investigación de la verdad y al juzgamiento de los responsables a través de excepciones perentorias, salvo cuando el juicio sea de imposible realización o se haya dictado una sentencia firme, pues los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos no admiten que la obligación de los Estados de enjuiciar a los imputados cese por el transcurso del tiempo, amnistía, o cualquier otro tipo de medidas que disueltan la posibilidad de reproche (del voto de la doctora Argibay).
36. La modificación de las normas referidas a la prescripción de la acción penal no viola el principio de culpabilidad —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad
- 271

de las leyes 23.492 y 23.521 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548)—, en tanto no implica cambio alguno en el marco de ilicitud que el autor pudo tener en cuenta al momento de realizar las conductas que se investigan (del voto de la doctora Argibay).

37. Aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo—en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548)—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito (del voto de la doctora Argibay).

38. En el caso de crímenes contra la humanidad, el Estado argentino ha declinado la exclusividad del interés en la persecución penal para constituirse en el representante del interés de la comunidad mundial, el cual esta misma ha declarado inextinguible (del voto de la doctora Argibay).

39. La decisión que rechaza la excepción de falta de acción y acepta el rol de parte querellante no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario—art. 14, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)—, pues no pone término al pleito ni impide su continuación, sin que quepa apartarse de tal principio a menos que se verifique un agravio de insusceptible reparación ulterior, lo que no se verifica cuando el impulso procesal está a cargo de otros querellantes y del representante del Ministerio Público Fiscal, al poner de manifiesto que—de momento—cualquier decisión al respecto sería indiferente para alterar la situación del imputado (del voto en disidencia del doctor Fayt).

40. La derogación de las leyes 23.492 de "punto final" y 23.521 de "obediencia debida" (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548) sólo puede operar para el futuro, sin afectar o modificar situaciones existentes a la entrada en vigor de la norma derogatoria, como se pretendió con la sanción de la ley 25.779 de "derogación retroactiva" (Adla, LXIII-E, 3843) de tales normas, aun cuando los legisladores interpreten que se violó la Constitución durante el procedimiento de formación y sanción de las normas anuladas, pues el Congreso se estaría atribuyendo una

potestad que no tiene ningún poder constituido de la República, correspondiendo al Poder Judicial privarlas de efecto en forma retroactiva a través del control de constitucionalidad en un caso concreto (del voto en disidencia del doctor Fayt).

41. No puede legitimarse la ley 25.779 (Adla, LXIII-E, 3843), en cuanto dispuso la anulación de las leyes 23.492 de "punto final" y 23.521 de "obediencia debida" (Adla, XLVII-A, 192; XLVII-B, 1548), con la invocación del antecedente de la anulación dispuesta por la ley 23.040 respecto de la ley 22.924—conocida como de "pacificación nacional"—(Adla, XLIV-A, 3; LXIII-D, 3831), dictada por el Gobierno de facto durante el Proceso de Reorganización Nacional, ya que esta última norma configuró un evidente abuso de poder frente a las garantías y derechos esenciales de los individuos, o bien un palmario exceso en el uso de las facultades de los poderes públicos que se desempeñaron en sustitución de las autoridades legítimas (del voto en disidencia del doctor Fayt).

42. Tanto la aplicación retroactiva de la "Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad"—arts. I y IV—como la de la "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas"—en virtud del art. 15, ap. segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—, resultan inaplicables en el derecho argentino, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que los tratados deben ajustarse y guardar conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución (del voto en disidencia del doctor Fayt).

CS, 2005/06/14. — Simón, Julio Héctor y otros (*).

Ornissis...

(*) Publicado en: LA LEY 2005-E, 331, con nota de Nicolás Diana; Gonzalo S. Kodella; Florencia Moscarillo - LA LEY 2005-D, 651, con nota de Gregorio Badeni; Fernando R. Moreno - LA LEY 2005-D, 520, con nota de Calogero Pizzolo - LA LEY 30/06/2005, 4, con nota de Roberto J. Boico - LA LEY 2005-D, 142, con nota de Roberto J. Boico - LA LEY 21/06/2005, 6, con nota de Andrés Gil Domínguez - LA LEY 2005-C, 845, con nota de Andrés Gil Domínguez - LA LEY 2005-F, 24, con nota de Pablo L. Manili - JA 2005-IV, 378.

Buenos Aires, junio 14 de 2005.

Considerando: En mérito a lo que surge de las constancias que obran agregadas en el expediente, a la naturaleza de la causal invocada para fundar el apartamiento y a lo dispuesto en el art. 17, inc. 5°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde aceptar la excusación para conocer en este asunto presentada por el señor ministro doctor don Augusto César Belluscio.—*Enrique S. Petracchi*.—*Carlos S. Fayt*.—*Antonio Boggiano*.—*Juan C. Maqueda*.—*E. Raúl Zaffaroni*.—*Elena I. Highton de Nolasco*.—*Ricardo L. Lorenzetti*.—*Carmen M. Argibay*.

Buenos Aires, junio 14 de 2005.

Considerando: 1°) Que estas actuaciones se iniciaron con motivo de la querrela formulada por Buscarita Imperi Roa, quien afirmó que el 28 de noviembre de 1978 las denominadas "fuerzas conjuntas" secuestraron a su hijo José Liborio Poblete Roa, a su nuera Gertrudis Marta Hlaczik y a su nieta Claudia Victoria Poblete; y que distintas denuncias recibidas en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo señalaban que el militar retirado Ceferino Landa y su esposa Mercedes Beatriz Moreira, tenían en su poder a la menor anotada bajo el nombre de Mercedes Beatriz Landa.

Tras el correspondiente impulso fiscal en torno al hecho denunciado, se llevaron a cabo diversas medidas de prueba que, en efecto, determinaron que Claudia Victoria Poblete se encontraba con vida, que se hallaba inscripta con el nombre de Mercedes Beatriz Landa como hija de Ceferino Landa y de Mercedes Beatriz Moreira y que este estado se constituyó poco tiempo después de que las fuerzas armadas la privaran de su libertad cuando contaba con ocho meses de edad.

A raíz de ello, el 25 de febrero de 2000, se decretó el procesamiento con prisión preventiva del militar retirado teniente coronel Ceferino Landa y de Mercedes Beatriz Moreira en orden a los delitos previstos por los arts. 139, inc. 2°, 146 y 293 del Código Penal y se declaró la nulidad de la inscripción del nacimiento de Mercedes Beatriz Landa como hija de los nombrados (fs. 532/543 del expediente principal).

2°) Que en virtud de la prueba producida el agente fiscal amplió el requerimiento de instrucción en los siguientes términos "De acuerdo a los elementos colectados en las presentes actuaciones, la menor Claudia Victoria Poblete fue secuestrada junto con sus

progenitores José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik el 28 de noviembre de 1978. Esta familia...ha permanecido detenida en el centro de detención clandestina conocido como 'El Olimpo', lugar éste en que el matrimonio Poblete fuera despojado de su hija Claudia, mediante el artificio de que sería devuelta a sus abuelos, hecho éste que jamás tuvo lugar. De acuerdo con las constancias de autos, y el testimonio de algunas personas que permanecieron en calidad de detenidos clandestinos en 'El Olimpo', centro éste que estuvo a cargo del General Suárez Mason, algunos de los represores que habían estado encargados de dicho lugar serían responsables del secuestro y la operatoria que culminara en la entrega de Claudia Victoria Poblete a manos del Teniente Coronel Ceferino Landa. Entre aquellos que tendrían conocimiento del destino que se le diera a la menor, se encontrarían Juan Antonio Del Cerro, alias 'Colores', Roberto Rosa, más conocido como 'Clavel', Julio Simón quien actuaba bajo el seudónimo de 'Turco Julián', Carlos Alberto Rolón 'Soler', Guillermo Antonio Minicucci 'Rolando', Raúl Antonio Guglielminetti 'Mayor Guastavino', el Coronel Ferro entre otros. Asimismo, y en lo concerniente al secuestro de la familia Poblete, los intervinientes habrían sido Juan Antonio Del Cerro, Carlos Alberto Rolón y Julio Simón" (fs. 963/964 del principal).

En función de ello el juez instructor dispuso recibirles declaración indagatoria a Juan Antonio Del Cerro (apodado "Colores") y a Julio Héctor Simón (apodado "Turco Julián"), a cuyo efecto ordenó la detención (fs. 1050). A su vez, con fecha 6 de octubre de 2000, tuvo por parte querellante a Horacio Verbitsky, en su carácter de presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con arreglo a los fundamentos que lucen a fs. 1177.

Ahora bien, tras escuchar los descargos de los imputados, el juez de primer grado dispuso el procesamiento, con prisión preventiva, de Del Cerro y Simón por haber secuestrado, retenido y ocultado a Claudia Victoria Poblete—art. 146 del Código Penal—(fs. 1470/1490).

Por su parte, la alzada, al confirmar el mencionado auto de mérito, indicó que, de acuerdo con el impulso procesal generado por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querrela, la investigación debía abarcar los hechos ilícitos de los que habían sido víctimas los padres de Claudia Victoria Poblete; sobre este punto indicó que de los diversos testimonios y constancias incorporadas

272

en el expediente se desprendía que cuando los menores que permanecieron o nacieron en cautiverio en "El Olimpo" fueron efectivamente entregados a sus familiares, posteriormente sus padres recuperaron su libertad, en tanto que en los casos en los cuales los niños no fueron devueltos a sus abuelos (como el del matrimonio Poblete y el caso de Lucía Tartaglia) sus padres permanecían aún como detenidos desaparecidos (fs. 1607/1614).

3°) Que, en razón de ello, el juez de primera instancia consideró que existían elementos de prueba suficientes para recibirles declaración indagatoria a Julio Héctor Simón y a Juan Antonio Del Cerro por los hechos ilícitos sufridos por José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik; de modo que, con el objeto de cumplir con dichos actos procesales, declaró la invalidez de los arts. 1° de la ley 23.492 y 1, 3 y 4 de la ley 23.521 por ser incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1, 2, 8 y 25), con la Declaración Americana de Derechos Humanos (art. XVIII), con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2 y 9) y con el objeto y fin de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes (art. 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados); y, a su vez, con apoyo en el art. 29 de la Constitución Nacional declaró la inconstitucionalidad y la nulidad insanable del art. 1° de la ley 23.492 y de los arts. 1, 3 y 4 de la ley 23.521 (pronunciamiento de fecha 6 de marzo de 2001 que luce a fs. 1798/1892).

4°) Que tras recibirle declaración indagatoria a Julio Héctor Simón (fs. 1967/1969), se dictó el procesamiento con prisión preventiva del nombrado sobre la base de las siguientes circunstancias de hecho: "en su calidad de miembro de la Policía Federal Argentina e integrante de un grupo de tareas que dependía del Primer Cuerpo de Ejército Argentino y que formaba parte del sistema clandestino de represión (1976-1983), secuestró, junto a otros funcionarios de las fuerzas de seguridad fuertemente armados, a José Liborio Poblete, quien era lisiado de ambas piernas y se movilizaba en silla de ruedas, hecho ocurrido el día 27 de noviembre de 1978, en horas de la tarde y en la zona del barrio 'Once' de esta Ciudad... que en horas de la noche, junto a un grupo de personal de seguridad fuertemente armado, secuestró a la esposa de Poblete, Gertrudis Marta Hlaczik (que se encontraba con la hija de ambos, Claudia Victoria), quien fue capturada en su domicilio, sito entre las calles 41 y 42 de Guernica, Provincia

de Buenos Aires. Poblete y Hlaczik eran adherentes al grupo político 'Cristianos para la Liberación'. Los secuestros de ambas personas se realizaron con el objeto de conducirlos al centro clandestino de detención denominado 'Olimpo' que se encontraba ubicado en la calle Ramón Falcón, entre Lacarra y Olivera, de esta ciudad; con pleno conocimiento de que allí serían sometidos a torturas y vejámenes y que, luego, en estado de total indefensión, su destino probable sería la eliminación física (muerte), a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad que formaban parte del sistema clandestino de represión. Ya en el centro 'Olimpo' José Poblete y Gertrudis Hlaczik fueron torturados por Julio Héctor Simón, entre otros, e interrogados acerca de otros integrantes de la agrupación política a la que pertenecían. Entre los métodos de tortura utilizados contra ambos se encontraba la 'picana eléctrica', la aplicación de golpes con elementos contundentes como palos o gomas. Asimismo, Julio Simón, junto a otros integrantes de las fuerzas de seguridad, mantuvieron privados de su libertad a Gertrudis Hlaczik y a José Poblete sin dar intervención a la autoridad judicial. Durante el tiempo que duró su cautiverio en 'Olimpo' Hlaczik y Poblete fueron sometidos a vejámenes y malos tratos; por ejemplo, se les aplicaban golpes, y a Gertrudis Hlaczik la arrastraron tomada de los pelos y desnuda, y a José Poblete, a quien le decían 'cortito', lo levantaban y lo soltaban desde lo alto sabiendo que la falta de miembros inferiores le impediría evitar que se golpeará contra el suelo. Todo ello era realizado por el grupo de tareas que integraba Simón, con la participación activa de éste, quien daba órdenes, custodiaba a los detenidos, y permanecía en el centro de detención en forma estable. Esta situación se mantuvo hasta el mes de enero de 1979 cuando Poblete y Hlaczik fueron sacados del centro 'Olimpo' y presumiblemente eliminados físicamente por personas hasta el momento no identificadas" (fs. 2678/2735).

Estos hechos fueron calificados como crímenes contra la humanidad consistentes en la privación ilegal de la libertad, doblemente agravada, por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, reiterada en dos oportunidades en concurso real, la que, a su vez, concurría materialmente con tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en dos oportunidades en concurso real entre sí (arts. 118 de la Constitución Nacional; 55, 144 bis, inc. 1° y último párrafo —ley 14.616— en función del art. 142, incs. 1° y 5° —ley 21.338—,

144 ter, párrafos primero y segundo —ley 14.616— del Código Penal; 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).

5°) Que, a su turno, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital Federal, con fecha 9 de noviembre de 2001, rechazó la excepción de falta de acción planteada por la defensa de Julio Héctor Simón, y confirmó la decisión del juez de grado en cuanto había declarado inválidos e inconstitucionales los arts. 1° de la ley 23.492 —de punto final— y 1°, 3° y 4° de la ley 23.521 —de obediencia debida— y había citado a prestar declaración indagatoria a Julio Héctor Simón (expediente 17.889); y en la misma fecha en el expediente 17.768 homologó el pronunciamiento del juez de primera instancia que había decretado el procesamiento con prisión preventiva de Julio Héctor Simón, por crímenes contra la humanidad, consistentes en privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, reiterada en dos oportunidades en concurso real, que, a su vez, concurre materialmente con tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en dos oportunidades en concurso real entre sí (art. 118 de la Constitución Nacional; arts. 2, 55 y 144 bis, inc. 1° y último párrafo —texto según ley 14.616— en función del art. 142, incs. 1° y 5° —texto según ley 20.642—, 144 tercero, párrafos primero y segundo —texto según ley 14.616— del Código Penal; y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).

Contra ambas decisiones el procesado dedujo el recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisibile con el argumento de que la presentación carecía de la fundamentación autónoma exigida por el art. 15 de la ley 48; tal decisión dio lugar a la presente queja.

6°) Que, en el recurso extraordinario, el recurrente plantea la nulidad absoluta de todo lo actuado a raíz de la intervención de Horacio Verbitsky (presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales) como querellante, pues sostiene que la participación del nombrado en el proceso significó la consagración —por vía judicial— de una acción popular no contemplada en la ley procesal ni susceptible de encontrar amparo en el art. 43 de la Constitución Nacional, que sólo recepta la protección de los derechos de incidencia colectiva, por lo que en consecuencia, a su juicio, carecía de legitimación para querellar.

Por otro lado, postula la validez constitucional de la ley 23.521 y solicita que se apli-

que el beneficio reconocido en el art. 1°. Afirma, que la constitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no es un tema justiciable, pues al Poder Judicial no le es dado, en los términos de los arts. 75, incs. 12 y 20 de la Constitución Nacional, juzgar sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones adoptadas en la zona de reserva de los demás poderes del Estado. Que tales leyes de amnistía por el alto propósito que perseguían de lograr la concordancia social y política, no son susceptibles de ser declaradas inconstitucionales.

También invoca la lesión a las garantías de la ley penal más benigna, del *nullum crimen nulla poena sine lege*, así como de la prohibición de aplicar la ley *ex post facto*. Sostiene que se aplicó retroactivamente una norma de naturaleza penal, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas —aprobada por la ley 24.556 y, en cuanto a su jerarquía constitucional, por la ley 24.820— con la consecuencia de que elimina los beneficios de la prescripción de la acción y de la pena. Agrega que no se puede restar significación a la validez inalterable de las garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional, en aras de los principios generales reconocidos por la comunidad internacional (art. 4 de la ley 23.313).

7°) Que, en primer lugar, cabe puntualizar que las resoluciones recurridas en tanto importan la restricción de la libertad del imputado son equiparables a sentencia definitiva, según la doctrina establecida por los precedentes de Fallos: 310:2246; 312:1351; 314:451, entre otros.

8°) Que en lo que atañe al cumplimiento del requisito propio de tribunal superior contemplado por el art. 14 de la ley 48, corresponde hacer las siguientes precisiones:

El recurso extraordinario fue interpuesto el 6 de junio de 2002 contra la sentencia de la cámara federal con arreglo a lo decidido en los pronunciamientos "Rizzo" (Fallos: 320:2118 —LA LEY, 1997-F, 350—), "Pancelra" (Fallos: 324:1632 —LA LEY, 2001-C, 922; 2001-D, 764; 2001-E, 778; DJ, 2001-2-6600—) y "Stancanelli" (Fallos: 324:3952 —LA LEY, 2001-F, 834; 2002-A, 240; 2002-B, 188; DJ, 2002-1, 452—), según los cuales satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia, la alzada constituía el superior tribunal a los fines de habilitar la apertura de esta instancia federal.

Sin embargo, esta doctrina ha sido modificada recientemente a raíz de la sentencia dictada in re D.199.XXXIX "Di Nunzio, Beatriz Hermi-

273

nía s/excarcelación —causa N° 107.572—, del 3 de mayo de 2005, en la que se fijó la regla por la cual siempre que en el ámbito de la justicia penal nacional, conforme al ordenamiento procesal vigente, se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de esta Corte por vía extraordinaria, estos deben ser tratados previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, en su carácter de tribunal intermedio, constituyendo de esta manera a dicho órgano en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la ley 48.

En ese caso, además, se subrayó que la determinación del tribunal superior de la causa en el ámbito de la justicia penal nacional no había sido precedida de una jurisprudencia uniforme, razón por la cual se estableció que la aplicación en el tiempo del nuevo criterio fijado correspondía a las apelaciones federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a ese fallo (doctrina de Fallos: 308:552 "Tellez").

Sin embargo, con el objeto de dar cabal cumplimiento con la nueva doctrina fijada, mas sin que este modo de proceder vulnere los derechos del recurrente, se dispuso remitir nuevamente las actuaciones a la instancia de origen para que la defensa —a quien ya se le había garantizado el derecho al recurso en la instancia de apelación— pudiese introducir por las vías que se calificaron como aptas por ante el tribunal de casación sus derechos y agravios federales involucrados.

9°) Que esta solución no puede aplicarse al caso en función de las consecuencias a que dan lugar las vías utilizadas por el recurrente.

En efecto, cabe recordar que el imputado impugnó simultáneamente la sentencia apelada por ante la Cámara Nacional de Casación Penal mediante los recursos de inconstitucionalidad y de casación, y por ante esta Corte con un recurso extraordinario federal; que frente al rechazo de la totalidad de las apelaciones, el imputado dedujo sendas quejas ante la Cámara Nacional de Casación Penal y ante este Tribunal; que la cámara de casación desestimó la presentación directa con fundamento —precisamente— en la doctrina derivada de los precedentes "Rizzo" y "Panceira"; y que de acuerdo a la certificación agregada a fs. 256 de esta queja (S.1767. XXXVIII) el imputado no interpuso recurso extraordinario contra dicha decisión.

Lo expuesto revela la imposibilidad jurídica de reeditar la instancia casatoria, pues el recurrente agotó y consintió la denegación de

esta vía de impugnación mediante una conducta que no puede jugar en contra del ejercicio del derecho de defensa del imputado, ya que en definitiva su proceder se ajustó a las reglas establecidas y aceptadas por la doctrina imperante.

Las especiales circunstancias reseñadas tornan de estricta aplicación la pauta jurisprudencial fijada en Fallos: 308:552 "Tellez", según la cual la autoridad institucional del nuevo precedente debe comenzar a regir para el futuro, de modo que corresponde examinar los agravios que, como de naturaleza federal, invoca el recurrente.

En esta inteligencia, además, esta Corte ha considerado arbitrario el pronunciamiento fundado en el viraje jurisprudencial operado a partir de un nuevo precedente, sobre la base de que se desvirtúa la necesidad de que el litigante conozca de antemano las reglas a las que debe atenerse al momento de intentar el acceso a la instancia revisora, lo cual genera una situación concretamente conculcatoria del derecho constitucional de defensa (Fallos: 320:1393).

10) Que, por último, cabe señalar que no se observa apartamiento de lo aquí dispuesto con el criterio aplicado por este Tribunal en los autos "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Juan Antonio Del Cerro en la causa 'Simón, Julio y Del Cerro, Juan Antonio s/sustracción de menores de 10 años —causa n° 8686/2000—", con fecha 30 de septiembre de 2003 (Fallos: 326:3988), en cuanto devolvió los autos al tribunal de origen para que se sustancie el recurso de inconstitucionalidad (art. 474 de Código Procesal Penal de la Nación), pues lo decisivo es que en ese caso esta Corte estaba habilitada para abrir la instancia revisora de la Cámara Nacional de Casación Penal mientras que en el sub lite se carece de dicha atribución en los términos señalados, ocasionando por ende a este procesado un agravio substancial a sus garantías constitucionales si no se procediese del modo indicado; máxime, cuando no puede soslayarse la magnitud del tiempo transcurrido y la restricción de libertad que soporta el recurrente con motivo de la decisión de la que se agravia.

En este sentido, no debe pasarse por alto que uno de los contenidos esenciales de la garantía constitucional de la defensa en juicio es el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación

de incertidumbre y de restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal (Fallos: 272:188).

11) Que, en primer término, corresponde señalar que el recurso extraordinario es inadmisibile en cuanto al agravio fundado en la falta de legitimación de Horacio Verbitsky (presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales) para ejercer el rol de querellante en el proceso que aquí se trata, pues esta Corte tiene establecido que la decisión que rechaza la excepción de falta de acción y acepta el rol de parte querellante no constituye sentencia definitiva, en tanto no pone término al pleito ni impide su continuación (Fallos: 310:248).

Si bien se ha hecho excepción a esta regla cuando la sentencia apelada puede causar un agravio de insusceptible reparación ulterior, en el caso no se verifica un supuesto de tal naturaleza ya que la circunstancia de que el impulso procesal se encuentre en cabeza de otros querellantes así como del representante del Ministerio Público Fiscal, pone de manifiesto que —de momento— cualquier decisión que se adopte sobre este planteo sería indiferente para alterar la situación del imputado.

En este sentido, cabe subrayar que más allá de la tacha que postula este procesado con respecto al alcance otorgado por la cámara a quo a la figura del querellante contemplada en la actualidad por el art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación, materia que —como regla— es ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 180:136; 188:178; 252:195), lo decisivo es que la recurrente no ha logrado demostrar el modo en que su situación procesal ha sido perjudicada a raíz de la petición efectuada por este querellante en el sub lite para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, si se tiene en cuenta que un planteo de esa naturaleza estaba insito en el requerimiento fiscal que incluyó en el objeto del proceso la investigación de los delitos cometidos a raíz de la detención y desaparición de José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik; máxime cuando con particular referencia a la declaración de inconstitucionalidad de normas inferiores a la Ley Fundamental, y más allá de las opiniones individuales que los jueces de esta Corte tienen sobre el punto, el Tribunal viene adoptando desde el año 2001 como postura mayoritaria la doctrina con arreglo a la cual una decisión de esa naturaleza es susceptible de ser tomada de oficio (Fallos: 324:3219; causa B.1160.XXXVI "Banco Comercial Finanzas S.A. (en liquidación Banco Cen-

tral de la República Argentina) s/quiebra", de fecha 19 de agosto de 2004).

Ello demuestra que la ineficacia de la decisión torna innecesario en el actual grado de desarrollo del proceso, el pronunciamiento de este Tribunal por falta de gravamen actual.

12) Que en cuanto a la pretensión del imputado de ampararse bajo la llamada "ley de obediencia debida", corresponde señalar que al dictar dicha ley (23.521), el Congreso Nacional resolvió convalidar la decisión política del Poder Ejecutivo de declarar la impunidad del personal militar en las condiciones del art. 1° de dicha ley, por los delitos cometidos "desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de septiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo" (art. 10, inc. 1°, ley 23.049). Con el objetivo señalado, la ley mencionada se sustentó en la creación de una presunción, de conformidad con la cual, se debía considerar "de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad" (art. 1°, ley 23.521, in fine).

13) Que la ley mencionada presentaba fallencias serias en cuanto a su formulación, las cuales fueron señaladas al examinar su compatibilidad con la Constitución Nacional en el precedente de Fallos: 310:1162 (conf. voto del juez Petracchi). Como se indicó en esa oportunidad, la ley 23.521 presentaba la particularidad de que no establecía regla alguna aplicable a hechos futuros y, de este modo, no cumplía con el requisito de generalidad propio de la función legislativa, infringiendo, por lo tanto, el principio de división de poderes. Asimismo, tal como se destacó en ese momento, no es posible admitir que las reglas de obediencia militar puedan ser utilizadas para eximir de responsabilidad cuando el contenido ilícito de las órdenes es manifiesto, tal como ocurre en los casos de los órdenes que implican la comisión de actos atroces o aberrantes, pues ello resulta contrario a la Constitución Nacional.

No obstante, a pesar de las deficiencias de la técnica legislativa utilizada, la ratio legis era evidente: amnistiar los graves hechos delictivos cometidos durante el anterior régimen militar, en el entendimiento de que, frente al grave conflicto de intereses que la sociedad argentina enfrentaba en ese momento, la amnistía aparecía como la única vía posible para preser-

277

var la paz social. La conservación de la armonía sociopolítica era valorada por el legislador como un bien jurídico sustancialmente más valioso que la continuación de la persecución penal de los beneficiarios de la ley. Dicha ley fue juzgada, en consecuencia, como el resultado de una ponderación acerca de los graves intereses en juego, privativa del poder político, y como tal fue admitida por este Tribunal.

14) Que desde ese momento hasta el presente, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos —con el rango establecido por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional— ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características, cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos de esa naturaleza.

15) Que, en efecto, a partir de la modificación de la Constitución Nacional en 1994, el Estado argentino ha asumido frente al derecho internacional y en especial, frente al orden jurídico interamericano, una serie de deberes, de jerarquía constitucional, que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolución claramente limitativa de las potestades del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos como los del sub lite.

16) Que si bien es cierto que el art. 75, inc. 20 de la Constitución Nacional mantiene la potestad del Poder Legislativo para dictar amnistías generales, tal facultad ha sufrido importantes limitaciones en cuanto a sus alcances. En principio, las leyes de amnistía han sido utilizadas históricamente como instrumentos de pacificación social, con la finalidad declarada de resolver los conflictos remanentes de luchas civiles armadas luego de su finalización. En una dirección análoga, las leyes 23.492 y 23.521 intentaron dejar atrás los enfrentamientos entre "civiles y militares". Sin embargo, en la medida en que, como toda amnistía, se orientan al "olvido" de graves violaciones a los derechos humanos, ellas se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables (arg. art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).

17) Que, tal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades, la

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. Fallos: 326:2805, voto del juez Petracchi, y sus citas).

18) Que ya en su primer caso de competencia contenciosa, "Velázquez Rodríguez" (1), la Corte Interamericana dejó establecido que incumbe a los Estados partes no sólo un deber de respeto de los derechos humanos, sino también un deber de garantía, de conformidad con el cual, "en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención, cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención" (2).

19) Que si bien el fallo citado reconoció con claridad el deber del Estado de articular el aparato gubernamental en todas sus estructuras del ejercicio del poder público de tal manera que sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, lo cierto es que las derivaciones concretas de dicho deber se han ido determinando en forma paulatina a lo largo del desarrollo de la evolución jurisprudencial del tribunal internacional mencionado, hasta llegar, en el momento actual, a una proscripción severa de todos aquellos institutos jurídicos de derecho interno que puedan tener por efecto que el Estado incumpla su deber internacional de perseguir, juzgar y

(1) CIDH, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C N° 4.
(2) Loc. cit. § 172.

sancionar las violaciones graves a los derechos humanos.

20) Que en el caso particular del Estado argentino, las leyes de punto final, obediencia debida y los subsiguientes indultos fueron examinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 28/92 (3). En esa oportunidad, la Comisión sostuvo que el hecho de que los juicios criminales por violaciones de los derechos humanos—desapariciones, ejecuciones sumarias, torturas, secuestros— cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas hayan sido cancelados, impedidos o dificultados por las leyes 23.492 (de punto final), 23.521 (de obediencia debida) y por el decreto 1002/89, resulta violatorio de los derechos garantizados por la Convención, y entendió que tales disposiciones son incompatibles con el art. 18 (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, recomendó al gobierno argentino "la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar" (4).

21) Que ya a partir de ese momento había quedado establecido que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la circunstancia de que los actos en cuestión hubieran sido dictados por órganos democráticos fundados en la urgente necesidad de reconciliación nacional y de la consolidación del régimen democrático (tal había sido la alegación del gobierno argentino) (5) era prácticamente irrelevante a los fines de la determinación de la lesión de los derechos a que se refieren los arts. 8.1 y 25.1 de la CADH.

22) Que, sin embargo, restaba aún por determinar los alcances concretos de la recomendación de la Comisión en el Informe citado, en particular, con respecto a cuáles eran las "medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos". Ello, por cuanto el tenor de la recomendación dirigida por la Comisión a la Argentina con relación a la incompatibilidad de las leyes de punto final y obediencia debida no permitía

inferir, sin más ni más, si era suficiente el mero "esclarecimiento" de los hechos, en el sentido de los llamados "juicios de la verdad", o si los deberes (y las facultades) del Estado argentino en esta dirección también suponían privar a las leyes y el decreto en cuestión de todos sus efectos, ya que tal conclusión significaba producir una fuerte restricción de la cosa juzgada y del principio de legalidad, que impide prolongar retroactivamente la prescripción de la acción penal, ya cumplida en muchos casos.

23) Que tales dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relación a las leyes de punto final y obediencia debida han quedado esclarecidas a partir de la decisión de la Corte Interamericana en el caso "Barrios Altos" (6). En efecto, en dicha sentencia, la Corte Interamericana hizo lugar a una demanda contra el Perú, a raíz de un episodio ocurrido en Lima, en el vecindario de "Barrios Altos", el 3 de noviembre de 1991. Según se desprende del relato de los hechos, esa noche, durante una fiesta para recaudar fondos, llegaron dos vehículos con sirenas policiales. Sus ocupantes llevaban pasamontañas y obligaron a los asistentes a arrojarlos al suelo, y una vez allí, les dispararon con ametralladoras y mataron a quince personas. Los autores del hecho fueron identificados como miembros de inteligencia militar del ejército peruano, que actuaban en un "escuadrón de eliminación" con su propio programa antisubversivo y que habría obrado en represalia contra supuestos integrantes de la agrupación "Sendero Luminoso". Aunque el hecho ocurrió en 1991, sólo en 1995 una fiscal intentó sin éxito hacer comparecer a los militares imputados a fin de que prestaran declaración. Poco después, una jueza asumió la investigación y ordenó la citación. Sin embargo, la justicia militar dispuso que los militares no declararan. De este modo, se planteó un conflicto de competencia ante la Corte peruana, y antes de que ésta resolviera, el Congreso sancionó una ley de amnistía (26.479) que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995. La jueza declaró la inconstitucionalidad de la amnistía por violar garantías y obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al tiempo, el Congreso dictó una nueva ley (26.492), en la que declaró que la amnistía no era revisable en sede judicial y

(3) "Consuelo Herrera v. Argentina", casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311, informe N° 28, del 2 de octubre de 1992.

(4) Loc. cit., puntos resolutive 1 y 3, respectivamente.
(5) Cf. § 25.

(6) CIDH, caso "Chumbipuma Aguirre vs. Perú", sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75.

275

que era de aplicación obligatoria. Además, amplió el alcance de la ley anterior, con lo cual quedaron también abarcados aquellos hechos que no hubieran sido denunciados. El tribunal de apelación que revisaba la decisión de la jueza declaró la constitucionalidad de las leyes en cuestión, y ello determinó el archivo definitivo de la investigación.

La Corte Interamericana consideró responsable internacionalmente a Perú, no sólo por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal derivada de la masacre, sino también por el dictado de las dos leyes de amnistía, que constituyó la violación de las garantías judiciales, del derecho a la protección judicial, de la obligación de respetar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno. Con relación a este último aspecto, señaló expresamente que "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos" (7). Señaló asimismo: "La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz (...). Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana" (8). Consiguientemente, ante la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables" (9).

(7) Cf. § 41.

(8) Cf. § 43.

(9) Cf. § 44. Sin destacar en el original.

24) Que la traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en "Barrios Altos" al caso argentino resulta imperativa, si es que las decisiones del Tribunal internacional mencionado han de ser interpretadas de buena fe como pautas jurisprudenciales. Por cierto, sería posible encontrar diversos argumentos para distinguir uno y otro caso, pero tales distinciones serían puramente anecdóticas. Así, por ejemplo, la situación que generó las leyes peruanas y su texto no son, por cierto, "exactamente" iguales a las de punto final y obediencia debida. Sin embargo, a los fines de determinar la compatibilidad de dichas leyes con el derecho internacional de los derechos humanos, no es esto lo que importa. Lo decisivo aquí es, en cambio, que las leyes de punto final y de obediencia debida presentan los mismos vicios que llevaron a la Corte Interamericana a rechazar las leyes peruanas de "autoamnistía". Pues, en idéntica medida, ambas constituyen leyes ad hoc, cuya finalidad es la de evitar la persecución de lesiones graves a los derechos humanos.

En este sentido, corresponde destacar que lo que indujo al tribunal interamericano a descalificar dichas reglas no fue tanto que el régimen haya intentado beneficiarse a sí mismo, en forma directa, con la impunidad de los delitos que él mismo cometió (a la manera de lo ocurrido en nuestro país con la ley de facto 22.924). Antes bien, el vicio fundamental no deriva tanto del hecho de que se trate de un perdón dictado por el propio ofensor o del carácter de facto o no del gobierno que las dicta, sino que son razones materiales las que imponen la anulación de leyes de estas características. Por lo tanto, resulta claro que también deben quedar alcanzadas aquellas leyes dictadas por regímenes ulteriores que otorgan impunidad a aquellos autores que pertenecían al régimen anterior, e infringen, de este modo, el propio deber de perseguir penalmente las violaciones a los derechos humanos.

25) Que, a esta altura, y tal como lo señala el dictamen del señor Procurador General, la circunstancia de que leyes de estas características puedan ser calificadas como "amnistías" ha perdido toda relevancia en cuanto a su legitimidad. Pues, en la medida en que dichas normas obstaculizan el esclarecimiento y la efectiva sanción de actos contrarios a los derechos reconocidos en los tratados mencionados, impiden el cumplimiento del deber de garantía a que se ha comprometido el Estado argentino, y resultan inadmisibles.

26) Que, en este sentido, el caso "Barrios Altos" estableció severos límites a la facultad

del Congreso para amnistiar, que le impiden incluir hechos como los alcanzados por las leyes de punto final y obediencia debida. Del mismo modo, toda regulación de derecho interno que, invocando razones de "pacificación" disponga el otorgamiento de cualquier forma de amnistía que deje impunes violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional, y debe ser efectivamente suprimida.

27) Que en este punto resulta pertinente recordar el voto concurrente del juez García Ramírez en el caso "Barrios Altos", en el que se reconoce que el dictado de una amnistía, bajo ciertas circunstancias, podría resultar conveniente para el restablecimiento de la paz y la apertura de nuevas etapas constructivas, en el marco de "un proceso de pacificación con sustento democrático y alcances razonables que excluyen la persecución de conductas realizadas por miembros de los diversos grupos en contienda...". Sin embargo "esas disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menoscabo de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad" (10).

28) Que, por otro lado, a partir de lo decidido en el caso citado con relación a los efectos de las llamadas "leyes de autoamnistía", se advierte que no sería suficiente con la supresión "simbólica" de las leyes de esta naturaleza. Así, la Corte Interamericana no se limitó a declarar la incompatibilidad de las leyes con la Convención, sino que resolvió que las leyes peruanas carecían de efectos y le impuso al estado peruano la obligación de hacer a un lado la cosa juzgada. Visto el caso argentino desde esta perspectiva, se concluye que la mera derogación de las leyes en cuestión, si ella no viene acompañada de la imposibilidad de invocar la ultractividad de la ley penal más benigna, no alcanzaría a satisfacer el estándar fijado por la Corte Interamericana.

29) Que, por lo demás, la sentencia en el caso "Barrios Altos" no constituye un precedente aislado, sino que señala una línea jurisprudencial constante. Así, en la sentencia del 3 de septiembre de 2001, al interpretar el alcance de dicho caso, la Corte Interamericana ratificó su decisión anterior y señaló que lo allí resuelto se aplicaba con efecto general a todos los demás casos en que se hubieran

(10) Cf. caso "Barrios Altos" supra cit., voto concurrente del juez García Ramírez, §§ 10 y sgtes.

aplicado las leyes de amnistía examinadas en aquella oportunidad, y volvió a insistir en que "la promulgación de una ley manifestamente contraria a las obligaciones asumidas por el Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado" (11).

30) Que la inadmisibilidad de las disposiciones de amnistía y prescripción, así como el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que tiendan a impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos fue reiterada con posterioridad y configura un aspecto central de la jurisprudencia de la Corte Interamericana (12), cuyos alcances para casos como el presente no pueden ser soslayados. Por lo demás, su concreta relevancia en el derecho interno frente a supuestos similares ya ha sido reconocida por este Tribunal en Fallos: 326:2805 ("Videla, Jorge Rafael"), voto del juez Petracchi; 326:4797 ("Astiz, Alfredo Ignacio"), voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni y, en especial, en la causa A.533.XXXVIII, "Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros—causa n° 259—", resuelta el 24 de agosto de 2004 (LA LEY, 2004-E, 827; Sup.Const., octubre/2004, 4; DJ 15/09/2004, 13; RDM 2004-V, 119), voto del juez Petracchi, en el que se admitió la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ingresada a nuestro ordenamiento jurídico ex post facto.

31) Que, desde ese punto de vista, a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el objeto de la presente causa. Esto significa que quienes resultaron be-

(11) Cf. CIDH, caso "Barrios Altos", interpretación de la sentencia de fondo, sentencia del 3 de septiembre de 2001, Serie C N° 83.

(12) Cf. CIDH, caso "19 Comerciantes", sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C N° 109, (§§ 175, 262 y sgtes.); caso "Hermanos Gómez Paquiyauri", sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C N° 110, (§§ 232 y sgtes.); caso "Tibi", sentencia del 7 de septiembre de 2004 Serie C N° 114, (§ 259 y sus citas); caso "Masacre Plan de Sánchez", sentencia del 19 de noviembre de 2004 Serie C N° 116, (§§ 95 y sgtes., esp. § 99); caso "Hermanas Serrano Cruz", sentencia del 1° de marzo de 2005 Serie C N° 120, (§§ 168 y sgtes., esp. § 172); caso "Huilca Tecse", sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie C N° 121, (§§ 105 y sgtes., esp. § 108).

276

neficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Pues, de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana en los casos citados, tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas ni para la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca. En otras palabras, la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana impide que el principio de "irretroactividad" de la ley penal sea invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los derechos humanos.

32) Que análogas consideraciones son las que han llevado al Congreso Nacional a dictar la ley 25.779, por medio de la cual el Poder Legislativo declara insanablemente nulas las leyes en cuestión. El debate parlamentario de dicha ley coincidió con el reconocimiento de jerarquía constitucional a la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad" y revela, sin lugar a dudas, la intención legislativa de suprimir todos los efectos de las leyes anuladas. Así, en la Cámara de Diputados se evaluó, expresamente, la circunstancia de que la derogación de las leyes dispuesta en el art. 2, de la ley 24.952 no hubiera producido el efecto deseado, en razón de que no dejó claramente establecida la inaplicabilidad del principio de la ley penal más benigna (13). Asimismo, la discusión legislativa permite inferir que el sentido principal que se pretendió dar a la declaración de nulidad de las leyes fue, justamente, el de intentar dar cumplimiento a los tratados constitucionales en materia de derechos humanos por medio de la eliminación de todo aquello que pudiera aparecer como un obstáculo para que la justicia argentina investigue debidamente los hechos alcanzados por dichas leyes (14) y, de este modo, subsanar la infracción al derecho internacional que ellas continuaban representando (15). Se trató, fundamentalmente, de facilitar el cumplimiento del deber estatal de reparar,

haciéndolo de la forma más amplia posible, de conformidad con los compromisos asumidos con rango constitucional ante la comunidad internacional.

33) Que los alcances de dicha obligación, por otra parte, han sido recientemente examinados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, según el cual "cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto (...) los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal como ha ocurrido con determinadas amnistías..." (16).

En el mismo sentido, y en lo que atañe concretamente a nuestro país, las observaciones finales de dicho Comité sobre este tema dirigidas a la Argentina (17) establecen la inadmisibilidad de la situación creada por las leyes 23.492 y 23.521 también frente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la insuficiencia de la mera derogación de tales normas: "Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores" (18). Anteriormente, el mismo organismo ya había expresado lo siguiente: "El Comité nota que los compromisos hechos por el Estado Parte con respecto a su pasado autoritario reciente, especialmente la ley de obediencia debida y la ley de punto final y el indulto presidencial de altos oficiales militares, son inconsistentes con los requisitos del Pacto (PIDCP)" (19). Asimismo, manifestó en esa ocasión la preocupación sobre ambas leyes "pues privan a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante el período del gobierno autoritario de un recurso efectivo en violación a los artículos 2 (2,3) y 9 (5) del Pacto (PIDCP). El Comité ve con preocupación que las amnistías e indultos han impedido las investigaciones sobre denuncias de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y agentes de los servicios de seguridad nacional incluso en casos donde existen suficientes pruebas sobre las vio-

(16) Observación General N° 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80° período de sesiones (2004), §§ 17 y sgtes.

(17) Sesión 1893, del 1° de noviembre de 2000. Tales observaciones también fueron tomadas en consideración en el debate en la Cámara de Senadores i.a. págs. 42 y 47.

(18) Loc. cit., § 9.

(19) Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Comentario sobre Argentina adoptados durante su sesión 53, el 5 de abril de 1995, § 3.

(13) Cf. Cámara de Diputados, 4° sesión ordinaria, 12 de agosto de 2003, pág. 22 y sgtes.

(14) Cf. Cámara de Diputados, 4° sesión ordinaria, 12 de agosto de 2003, i.a. págs. 31, 50, 52.

(15) Cf. versión taquigráfica provisional, Cámara de Senadores, 11 sesión ordinaria, 20 y 21 de agosto de 2003, i.a., págs. 3, 36, 39 y sgtes. En esta dirección, también se citaron en apoyo de la decisión las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formulada en el informe 28.92, supra cit.

laciones a los derechos humanos tales como la desaparición y detención extrajudicial de personas, incluyendo niños" (20).

34) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, considerada la ley 25.779 desde una perspectiva estrictamente formalista, podría ser tachada de inconstitucional, en la medida en que, al declarar la nulidad insanable de una ley, viola la división de poderes, al usurpar las facultades del Poder Judicial, que es el único órgano constitucionalmente facultado para declarar nulas las leyes o cualquier acto normativo con eficacia jurídica.

Sin embargo, corresponde atender a la propia naturaleza de lo que la ley dispone, así como a la circunstancia de que ella, necesariamente, habrá de ser aplicada—o, en su caso, rechazada— por los propios jueces ante quienes tramitan las investigaciones de los hechos en particular. Desde este punto de vista, se advierte que la supuesta "usurpación de funciones" tiene un alcance muy corto, ya que, en todo caso, se reduce a adelantar cuál es la solución que el Congreso considera que corresponde dar al caso, pero en modo alguno priva a los jueces de la decisión final sobre el punto.

Por otro lado, de acuerdo con lo que ya se ha dicho, queda claro que el contenido mismo de lo declarado por la ley 25.779 coincide con lo que los jueces deben declarar con relación a las leyes referidas. Diferente sería la cuestión, si la nulidad declarada por la ley fuera contraria a derecho. Pero, en la medida en que las leyes deben ser efectivamente anuladas, declarar la inconstitucionalidad de dicha norma para luego resolver en el caso tal como ella lo establece constituiría un formalismo vacío. Por lo demás, de ese modo se

perdería de vista que el sentido de la ley no es otro que el de formular una declaración del Congreso sobre el tema y que, de hecho, la "ley" sólo es apta para producir un efecto político simbólico. Su efecto vinculante para los jueces sólo deriva, en rigor, de que la doctrina que ella consagra es la correcta: la nulidad insanable de las leyes 23.492 y 23.521.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se resuelve:

1.- Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance indicado en los considerandos; declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, y confirmar las resoluciones apeladas.

2.- Declarar la validez de la ley 25.779.

3.- Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

4.- Imponer las costas al recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. —*Enrique S. Petracchi*.—*Carlos S. Fayt* (en disidencia).—*Antonio Boggiano* (según su voto).—*Juan C. Maqueda* (según su voto).—*E. Raúl Zaffaroni* (según su voto).—*Elena I. Highton de Nolasco* (según su voto).—*Ricardo L. Lorenzetti* (según su voto).—*Carmen M. Argibay* (según su voto).

Omissis...

(20) Loc. cit., § 10.

8. VERBITSKY, HORACIO

AUTONOMIA PROVINCIAL

Cárcel — Constitución Nacional — Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes — Cuestión federal — Derechos constitucionales — Derechos humanos — Detención de personas — Hábeas corpus — Igualdad ante la ley — Organización de las Naciones Unidas — Policía — Prisión preventiva — Provincia de Buenos Aires — Recurso extraordinario — Reglamento carcelario — Sentencia definitiva — Sistema representativo republicano y federal — Supremacía constitucional — Tratado internacional.

Hechos

El Director del Centro de Estudios Legales y Sociales interpuso un habeas corpus correcti-

vo y colectivo a favor de la totalidad de los detenidos alojados en establecimientos policiales superpoblados y/o en comisarías de la Pro-

277

vincia de Buenos Aires. Relató que los detenidos, incluidos mujeres y menores, padecían condiciones deplorables en tanto los calabozos estaban en un estado deplorable de conservación e higiene. La acción fue rechazada por el Tribunal de Casación Penal, quien consideró que debía analizarse cada caso en concreto. El accionante interpuso sendos recursos de nulidad de inaplicabilidad de ley, que fueron declarados inadmisibles por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ante ello, el promotor del hábeas corpus interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación por mayoría revoca la sentencia cuestionada.

1. En la eventualidad de que puedan verificarse casos de agravamiento de las condiciones de detención de las personas que están alojadas en establecimientos policiales y/o en comisarias superpobladas de la Provincia de Buenos Aires, que importarían trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad internacional del Estado Nacional, debe inscribirse a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los demás tribunales de dicha provincia para que hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda.
2. La presencia de adolescentes y enfermos en establecimientos policiales y/o en comisarias superpobladas de la Provincia de Buenos Aires, es susceptible de configurar un trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos y generar responsabilidad del Estado Nacional, con flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, por lo cual debe disponerse que en un plazo perentorio la Suprema Corte provincial, por las vías procedentes, haga cesar esas situaciones.
3. Siendo que la situación no controvertida de los detenidos en establecimientos policiales y/o en comisarias superpobladas de la Provincia de Buenos Aires pone en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario y policial y genera condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo, debe inscribirse a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los demás tribunales locales para que extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas y de las demás normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de la libertad, en especial en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros.
4. Cualquiera sea el sistema procesal de una provincia y sin desmedro de reconocer su amplia autonomía legislativa en la materia, lo cierto es que si bien no puede llevarse a cabo la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el principio federal cancele por completo el derecho a la igualdad ante la ley, pues un principio constitucional no puede borrar o eliminar otro de igual jerarquía.
5. Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal, se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad.
6. Pese a que la Constitución Nacional no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva, tratándose de una pretensión esgrimida a favor de la totalidad de los detenidos en establecimientos policiales y/o en comisarias superpobladas de la Provincia de Buenos Aires —en el caso, por estar en riesgo su salud y su vida debido a las condiciones de higiene—, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional, con igual o mayor razón la Carta Magna otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla.
7. Es definitiva a los fines del recurso extraordinario, la sentencia del Superior Tribunal de provincia que declaró inadmisibles los recursos de nulidad e

inaplicabilidad de ley por los cuales se cuestionó el rechazo de la acción de hábeas corpus colectivo presentada a favor de la totalidad de los detenidos que se encuentran alojados en establecimientos policiales y/o en comisarias provinciales superpobladas —en el caso, por estar en riesgo su salud y su vida debido a las condiciones de higiene—, ya que pone fin a la acción colectiva pretendida en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional.

8. Existe cuestión federal suficiente a los fines del recurso extraordinario, si la sentencia del Superior Tribunal de Provincia declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley por los cuales se cuestionó el rechazo de la acción de hábeas corpus colectivo presentada a favor de la totalidad de los detenidos alojados en establecimientos policiales y/o en comisarias provinciales superpobladas —en el caso, por estar en riesgo su salud y su vida debido a las condiciones de higiene—, ya que se cuestiona la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional, como así también la violación al art. 18 "in fine" del mismo cuerpo, y a diversas normas contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte del bloque constitucional.
9. Es procedente la interposición de un hábeas corpus colectivo en protección de las condiciones de detención de todos los sujetos privados de libertad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, efectuada por una persona colectiva distinta de los afectados, ya que la peticionaria pretende la modificación de una situación en la que se encuentran quienes están detenidos, respecto del goce de derechos básicos que afectan el respeto a su dignidad humana (del voto en disidencia parcial del doctor Fayt).
10. Siendo que el hábeas corpus colectivo interpuesto por el recurrente apunta a obtener soluciones concretas a las lesiones en los derechos más esenciales de cada uno de los amparados, quienes están alojados en establecimientos policiales y/o en comisarias provinciales superpobladas y cuyas condiciones varían en mucho de un caso a otro, corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que

le acuerda el art. 16, segunda parte, de la ley 48 y, toda vez que la decisión recurrida se limitó a rechazar liminarmente la pretensión, la manera de "sustituir al tribunal apelado" debe circunscribirse a disponer que se le de curso (del voto en disidencia parcial del doctor Fayt).

11. Es deber de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como guardián último de las garantías constitucionales, señalar que la salvaguardia del derecho a la vida de las personas que se encuentran alojados en establecimientos policiales y/o en comisarias provinciales superpobladas, a favor de las cuales se ha interpuesto un hábeas corpus colectivo, podrá formularse ante los jueces competentes para ser atendida con la celeridad y eficacia que la situación requiere (del voto en disidencia parcial del doctor Fayt).
12. Es equiparable a definitiva, a los fines del recurso extraordinario, la sentencia del Superior Tribunal de provincia que declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley por los cuales se cuestionó el rechazo del hábeas corpus colectivo presentado a favor de la totalidad de los detenidos en establecimientos policiales y/o en comisarias provinciales superpobladas —en el caso, por estar en riesgo su salud y su vida debido a las condiciones de higiene—, pues el gravamen que provoca es de imposible e insuficiente reparación ulterior en la medida en que las denunciadas vulneraciones de distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales demandan una tutela judicial efectiva e inmediata que no admite el diferimiento a otro tipo de procesos (del voto en disidencia parcial del doctor Fayt).
13. El examen de constitucionalidad del régimen de la prisión preventiva y la excarcelación vigente en la Provincia de Buenos Aires debe llevarse a cabo exclusivamente sobre la base de las reglas contenidas en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales que vinculan a las legislaturas provinciales (del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).
14. La propuesta de analizar la constitucionalidad del régimen de la prisión preventiva y la excarcelación vigente en la Provincia de Buenos Aires, tomando

como marco normativo obligatorio el Código Procesal Penal de la Nación, importa una severa restricción, del principio federal del art. 1º de la Constitución Nacional, pues, fuera del respeto a la Carta Magna y leyes federales, las provincias no pueden ser obligadas a seguir los criterios legislativos del Congreso Nacional en un tema que no ha sido delegado por las provincias, como lo es la regulación de la excarcelación y la prisión preventiva (del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).

15. Toda vez que en el caso el hábeas corpus interpuesto a favor de la totalidad de las personas detenidas alojadas en establecimientos policiales y comisarías de la Provincia de Buenos Aires importa una impugnación genérica al sistema carcelario provincial, cabe atenerse a la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (del voto en disidencia del doctor Boggiano).

16. La pretensión de modificar el sistema carcelario en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, intentada mediante el hábeas corpus interpuesto a favor de la totalidad de las personas detenidas alojadas en establecimientos policiales y comisarías provinciales, excede las facultades jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (del voto en disidencia del doctor Boggiano).

17. Considerando que no es posible permanecer indiferente ante situaciones incompatibles con la Constitución Nacional y los tratados internacionales y dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado su preocupación por la dolorosa realidad que afecta a las personas privadas de su libertad, ha de urgirse a los poderes de la Provincia de Buenos Aires para que adopten las medidas necesarias, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos (del voto en disidencia del doctor Boggiano).

CS, 2005/05/03. — Verbitsky, Horacio (*).

Dictamen del Procurador General de la Nación:

Considerando: I. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpuso acción de hábeas corpus, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.

Expresó que la superpoblación y el consecuente hacinamiento que deben padecer las personas privadas de su libertad es la nota distintiva de las 340 comisarías que funcionan en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No obstante poseer una capacidad para 3178 detenidos, alojan 6364, según información del mes de octubre de 2001. La situación se agrava en el conurbano, donde 5080 detenidos ocupan 2068 plazas. Los calabozos se encuentran en un estado deplorable de conservación e higiene; carecen por lo general de ventilación y luz natural. La humedad y, en verano, el calor son agobiantes. No cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda la actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso. Los sanitarios no son suficientes para todos y no se garantiza la alimentación adecuada de los reclusos. El riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas es, sin dudas, mucho mayor y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es más que significativo.

Ante esa situación, solicitó que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires asumiera su competencia respecto de ese colectivo de personas para que, luego de comprobar la situación descripta, se pronunciara expresamente acerca de la ilegitimidad, constitucional y legal, del encierro de esas personas en las condiciones en las que se hallan, ordenando el cese de esa situación. A tal fin, requirió el establecimiento de una ins-

(*) Publicado en: LA LEY 2005-E, 39, con nota de Daniel Alberto Sabsay - LA LEY 2005-D, 534, con nota de Marcela I. Basterra; Pedro M. Lorenti (h.) - LA LEY 2005-C, 439, con nota de Roberto José Bolco - LA LEY 2005-C, 276 - DJ 2005-2, 172 - LA LEY 2005-C, 534 - LA LEY 2005-E, 95, con nota de María de los Ángeles Millicic; Víctor R. Corvalán - JA 2005-IV, 612.

tancia de ejecución de la sentencia, en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados, pudiera determinarse —y controlar el Tribunal de Casación— el modo en que la administración pueda hacer efectivo el cese de esas condiciones oprobiosas de detención.

Aclaró que no se pretendía que el órgano jurisdiccional llevara a cabo un análisis acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de los cursos de acción que el Poder Ejecutivo provincial llevara adelante en la materia, pero sí que se sometiera al control de legitimidad legal y constitucional.

En cuanto a la competencia del Tribunal de Casación para conocer de la acción, destacó que la propia jurisprudencia del tribunal —que citó— posibilitaba la deducción directa del hábeas corpus en casación mediando manifiesta importancia o gravedad institucional en la cuestión que se somete a su decisión. Expresó que ante la inobjetable gravedad de la situación denunciada, era imperioso que el Tribunal de Casación se avocara originariamente a su tratamiento y resolviera la problemática de la totalidad de las personas privadas de su libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, dado que, si bien numerosos tribunales locales habían ordenado reiteradamente en los últimos años la clausura de comisarías y centros de detención, las resoluciones parciales así producidas sólo habían generado el movimiento de internos de un lugar a otro, aliviando la situación de unos, pero agravando la de otros, sin que, en definitiva, se dispusiera una solución eficaz al problema del alojamiento.

II. La Sala III del Tribunal de Casación decidió rechazar el hábeas corpus interpuesto con fundamento en que no era competente para entender originariamente en la acción instaurada. Sostuvo que su competencia estaba limitada en la materia al conocimiento del recurso en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 406 y 417 del Código Procesal Penal local. Agregó, además, que el hábeas corpus no autorizaba, en principio, a sustituir a los jueces propios de la causa en decisiones que les incumben, de modo tal que la reparación de las agravaciones en las condiciones de detención denunciadas en la presentación de origen debían encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales, a cuya disposición se hallan los beneficiarios del hábeas corpus. Por último, señaló que no correspondía tomar una única decisión que englobase las situaciones plu-

rales indeterminadas con otros posibles objetivos perseguidos aun cuando estén, de manera significativa, referidos a un problema común. En tal sentido, entendió que la acción planteada apuntaba a cuestionar el sistema carcelario —y su sucedáneo policial como extensión de aquél— en forma genérica, y no a obtener una decisión concreta en casos individuales, los cuales pueden variar mucho entre sí, respecto de lesiones a derechos esenciales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales impugnó la sentencia del Tribunal de Casación a través de los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley previstos en los acápites "a" y "b" del artículo 161, inciso 3, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en los artículos 491 y 494 del Código Procesal Penal local.

En lo que atañe al primero, argumentó que el Tribunal de Casación había omitido el tratamiento de una cuestión esencial, relativa a la gravedad o interés institucional de la situación por la que se solicitaba su intervención, circunstancia ésta que, según la propia jurisprudencia del tribunal, habilitaba a hacer excepción a la regla general según la cual la competencia de ese órgano jurisdiccional se halla limitada al conocimiento sólo por vía recursiva de la acción de hábeas corpus.

A su vez, en lo que hace al recurso de inaplicabilidad de ley, expresó que el Tribunal de Casación había desconocido la posibilidad de accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, contemplada en el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional, al decir que con la acción intentada sólo se apuntaba "a cuestionar el sistema carcelario [...] en forma genérica, y no a obtener una decisión concreta en casos individuales [...] respecto a lesiones de derechos esenciales", al resolver que debía ocurrirse individualmente ante los respectivos jueces a cuya disposición se hallan los beneficiarios del hábeas corpus, y considerar que "las situaciones descriptas por los requerientes se sitúan en un cuadro general de crisis no remediada por la vía intentada".

Invocando en su apoyo jurisprudencia de V.E. sobre la materia, sostuvo que la legitimación para interponer esa acción colectiva derivaba de que su objeto no era la solución de la situación individual de una persona —caso en el que sería ubicua la acción individual—, sino la situación de alcance colectivo de violación por parte del Estado provincial de los estándares jurídicos fijados en materia peni-

tenencia por la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Explicó así que el intento de resolución individual se veía frustrado porque la resolución individual de un caso afectaba necesariamente la situación de las demás personas que padecían la misma situación, generando además evidentes problemas de igualdad. A modo de ejemplo, mencionó que la orden judicial de traslado de una unidad de detención a otra podía aliviar la situación de la primera pero agravar la de la segunda. Y a ello agregó que también hablaban a favor de una acción colectiva razones de economía procesal que la hacían preferible por sobre una multiplicidad de acciones individuales. Por un lado, señaló que encauzar el reclamo por la vía de una acción colectiva permite que la orden judicial al Poder Ejecutivo para que solucione la situación provenga de un único órgano judicial y se refiera a la totalidad del problema. Por el otro, refirió que, dada la gravedad y urgencia de la situación denunciada, la centralización de la cuestión en un solo tribunal evitaría la acumulación de múltiples causas individuales con el mismo objeto y la existencia de decisiones contradictorias, sin mencionar las declaraciones de incompetencia cuando los tribunales inferiores considerasen que el remedio colectivo solicitado excede las potestades judiciales en una causa individual. Concluyó, en síntesis, que todas esas razones militaban a favor de la legitimación colectiva y fundaban la idoneidad de la acción interpuesta que el Tribunal de Casación había desconocido expresamente.

Por lo demás, también argumentó que al ser —por las razones que expusiera— la vía colectiva propuesta la única apta para reparar el agravamiento de las condiciones bajo las cuales se encuentran las personas detenidas en el ámbito de la provincia, la negativa del Tribunal de Casación de abordar la problemática de todos los detenidos en comisarías superpobladas de esa jurisdicción había importado privar de justicia a ese colectivo de personas cuyos derechos se pretendía tutelar, en violación a los artículos 18, 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, así como diversos instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial.

Asimismo, señaló que si se interpretara, por vía de hipótesis, que al declararse el Tribunal de Casación incompetente para conocer originariamente en la acción había des-

cartado implícitamente que el caso configurara un supuesto de gravedad o interés institucional en los términos de su propia jurisprudencia, entonces aun cuando ya no sería procedente el recurso de nulidad, sí lo sería de todos modos el recurso de inaplicabilidad de ley, y ello por resultar el fallo autocontradictorio al reconocer la magnitud del problema planteado y rehusarse, al mismo tiempo, a aplicar la doctrina que el tribunal considera pertinente para casos de esas características.

Por último, con sustento en la doctrina sentada por V.E. en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (LA LEY 1986-B, 476; DJ, 1986-2-2001; LA LEY, 1989-B, 1417), planteó la inconstitucionalidad del artículo 494 de la ley procesal local para el supuesto de que se interpretara esa norma como óbice a la admisibilidad formal del recurso de inaplicabilidad de ley por no ser el resolutorio impugnado uno de aquellos que el precepto menciona como susceptible de ser atacado por esa vía.

Llegadas las actuaciones a conocimiento del la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el a quo, por el voto de la mayoría de sus miembros, declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos.

Para resolver así sostuvo, primeramente, que la resolución del Tribunal de Casación que rechazó la acción de hábeas corpus intentada, por no resultar competente ese tribunal, no encuadraba en los supuestos previstos en los artículos 491 y 494 del Código Procesal Penal de la provincia, que sólo habilitan la procedencia de ambos recursos contra las sentencias definitivas.

Además, sin perjuicio de lo anterior, señaló que en el caso la decisión cuestionada no sólo no cancelaba definitivamente los respectivos procesos principales, sino que ni siquiera hacía lo propio con misma pretensión incoada, en tanto ésta fue sometida a los magistrados a cuya disposición se encuentran los detenidos en cuya representación la acción fue interpuesta.

Por último, expresó que resultaba inadmisibles que la competencia de los tribunales se abriera como consecuencia de una conjetura del recurrente relativa a un supuesto impedimento de solución por parte de los magistrados legalmente habilitados, sin que exista en consecuencia la necesidad de apelar a poderes implícitos que, en todo caso, no podrían ser usados en detrimento de las normas vigentes en tanto éstas permiten que se ven-

tile judicialmente ante quien corresponda la pretensión del recurrente.

Contra este pronunciamiento la actora interpuso el recurso extraordinario federal, cuya denegatoria dio lugar a esta presentación directa.

III. El apelante funda el carácter definitivo de la sentencia impugnada en la circunstancia de que impide la prosecución del procedimiento tal como se lo había planteado, esto es, como acción colectiva. Al respecto, aduce que no es posible sostener, sin incurrir en un claro error conceptual, que la misma cuestión objeto de la presentación puede ser aún debatida —en forma desgarrada— ante cada uno de los magistrados a cuya disposición se hallan los detenidos por quienes se iniciara el hábeas corpus, pues ello implicaría defender la idea errónea de que una acción colectiva es igual a la suma de muchas acciones individuales tramitando separadas. Agrega, una vez más, que el artículo 43 del texto constitucional reconoce legitimación a entidades no gubernamentales como el CELS para accionar en forma colectiva en representación de un grupo o clase de personas que necesitan especial tutela, lo cual desconoce el resolutorio cerrando definitivamente la discusión sobre este tema. Añade, también, que prueba de la conveniencia de encauzar la pretensión en el marco de una acción colectiva y de la falta de equivalencia con la solución individual postulada por el a quo era que habiéndosele dado intervención en el procedimiento a todos los jueces supuestamente competentes, el gravamen que se intenta subsanar no sólo aún subsiste, sino que ha ido aumentando inexorablemente su magnitud, a pesar de haberse clausurado los calabozos de algunas comisarías y haberse trasladado a algunos reclusos de un lugar hacia otro. En tal sentido, informó, con mención de la fuente, una serie de acontecimientos ocurridos con posterioridad al dictado del resolutorio de casación en los calabozos de las comisarías del conurbano bonaerense (motines, muertes, incendios, etc.) que darían cuenta de la situación denunciada no sólo perdura sino que se empeora cada día.

Subsidiariamente manifiesta que, aun cuando se disintiera con la idea de que la cuestión no puede plantearse o renovarse en otro juicio, la resolución del a quo debe ser considerada equiparada a una sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario federal, pues causaría, en todo caso, un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, en tanto los garantías constitu-

cionales afectadas requieren tutela jurisdiccional inmediata ya que una ulterior decisión favorable no podría suprimir los perjuicios ocasionados entretanto por las denigrantes condiciones de detención que los afectados deben padecer, y que ponen en peligro no sólo su integridad física, sino también su vida.

Por lo demás, expresa que al rechazar los recursos extraordinarios locales por considerarlos inadmisibles, el a quo se pronunció, sin embargo, sobre las cuestiones constitucionales controvertidas, pues al señalar que la pretensión debe ventilarse judicialmente ante los magistrados a cuya disposición se encuentran los detenidos por quienes se iniciara la acción, desconoce la posibilidad de accionar colectivamente en el marco de un hábeas corpus correctivo, tal como lo prevé el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional. Asimismo, aduce que, al sostener el a quo que es inadmisibles que la competencia de los tribunales se abra como consecuencia de una conjetura del recurrente, rechazó el planteo de que dicha negativa importa una violación al derecho al acceso a la jurisdicción. Concluye, sobre esta base, que las mismas cuestiones que el CELS intenta someter a conocimiento de V.E. fueron propuestas oportunamente a través de los recursos locales deducidos ante el a quo, tribunal que al rechazarlos se pronunció sobre las mencionadas cuestiones, por lo que cabe tener por fenecida la causa ante el superior tribunal provincial.

Supletoriamente, para el caso de que se entendiera que el a quo se limitó a declarar formalmente inadmisibles los remedios extraordinarios locales, sin pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales controvertidas, sostiene que el recurso extraordinario sería igualmente procedente, pues la negativa a conocer la materia constitucional constituye en sí misma una cuestión federal suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia de V.E. (Fallos 308:490 y 311:2478) invocada oportunamente ante el a quo.

Asimismo, aduce que el a quo también habría incurrido en arbitrariedad, al haber omitido tratar la cuestión relativa a la falta de pronunciamiento del Tribunal de Casación respecto a si existía o no en el caso planteado gravedad institucional, lo cual había sido objeto del recurso de nulidad interpuesto, o bien la autocontradicción que imputó; subsidiariamente, también a ese tribunal para el caso de que se entendiera que su declaración de incompetencia para conocer originariamente en la acción significó descartar im-

plícitamente que el caso configurara un supuesto de gravedad o interés institucional.

IV. A mi modo de ver, el recurso intentado es formalmente admisible, toda vez que el pronunciamiento impugnado proviene del tribunal superior de la causa, y rechaza en forma definitiva la acción con el alcance colectivo que la actora pretende con apoyo en normas de carácter constitucional.

Además, se halla cuestionada la inteligencia del artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional y la resolución ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en esa norma (artículo 14, inciso 3º, de la ley 48).

En lo que respecta a la causal de arbitrariedad invocada por el apelante, estimo que se vincula de un modo inescindible con los temas federales en discusión y, por ello, debe ser examinada en forma conjunta (Fallos 322:3154 y 323:1625).

IV. En cuanto al fondo de la cuestión, considero que asiste razón al recurrente cuando afirma que, por la índole de las cuestiones debatidas y expuestas in extenso en los acápites precedentes, el Centro de Estudios Legales y Sociales se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto por el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional (Fallos 320:690; 323:1339 y 325:524).

Pienso, asimismo, que reconocer a la actora legitimación para representar a los individuos de un colectivo, pero ordenar que el ejercicio de esa representación tenga lugar de manera individual y separada ante cada uno de los jueces a cuya disposición se hallan detenidos, equivale a desvirtuar la previsión constitucional de una acción grupal o colectiva como medio más idóneo para la solución de la controversia en el caso de los derechos de incidencia colectiva.

Por lo demás, también lleva la razón, a mi entender, la actora cuando sostiene que, en atención a la situación denunciada —cuyas características y gravedad tanto el Tribunal de Casación como el propio a quo reconocen—, el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podría incluso perjudicar a los miembros del colectivo.

Por último, y en cuanto la pretensión de que sea el Tribunal de Casación provincial el órgano jurisdiccional que conozca en forma

originaria la acción de hábeas corpus colectiva, observo que el a quo omitió pronunciarse sobre la tacha de arbitrariedad que el recurrente dirigió al fallo del Tribunal de Casación que omitió, a su vez, resolver esa cuestión a pesar de su planteamiento oportuno y con invocación de su propia jurisprudencia. En tales condiciones, la falta de tratamiento y resolución de la cuestión planteada priva al pronunciamiento de fundamentos suficientes que lo sustenten, lo cual lo descalifica en este aspecto como acto jurisdiccional válido (Fallos 321:2243).

V. Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado. — Febrero 9 de 2004. — *Nicolás E. Becerra*.

Buenos Aires, mayo 3 de 2005.

Considerando: 1. Que contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que —por mayoría— declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación Penal provincial, que había rechazado la acción de hábeas corpus interpuesta, en forma directa ante ese tribunal, por Horacio Verbitsky, en su calidad de director del Centro de Estudios Legales y Sociales —en adelante CELS—, a favor de la totalidad de los detenidos que se encuentran alojados en establecimientos policiales superpoblados y/o en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, el accionante interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la presentación de esta queja.

I. Relato de los hechos

1.1. La acción de hábeas corpus

2. Que con fecha 15 de noviembre de 2001 Horacio Verbitsky, en su carácter de representante legal del CELS, interpuso ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires una acción de hábeas corpus correctivo y colectivo en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires detenidas en establecimientos penales y comisarías superpoblados, a pesar de que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.

Indicó que en el territorio provincial funcionan 340 comisarías cuyas instalaciones permiten albergar a 3178 personas, pero que en la realidad alojan 6364; haciendo hinca-

pié en que esta situación se agravaba notablemente en las seccionales del conurbano bonaerense, en las cuales a la fecha de la presentación se hallaban detenidas 5080 personas en celdas que sólo podían cubrir 2068 plazas.

Describió que los calabozos de estas comisarías se encontraban en un estado deplorable de conservación e higiene, que carecían por lo general de ventilación y luz natural, que no contaban con ningún tipo de mobiliario —por lo que toda actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollaban los internos, debía llevarse a cabo en el piso—, que los sanitarios no eran suficientes para todos y que no se garantizaba la alimentación adecuada de los reclusos. Frente a esta situación, sostuvo que el riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas se tornaba mucho mayor, al igual que el aumento de los casos de violencia física y sexual entre los propios internos.

Especificó que los lugares de alojamiento de detenidos provinciales deben respetar reglas mínimas que garanticen los derechos de los reclusos. En ese sentido, indicó que los lugares de alojamiento de detenidos debían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada; condiciones éstas, que el Estado provincial no satisfacía siquiera mínimamente en virtud del hacinamiento denunciado.

Manifestó que estas condiciones de detención incrementaban las posibilidades de poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas, tanto de los detenidos como del personal asignado a la custodia.

Por otra parte, señaló que la situación en las cárceles provinciales no era mejor y que incluso el Poder Ejecutivo provincial había reconocido esta situación al declarar la emergencia físico-funcional del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto 1132/01.

Explicó que muchas personas permanecen detenidas en comisarías, pese a que la Constitución y la ley lo impiden, consignando además, que gran cantidad de los detenidos continuaban en dichas instalaciones pese a haber vencido el plazo que la ley menciona para su alojamiento excepcional, y si bien había sido ordenado el traslado de gran parte de ellos

a unidades penitenciarias, éste no se había hecho efectivo por falta de cupos en éstas.

Refirió que muchas de las personas detenidas en comisarías se encontraban procesadas con prisión preventiva, por lo que su detención debía llevarse a cabo en dependencias carcelarias propiamente dichas, pertenecientes al Servicio Penitenciario, invirtiendo de esta manera los roles del personal policial, que debe garantizar la seguridad de aquéllos, cuando dicha tarea no corresponde a su órbita institucional.

Mencionó especialmente la situación de las mujeres y menores detenidos en establecimientos policiales como una violación flagrante de las normas internacionales que rigen la materia.

En suma, consideró que la situación planteada en los hechos resultaba violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional y de diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional; como así también de las leyes nacionales y provinciales que aseguran y regulan los derechos básicos de las personas detenidas, estableciendo un tratamiento humano y digno tendiente a garantizar el fortalecimiento de la dignidad humana y la inserción social de los procesados y condenados.

Sostuvo que la situación denunciada constituía un caso inobjetable de gravedad institucional que tornaba imperioso el tratamiento por parte de dicha judicatura, para que, mediante su pronunciamiento, se resolviera la problemática de la totalidad de las personas privadas de su libertad en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, dado que, las acciones individuales incoadas ante los tribunales de instancia inferior sólo habían producido resoluciones parciales que aliviaban la situación concreta de algunos, agravando en ciertas ocasiones la de otros, sin que, en definitiva, se dispusiera una solución eficaz al problema del alojamiento y la superpoblación.

En virtud de ello, el accionante consideró que las situaciones descriptas constituirían agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal y por ello hacía procedente la acción en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Sobre tal base solicitó al Tribunal de Casación provincial que asumiera la competencia respecto de la situación de ese colectivo de personas a los efectos de repararla como así también para que se determinara un mecanismo que sea capaz de evitar la reiteración de estas irregularidades en el futuro.

A tal fin requirió el establecimiento de una instancia de ejecución de la sentencia, en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pudiera determinarse el modo en que la administración pueda hacer efectivo el cese de esas condiciones oprobiosas de detención; modo éste que debía ser controlado por el Tribunal.

1.2. El dictamen conjunto del fiscal y del defensor ante el Tribunal de Casación Provincial

3. Que a fs. 23/24 de la presente queja se halla glosada la presentación conjunta efectuada por el fiscal y el defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. En la misma, solicitaron que se declarara admisible la acción de hábeas corpus interpuesta por el CELS.

Coincidieron con el accionante en cuanto a que la situación planteada por éste constituía una violación sistemática y deliberada de las normas protectoras del respeto a la dignidad de la persona. Por ello, entendieron que resultaba insuficiente abordar la problemática en forma aislada, realizando presentaciones ante cada uno de los órganos jurisdiccionales de los distintos departamentos judiciales de la provincia, puesto que con ellas sólo podía lograrse una respuesta parcial o temporal sobre determinados casos, pero que en manera alguna, podía considerarse satisfactoria con respecto a la situación colectiva.

Finalmente, consideraron que el caso revestía gravedad institucional, no sólo porque excedía el interés de las partes, sino también porque comprometía eventuales responsabilidades del Estado Argentino ante los distintos organismos internacionales.

1.3. La sentencia del Tribunal de Casación

4. Que la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires decidió rechazar la acción incoada al considerar que no era el órgano competente para intervenir en los hechos denunciados en la presentación, pues en ésta, se hacía una referencia genérica y colectiva a las distintas situaciones e irregularidades en que se encontraban las personas privadas de su libertad en causas penales y detenidas en comisarías o establecimientos policiales provinciales. Sostuvo que su competencia estaba limitada al conocimiento del recurso de la especialidad, regulado en los arts. 406 y 417 del Código Procesal Penal local, por lo que no era competente para decidir en el caso traído a su conocimiento.

Señaló que no correspondía tomar una única decisión que englobase situaciones plurales indeterminadas, aun cuando estén, de manera significativa, referidas a un problema común. En función de ello, y en tanto la acción interpuesta en forma genérica cuestionaba el sistema carcelario provincial —y su sucedáneo policial como extensión de aquél—, no se dirigía a obtener decisiones específicas para casos concretos, no procedía su consideración puesto que las situaciones individuales podían variar mucho entre sí, en la medida en que podían encontrarse lesionados distintos derechos esenciales. Por este motivo, correspondía que cada supuesto fuera evaluado por el juez propio de la causa.

Finalmente, agregó que la acción de hábeas corpus, no autorizaba —en principio— a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, de modo tal que la reparación de las agravaciones de las condiciones de detención denunciadas en la presentación debía encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales a cuya disposición se hallaban los detenidos.

1.4. Los recursos locales de nulidad e inaplicabilidad de ley

5. Que el CELS impugnó ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la sentencia del Tribunal de Casación a través de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley previstos en la Constitución provincial y en el procedimiento penal local, por considerar que había omitido el tratamiento de las cuestiones planteadas por razones formales de competencia, sin tomar en cuenta la gravedad institucional que los hechos denunciados acarrearaban.

Por otra parte, consideró que la decisión adoptada —en tanto estableció que se debía analizar cada caso concreto de manera individual por los jueces de la causa, lo que obligaba a interponer una acción de hábeas corpus correctivo por cada persona detenida en las condiciones referidas, ante los distintos jueces que entendieran en su causa—, había desconocido la posibilidad de accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, contemplada en el art. 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional.

En este sentido, sostuvo su legitimación procesal activa para accionar en forma colectiva, pues lo que se perseguía con la presentación incoada no era sólo la solución de la situación individual de cada detenido, sino, antes bien, una respuesta concreta al conflicto colectivo que comprometía al Estado pro-

vincial, en virtud de la violación permanente y sistemática de los estándares jurídicos en materia penitenciaria fijados por la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Agregó que los fundamentos dados por el tribunal para justificar su decisión conspiraban contra el principio de economía procesal, puesto que la interposición de una multiplicidad de acciones iba a generar otras tantas sentencias individuales que, incluso, podrían ser contradictorias entre sí, generando evidentes problemas de igualdad; mientras que la acción colectiva permitía el dictado de un único pronunciamiento jurisdiccional referido a la solución de todo el conflicto.

Asimismo resaltó que la negativa a tratar las cuestiones planteadas en la acción colectiva significaba un supuesto de privación de justicia, en tanto que el agravamiento de las condiciones de detención de las personas amparadas continuaba sin repararse, y ello implicaba la continuidad de la vulneración de sus derechos, en franca violación de distintas normas del bloque de constitucionalidad federal.

Por último señaló, que si por vía de hipótesis el Tribunal de Casación provincial al declararse incompetente había descartado implícitamente que en el caso no concurrían circunstancias para que se configurara un supuesto de gravedad institucional, este criterio no sólo no se ajustaba con sus propios pronunciamientos, sino que además, el propio fallo impugnado resultaba arbitrario por autocontradictorio, pues luego de indicar que la vía correspondiente para atender el reclamo era la de la acción individual ante cada juez de la causa donde se verificaran supuestos de agravamiento de las condiciones de detención, "obiter dictum" aparte, el propio juez Mahiques —que conformó la mayoría—, admitió que se trataba de un supuesto de gravedad institucional, reconociendo de esta forma la magnitud del conflicto.

1.5. La sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires

6. Que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, decidió declarar inadmisibles los recursos del accionante. Para resolver de esta manera sostuvo que la resolución impugnada mediante los recursos incoados no revestía carácter de definitiva. Tuvo en cuenta que el pronunciamiento recurrido no sólo no cancelaba definitivamente los respectivos procesos principales sino que ni siquiera hacía lo propio con la misma

pretensión deducida, en tanto ésta fue sometida a los magistrados a cuya disposición se encuentran las personas detenidas amparadas por la acción interpuesta.

Por último indicó que no era inadmisibles desplazar la competencia de los tribunales en detrimento de las normas vigentes, por supuestos que no pasaban de ser una conjetura del recurrente, en la medida que se planteaba la necesidad de un pronunciamiento del Tribunal de Casación provincial, ante la imposibilidad de arribar a una solución del conflicto por parte de los magistrados legalmente habilitados en cada caso concreto.

1.6. El recurso extraordinario federal

7. Que contra este pronunciamiento del tribunal superior local la actora interpuso recurso extraordinario federal. En dicho libelo, el recurrente justificó el carácter definitivo de la sentencia impugnada en la circunstancia de que impide la prosecución del procedimiento por la vía escogida, es decir, como hábeas corpus colectivo.

En este sentido, calificó como error conceptual sostener que la cuestión planteada en el sub judice podía ser debatida individualmente en cada caso ante los magistrados a cuya disposición se hallan detenidos los amparados por el hábeas corpus correctivo incoado, en tanto este razonamiento identifica a la acción colectiva como la suma de muchas acciones individuales tramitadas por separado, vulnerando de esta manera las pautas fijadas por el art. 43 constitucional que legitima a las entidades no gubernamentales para accionar en forma colectiva en representación de un grupo o clase de personas que requieren especial tutela.

De esta manera, a criterio del recurrente, el pronunciamiento impugnado, cerraba definitivamente la discusión sobre el tema, impidiendo el tratamiento de los agravios encauzados en la acción colectiva, que difieren sustancialmente de la solución individual y aleatoria que podría obtenerse en cada caso individual.

Por otra parte, tomando en cuenta la situación denunciada, remarcó que el transcurso del tiempo y la demora que implicaría tratar cada caso en forma particular aumentaba el gravamen que padecen las personas detenidas en condiciones agravadas, incrementando los riesgos contra la vida y la integridad física, tanto de los detenidos como del personal policial y penitenciario de custodia, en virtud de los peligros de crisis violentas que

la situación pudiera generar. En este sentido, sostuvo que el perjuicio que ocasionan las distorsionadas condiciones de detención que sufren los amparados, no sólo subsistan sino que habrían aumentado desde que se interpuso la acción y tendían a empeorar día tras día.

En virtud de ello, manifestó que aun cuando no se compartiera el criterio en torno al carácter definitivo de la sentencia por la conclusión del procedimiento por vía de la acción colectiva, la sentencia de la Corte bonaerense debía ser equiparada a definitiva, en tanto el gravamen que ocasionaba sería de imposible o insuficiente reparación ulterior, y se encontraban comprometidas en el caso garantías constitucionales que requerían de una tutela judicial inmediata, en la medida en que un pronunciamiento ulterior no podría subsanar los perjuicios causados por la demora de su dictado.

Por lo demás, consideró que el tribunal superior provincial al descartar la acción colectiva en favor de las acciones individuales se había expedido sobre la cuestión federal puesta a su consideración, por lo que cabía tener por fenecida la causa en la jurisdicción local.

Finalmente, y en forma supletoria para el caso que se entendiera que en la sentencia recurrida el tribunal a quo se había limitado a declarar formalmente inadmisibles los remedios extraordinarios locales, sin pronunciarse sobre las cuestiones federales involucradas, solicitó que la misma sea revocada no sólo por no cumplir con lo establecido por esta Corte en los precedentes "Strada" y "Di Mascio", sino porque además el pronunciamiento era arbitrario, toda vez que había omitido tratar la cuestión relativa a la falta de pronunciamiento del Tribunal de Casación respecto a si existía o no gravedad institucional en el caso planteado, o en su defecto, de haberse considerado tratada, la autocontradicción imputada a esta sentencia la tornaba arbitraria.

II. El trámite de las audiencias públicas

8. Que esta Corte resolvió, en los términos del art. 34, inc. 4°, ap. a, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación convocar a las partes a dos audiencias públicas, que se llevaron a cabo el 1° de diciembre del pasado año y el 14 de abril del corriente.

En las mismas, tanto el CELS como el Poder Ejecutivo provincial presentaron sus inquietudes y aportaron escritos en los que sostuvieron sus respectivas posiciones.

9. Que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires proporcionó un informe que da cuenta del estado de situación en materia de personas privadas de la libertad en el ámbito territorial de la provincia, y también del programa de medidas propiciado por esa cartera para solucionar el conflicto.

De aquél, se desprende la existencia de un incremento notable (296,70%) en la cantidad de detenidos procesados por la justicia local desde el año 1990 —acentuándose desde 1998—, los que representan el 75% del total de las personas privadas de su libertad.

Por otra parte, también consta que la situación de las cárceles provinciales es crítica en materia de capacidad de alojamiento, habiéndose dispuesto por ello la imposibilidad de incorporación de nuevos detenidos por la resolución ministerial 221/04.

Se anexó un programa de reformas y ampliación del patronato de liberados, que lo posicionaría como una alternativa al encierro; la adquisición de un mayor número de pulseras magnéticas, y el impulso para la construcción de nuevas cárceles y alcaldías.

Por lo demás, se reconoció la superpoblación del sistema carcelario, la existencia de personas detenidas en comisarías bonaerenses —pese a la implementación del programa de traslado de detenidos a unidades del servicio penitenciario—; que la mayoría de los detenidos son procesados y que los juicios son lentos, y los inconvenientes para solucionar de manera definitiva la situación en el corto plazo en virtud de la profundidad y los alcances de la crisis económica que afectó al Estado Nacional y provincial.

También se indicó que, para determinar las condiciones de alojamiento de los detenidos, resultan aplicables las "Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el 1° Congreso de la Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente". Asimismo se reconoció que existe un abuso en la utilización del instituto de la prisión preventiva, el cual, sumado a la demora en la tramitación de los juicios, agregaba en las cárceles y comisarías una cantidad adicional de detenidos. Por este motivo puso en conocimiento de este Tribunal que se había elaborado un proyecto de ley de control de cupo penitenciario, a los efectos de dotar de un mecanismo de corrección de las situaciones de detención que no se ajusten a las reglas internacionales, como así también de un sistema de comunicación con los jueces a cuya disposición se encuentren los deteni-

dos que estén en condiciones de obtener su libertad o de ser incluidos en un régimen atenuado o alternativo de la prisión.

Finalmente propuso la introducción de medidas de oportunidad e instancias de mediación penal para solucionar estos inconvenientes, pero que aún no fueron aprobadas legislativamente.

10. Que la parte actora puso en conocimiento del tribunal que en los tres años transcurridos la situación descrita en la acción originaria, no sólo no se había modificado sino que se había incrementado.

Al respecto, mencionó que la cantidad de personas privadas de su libertad por la justicia provincial había crecido de 23.264 en noviembre del año 2001, a 30.414 para el mismo mes del año 2004, lo que implicaba un incremento del 31% en el término de tres años.

Del mismo modo indicó que —según datos suministrados por el propio servicio penitenciario de la provincia—, pese a haberse construido en el lapso señalado ut supra 6810 plazas carcelarias, continuaban detenidas en comisarías 5441 personas a julio del pasado año.

Con respecto a las condiciones de detención en las cárceles de la provincia, indicó que, a septiembre del pasado año, la distorsión de plazas oscilaba entre las 7700 y las 10.114 de acuerdo con los diversos mecanismos utilizados para medirla. Este dato ponía de relieve que la cantidad de personas alojadas en las dependencias penitenciarias provinciales excedía en más del 30% la capacidad máxima prevista, llegando incluso —según otras mediciones— al 50% de superpoblación.

Cuestionó las medidas llevadas a cabo por la provincia por cuanto ellas no habían tenido como resultado una variación sustancial de la situación, agregando a su vez, que algunas de las circunstancias se habían agravado en el último tiempo. En este sentido consideró que las propuestas del Estado provincial eran insuficientes e inidóneas para resolver las dificultades planteadas.

Consideró que las propuestas referidas al fortalecimiento del Patronato de Liberados y la adquisición de pulseras magnéticas, no tendrían un impacto sustancial sobre el problema del hacinamiento. Finalmente sostuvo que la superpoblación y las condiciones de detención continuaban agravándose como así también que había aumentado la

cantidad de detenidos en dependencias policiales.

Sostuvo que la autoridad provincial consideraba que el hacinamiento padecido por los presos obedece —como regla general— a la escasez de espacio, motivo por el cual la solución al problema se reduciría a la construcción de nuevos lugares de detención, sin tomar en cuenta el aumento de la tasa de prisionización provocado por las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales provinciales, dispuestas en los últimos seis años.

Así refirió que "el alojamiento ilegal de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario se ha ido consolidando en la Provincia de Buenos Aires como una componente de las condiciones de privación de la libertad en los últimos años. Esto más allá de la permanente construcción de establecimientos penitenciarios y otras medidas que se hayan intentado... Una serie de políticas públicas en materia criminal, que ubicaron a la cárcel como principal herramienta de solución de los conflictos sociales, han provocado que la provincia de Buenos Aires esté cerca de las tasas de encarcelamiento cada 100.000 habitantes más alta de la región. Con 220 para el 2004 esta tasa solo es superada por Chile. Sin embargo su nivel de crecimiento ha sido superior no sólo al de Chile sino inclusive a los niveles de incremento de la tasa de prisionización en los Estados Unidos de América. Los datos señalan que una serie de acciones llevadas a cabo desde los poderes ejecutivo provincial, reformas legislativas y decisiones judiciales han sido unas variables fundamentales del incremento de los niveles de privación de la libertad y de las condiciones en que ésta se cumplen en dependencias policiales y penitenciarias. Entre otras cosas, las modificaciones introducidas en la normativa provincial promovieron: a) restringir al máximo los supuestos de libertad durante la sustanciación del proceso, invirtiendo el principio de excepcionalidad de la privación de libertad cautelar, y b) limitar el acceso a regímenes de ejecución de penas alternativos al encierro carcelario a cada vez más supuestos específicos, retomando la concepción de que los institutos pre-liberatorios constituyen 'beneficios penitenciarios' en lugar de modalidades de cumplimiento de condenas. Las decisiones de política criminal en la provincia de Buenos Aires están orientadas a promover, sin que la ilegalidad de las privaciones de la libertad actúe como límite, más privación de

283

libertad tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, es decir, más presos detenidos por lapsos cada vez más prolongados" (confr. fs. 256 vta.).

De esta manera mencionó que en los últimos seis años las reformas legislativas introducidas en el ordenamiento procesal local por las leyes provinciales 12.405 y 13.183 —que modificaron la regulación en materia de encarcelación—, como así también las modificaciones efectuadas a la legislación bonaerense de ejecución penal mediante la sanción de la ley 13.177, trajeron aparejadas un significativo aumento en la cantidad de personas privadas de su libertad en el ámbito local.

Asimismo señaló que, en virtud de estas reformas legislativas, se incrementó significativamente el número de condenas de prisión o reclusión por más de 3 años, pasando del 20% del total de condenas pronunciadas en 1998, al 31,4% en el año 2003.

Sin perjuicio de ello, refirió que igualmente la situación más grave de aumento de detenidos se vincula con detenciones durante el curso de los respectivos procesos, puesto que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad aún no tienen condena firme.

III. Las presentaciones de los amicus curiae

11. Que en el trámite del recurso interpuesto ante esta Corte, fueron anexadas al expediente las presentaciones en carácter de amigos del tribunal, articuladas por la "Comisión Nacional de Juristas", la Organización "Human Rights Watch", la "Organización Mundial contra la Tortura", la "Asociación por los Derechos Civiles", la "Clínica Jurídica de Interés Público" de Córdoba, la Asociación Civil "El Agora", la Asociación Civil "Casa del Liberado" de Córdoba, y el "Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal".

En ellas, los organismos mencionados aportaron argumentos de derecho y jurisprudencia internacional relacionados con el caso en estudio para conocimiento de esta Corte.

IV. Dictamen del señor Procurador General de la Nación

12. Que llegada la presentación directa a conocimiento de este Tribunal, con fecha 29 de agosto de 2003 se dispuso dar vista al señor Procurador General de la Nación, quien con fecha 9 de febrero de 2004, emitió el dictamen obrante a fs. 99/104 de los presentes actuados, opinando que correspondía declarar procedente la queja, hacer lugar al recur-

so extraordinario y, en consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento apelado.

Para así dictaminar, consideró que el recurso es formalmente admisible, puesto que el fallo impugnado proviene del tribunal superior de la causa, y además, rechaza en forma definitiva la acción con alcance colectivo que la actora pretende con apoyo en normas de carácter constitucional.

Agregó, que en el sub lite se halla cuestionada la inteligencia del art. 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional; y la resolución impugnada había sido contraria al derecho en que el recurrente fundó su planteo. Asimismo, estimó, que el tratamiento de la arbitrariedad del pronunciamiento apelado, no podía escindirse del conferido a la cuestión federal controvertida en el pleito.

En cuanto a los aspectos de fondo planteados, consideró que asistía razón al recurrente en cuanto sostuvo que se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas privadas de su libertad en el ámbito provincial a las que se les habían agravado las condiciones de detención.

Destacó que esta legitimidad se desprende de la inteligencia que cabe asignarle al párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional, y en este sentido, tomando en cuenta que la pretensión del accionante tiene por objeto obtener una solución que abarque la totalidad de los casos que se encuentran en la misma situación, el razonamiento efectuado por el tribunal a quo en la medida en que impide el progreso de la acción colectiva, desvirtúa el alcance otorgado por la cláusula constitucional mencionada.

Por lo demás, compartió el criterio de la actora en lo que se refiere a que la acción colectiva resultaba el remedio procesal apto para solucionar la situación denunciada, toda vez que el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podía incluso perjudicar a los miembros del colectivo.

Finalmente, coincidió con la recurrente en que la falta de tratamiento de cuestiones planteadas e invocadas oportunamente en la sentencia del tribunal inferior en grado, tornaban arbitrario el pronunciamiento, dado que no cuenta con fundamentos suficientes que sustenten esta carencia, descalificándolo entonces como acto jurisdiccional válido.

V. Procedencia del recurso extraordinario

13. Que el recurso extraordinario, tal como lo manifestara el señor Procurador General

de la Nación, resulta formalmente procedente puesto que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley 48.

Ello es así puesto que la sentencia impugnada fue dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que reviste en el caso el carácter de superior tribunal de la causa.

Dicho pronunciamiento es definitivo, pues pone fin a la acción colectiva pretendida por la recurrente en los términos pautados por el art. 43 constitucional. Por otra parte, en cualquier caso sería equiparable, pues el gravamen que provoca el objeto de la acción y que perjudicaría a todos los detenidos en establecimientos policiales de la Provincia de Buenos Aires —representados por la actora— es de imposible e insuficiente reparación ulterior, denunciándose como vulneradas distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la Constitución Nacional, como así también en diversos instrumentos internacionales incorporados a ella en virtud de la recepción establecida en el art. 75, inc. 22, que demandan tutela judicial efectiva e inmediata.

Asimismo existe cuestión federal suficiente pues se cuestiona la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional, como así también la violación al art. 18 in fine del mismo cuerpo, y a diversas normas contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional.

A mayor detalle, cabe destacar que al hallarse cuestionadas garantías del derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional.

Por lo demás, la resolución ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en esas normas, el agravio subsiste al momento de fallar y existe relación directa e inmediata entre el planteo realizado, la sentencia impugnada y las cláusulas constitucionales invocadas.

VI. El "hábeas corpus" colectivo.

14. Que según consta en autos, en sus recursos ante la Corte provincial el CELS impugnó la interpretación del artículo constitucional 43 que hizo la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto al resolver que se debía accionar caso por caso desconoció la posibi-

lidad de hacerlo en beneficio de intereses colectivos.

En consecuencia, al introducir sus agravios en la instancia extraordinaria federal, la parte recurrente sostuvo que la denegación de la acción intentada con fundamento en que ésta debía ejercerse ante cada uno de los magistrados a cuya disposición se encuentran detenidos sus amparados, vulnera el derecho a promover acciones en forma colectiva reconocido en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional.

15. Que es menester introducirnos en la cuestión mediante el estudio de la cláusula constitucional en crisis, a fin de especificar el alcance de lo allí dispuesto, esto es, si sólo se le reconoce al amparo strictu sensu la aptitud procesal suficiente para obtener una protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva, o si, por el contrario, se admite la posibilidad de hacerlo mediante la acción promovida en el sub judice.

16. Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo; con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla.

17. Que debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (Fallos 312:2192, disidencia del juez Petracchi; 320:875, entre otros).

18. Que este Tribunal —en una demanda contra la Provincia de Buenos Aires articulada en función de su competencia originaria, promovida a raíz de la muerte de 35 detenidos alojados en la cárcel de Olmos— ya había advertido que "si el estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más,

indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa" (Fallos 318:2002).

19. Que no se trata en el caso de discutir cuestiones importantes pero no esenciales, como el exactísimo cubaje de aire, dos o tres grados más o menos de temperatura u horarios de recreos y provisión de trabajo carcelario, media hora más o menos del horario de visitas, etc., sino que lo denunciado y lo admitido oficialmente como superpoblación carcelaria genera muy serios peligros para la vida y la integridad física de personas incluso ni siquiera involucradas en los potenciales conflictos.

VII. Los hechos no controvertidos en el caso y las propuestas del Estado provincial.

20. Que el marco excepcional y acotado previsto para el tratamiento de agravios federales por vía del recurso regulado por el art. 14 de la ley 48, impide a este Tribunal examinar y analizar situaciones que se vinculen con cuestiones de hecho y prueba, justamente para no desnaturalizar su contenido, ni alterar irracionalmente la función de esta judicatura.

21. Que en virtud de lo expuesto, no es posible verificar en el caso concreto algunas de las situaciones planteadas, puesto que requieren de medidas de prueba que no corresponden a esta instancia. Ellas, indefectiblemente son de competencia de los jueces propios de las causas a cuya disposición se encuentran las personas detenidas, quienes tienen, por expreso imperativo constitucional, la obligación de comprobarlas y, en su caso, de adoptar las medidas necesarias para corregirlas.

22. Que muchas de estas situaciones, vinculadas con el espacio, la aireación, la alimentación, la iluminación, las instalaciones sanitarias, la recreación y la asistencia médica —si bien la experiencia común en la conflictividad global en que se enmarcan llevaría en principio a admitirlas como ciertas en general—, seguramente varían en cada lugar de detención y para cada caso individual, por lo que requieren un tratamiento específico, reservado *prima facie* a los jueces provinciales.

23. Que sin embargo, existen hechos no controvertidos en las actuaciones que surgieron en el marco del trámite de las audiencias públicas, y que esta Corte no puede dejar de

considerar, pues corresponden a una situación genérica, colectiva y estructural y, además, quedan fuera de las cuestiones probatorias, pues, como se ha destacado, fueron admitidos por el gobierno provincial con encomiable sinceridad.

24. Que no se ha puesto en discusión la superpoblación de detenidos, tanto en las instalaciones del servicio penitenciario, como en las dependencias policiales provinciales. Esta superpoblación, en los niveles alcanzados y admitidos, de por sí acreditan que el Estado provincial incumple con las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad.

Por otra parte, tampoco se puso en duda que se encuentran alojados en comisarías en calidad de detenidos adolescentes y personas enfermas.

También ha sido reconocido que, por los menos, el 75% de la población privada de su libertad son procesados con prisión preventiva que todavía no han sido condenados, y por lo tanto gozan de la presunción de inocencia.

Finalmente, está dicho y no controvertido en autos que si bien la cantidad de detenidos en la provincia ha aumentado año a año desde 1990, en los últimos seis años ha alcanzado un incremento exponencial que no guarda relación de proporcionalidad alguna ni con el aumento demográfico de la población ni con el aumento de los índices delictivos en la provincia.

25. Que no compete a esta Corte evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, ni poner en discusión su política penitenciaria y, menos aún, su política criminal en la parte en que le compete, como tampoco podría hacerlo ni siquiera respecto del Estado Federal. La valoración de las medidas que el Estado provincial comunica haber adoptado y que fueran expuestas en las audiencias públicas, solicitando que se incorporaran a las actuaciones, no son materia que deba evaluar esta Corte en cuanto a su acierto o conveniencia, más allá de considerar que acreditan el esfuerzo del Estado provincial respecto del problema.

26. Que reconoce la actora que la actuación judicial tiene sus límites y que en materias tales como la presente no puede imponer estrategias específicas, sino sólo exigir que se tengan en cuenta las necesidades ignoradas en el diseño de la política llevada a cabo. En

consonancia, acepta que no se trata de que la Corte Suprema defina de qué modo debe subsanarse el problema pues ésta es una competencia de la Administración, en tanto una Corte Constitucional fija pautas y establece estándares jurídicos a partir de los cuales se elabora la política en cuestión.

Como consecuencia de admitir como impracticable una solución total e inmediata a la pretensión y que la obligación estatal está compuesta por múltiples y variadas cargas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo, pide se establezcan instancias de ejecución en las que a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pueda determinarse el modo en que podrá hacerse efectivo el cese de la inapropiada detención de personas.

Efectivamente, las políticas públicas eficaces requieren de discusión y consenso.

En tal contexto y en el marco de lo que aquí se decide, es prudente implementar un criterio de ejecución que en justo equilibrio y con participación de la sociedad civil, contemple los intereses en juego y otorgue continuidad al diálogo ya iniciado con el propósito de lograr el mejoramiento de las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires.

Por ello, se estima procedente que esta Corte encomiende a la Provincia de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una Mesa de Diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como *amicus curiae*, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil que puedan aportar ideas y soluciones y que en un ámbito de discusión facilitada permita arribar a soluciones consensuadas y sustentables.

27. Que a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judicial, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias.

Ambas materias se superponen parcialmente cuando una política es lesiva de derechos, por lo cual siempre se argumenta en contra de la jurisdicción, alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la política, cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judi-

cial, en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona. Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad.

No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas.

28. Que en este sentido, si bien resultan atendibles algunas de las razones expuestas por el Poder Ejecutivo provincial, en cuanto a la carencia de recursos económicos para solucionar en el corto plazo los problemas planteados, este Tribunal ya se ha pronunciado sobre el particular indicando que "estas dolorosas comprobaciones, que es deber del Tribunal destacar, no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias que se traducen en la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del personal o las consecuentes excesivas poblaciones penales" ... "Las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica internacional, receptados en el texto actual de aquella (art. 5°, inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)" (Fallos 318:2002).

29. Que en consecuencia, se plantea como disyuntiva, qué circunstancias ponderar al momento de decidir; pues no resulta sencillo determinar en qué medida el fallo que se dicte, según el temperamento escogido y su fuerza ejecutoria, pueda contribuir a solucionar el conflicto, manteniendo el equilibrio y el respeto armónico que los principios republicano y federal demandan, como así también para garantizar el funcionamiento co-

recto de las instituciones y sus objetivos, sin sacrificar en aras de ellos otros derechos y deberes.

30. Que por este motivo, reconociendo la gravedad de la situación, los peligros que avizora y las dificultades que genera encontrar una solución en esta instancia, y con el marco acotado que proporciona el tratamiento del recurso extraordinario, fue que este Tribunal decidió convocar a las partes a sendas audiencias públicas, para tratar de encontrar en esa instancia de diálogo una propuesta consensuada y viable que permitiera allanar el camino para superar el conflicto.

31. Que no obstante ello y luego de realizadas las audiencias, esta propuesta consensuada no se ha vislumbrado, y la gravedad del caso impide seguir demorando el dictado de una sentencia, tomando en cuenta que el proceso ya lleva más de cuatro años de trámite sin que las medidas que se han adoptado para remediarlo hayan tenido eficacia. El Poder Ejecutivo provincial expuso una serie de esfuerzos que demuestran su empeño, pero que no resuelven la situación, precisando incluso que esto se debe al accionar de otros poderes del Estado provincial. Lo cierto es que parece que la situación se mantiene y se agrava con el aumento de detenidos informado por el Poder Ejecutivo provincial y se proyecta hacia el futuro inmediato con perspectivas de mayor gravedad. Se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen, lo que impide hacer cesar la violación de derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida y a la integridad personal de los presos, del personal de custodia y de terceros.

La experiencia corriente y técnica, y el sentido común indicarían que de seguir esta proyección, en el corto tiempo, el Estado provincial tampoco podría continuar su actual empeño, por obvias razones presupuestarias y políticas, o sea, porque se vería en la disyuntiva de continuar construyendo celdas indefinidamente o de atender otros requerimientos necesarios para el bienestar general (salud, educación, higiene pública, pavimentos, caminos, etc.). Esta perspectiva sería aun más peligrosa para los derechos que hoy se hallan comprometidos con las actuales condiciones de detención, pues se agravarían aun más y abarcarían a un número mayor de personas.

32. Que en el curso de las audiencias ha sido establecido, sin controversia alguna: a) el

cuadro de situación señalado en el considerando 24; b) que hay menores y enfermos en comisarías; c) que los esfuerzos del Poder Ejecutivo provincial no alcanzan para resolver el problema porque no cede la curva ascendente del número de presos en la provincia; d) que este aumento responde básicamente a leyes provinciales en materia excarcelatoria y penitenciaria; e) que también el Poder Ejecutivo provincial considera que media un excesivo uso de la prisión preventiva por parte de los jueces de la Provincia de Buenos Aires.

33. Que frente a esta situación, al momento de definir las distintas alternativas a adoptarse y en el marco de su competencia corresponde que esta Corte adopte las medidas posibles y para ello es menester explorar esas posibilidades con referencia a los señalados puntos.

VIII. El cuadro de situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires y las posibles medidas de competencia de esta Corte.

34. Que el art. 18 de la Constitución Nacional al prescribir que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice", reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. El alcance de este texto ha sido puesto en discusión, dudándose si abarcaba a los condenados, pues tiene un claro origen histórico iluminista referido a la prisión cautelar, como que parece provenir de Lardizábal: "Aunque la cárcel no se ha hecho para castigo, sino para custodia y seguridad de los reos..." (Discurso sobre las penas contrahído a las leyes criminales de España, para facilitar su reforma, Madrid, 1782, pág. 211, ed. con estudio preliminar de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Fundación Sancho El Sabio, Vitoria, 2001). Sin embargo, ha quedado superada la discusión después de la reforma constitucional de 1994, en cuanto a que los fines reintegradores sociales de la pena de prisión están consagrados en virtud del inc. 22 del art. 75 constitucional, y, además, en el caso se refiere al 75% de los amparados, que son presos cautelares.

35. Que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave

indebidamente. "Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal" (Nuñez, Ricardo; Dcho. Penal Argentino, Parte Gral. Tomo II; Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960).

36. Que este Tribunal ha expresado: "Que un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los derechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral". "La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario" (Fallos 318:2002).

37. Que la situación no controvertida de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires pone en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario y policial, además de que genera condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo de esos funcionarios y empleados.

Una prisión es un establecimiento en el que hay un fino equilibrio entre presos y personal, y la superpoblación provoca descontrol y violencia llevando ese equilibrio siempre precario al límite de la fragilidad.

A ello cabría agregar que el personal policial, por su entrenamiento, no está prepara-

do para cumplir esta función que no es la específica de su tarea social.

38. Que también genera peligro para la vida de terceros ajenos al conflicto, pues en no pocas ocasiones han padecido consecuencias lamentables vecinos de los lugares de detención o de las mismas cárceles amotinadas e incluso familiares sorprendidos por los acontecimientos en el interior de los establecimientos. También se vuelve peligroso para el propio personal judicial, habiéndose registrado casos de jueces tomados como rehenes. Todo ello sin contar con que la distracción de personal policial de sus funciones específicas resiente considerablemente el servicio de seguridad pública, con el consiguiente riesgo para la prevención secundaria de delitos de gravedad.

39. Que el derecho a un trato digno y humano reconocido a las personas privadas de su libertad no sólo encuentra soporte en nuestra Constitución Nacional desde 1853, sino que ha sido reconocido desde los orígenes mismos de la legislación penitenciaria del país y especialmente de la propia Provincia de Buenos Aires, en cuyo Reglamento Provisorio de la Penitenciaría de 1877, sancionado por el gobernador Carlos Casares, establecía un régimen respetuoso de la dignidad humana sensiblemente notable para los estándares de su tiempo (Reglamento Provisorio de la Penitenciaría, Buenos Aires, Imprenta de M. Biedna, calle de Belgrano número 135, 1877).

La República Argentina tuvo un papel protagónico en el establecimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, en el Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, de Ginebra, en 1955, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C31-7-57 y complementada en la 2076 del 13 de mayo de 1977. Después de la reforma de 1994, con jerarquía constitucional, la Nación está obligada por tratados internacionales de vigencia interna y operativos, que fortalecen la línea siempre seguida por la legislación nacional en la materia: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. XXV que "todo individuo tiene también un tratamiento humano durante la privación de su libertad"; el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que "toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"; fórmula ésta que recepta de modo similar el art. 5 inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas —si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal— se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado en la Provincia de Buenos Aires.

40. Que ante esta situación es indudable que esta Corte no puede resolver todas las cuestiones particulares que importa, dadas las dificultades antes señaladas y el número de casos y variables posibles, pero es su deber instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que en sus respectivas competencias extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las Reglas Mínimas y de las normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, en especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros.

41. Que no escapa a esta Corte que de verificarse algunos de los extremos mencionados por el accionante, sería posible que se configuraran eventuales casos de agravamientos que importarían trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad al Estado Federal. En esta eventualidad, es deber de esta Corte, por estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado Federal, instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda.

IX. Adolescentes y enfermos en dependencias policiales, y la jurisprudencia internacional

42. Que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarías o establecimientos policiales, configura con gran certeza uno de los supuestos contemplados en el considerando anterior, con flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas citadas y muy probablemente innegables casos de trato cruel, inhumano o degradante. Esta Corte, en virtud del alto riesgo de responsabilidad internacional que de ello se deriva para el Estado Federal, debe disponer, sin dilación, que en un plazo perentorio, la Su-

prema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por las vías procedentes, haga cesar esas situaciones. Respecto de los niños y adolescentes, la presencia en comisarías resulta, además de intolerable, sospechosa respecto del índice de institucionalizados de la provincia, materia en la que sería terrible que se produjera una escalada análoga al número de presos, cuando es sabido el efecto reproductor que tiene la institucionalización de menores, además de responder a una ideología tutelar incompatible con la normativa internacional vigente.

43. Que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de modo mucho más específico sobre cuestiones similares a las que motivan este hábeas corpus correctivo, al analizar las violaciones de diversos derechos de la Convención Americana, en virtud de las condiciones de detención en el Establecimiento "Panchito López" en el Paraguay, que resultan de ineludible exposición (CIDH caso "Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay", el 2 de septiembre de 2004).

En dicho caso el tribunal internacional tuvo por probado que el crecimiento de la población carcelaria, originó serios problemas de hacinamiento e inseguridad entre los internos de dicho instituto paraguayo. Los internos se encontraban reclusos en celdas insalubres con escasas instalaciones higiénicas; mal alimentados y carecían de asistencia médica psicológica y dental adecuada. Los internos que sufrían discapacidades físicas, enfermedades mentales y/o problemas de adicciones, no disponían de una atención médica acorde con las necesidades especiales. Contaban con pocas oportunidades de hacer ejercicio o de participar en actividades recreativas. Muchos de los internos no tenían camas, frazadas y/o colchones, con lo cual se vieron obligados a dormir en el suelo, hacer turnos con sus compañeros o compartir camas y colchones. La falta de camas y colchones, junto con el hacinamiento, facilitaron que hubiera abusos sexuales entre los internos. También sostuvo que a pesar de que el nuevo código procesal paraguayo establecía que la prisión preventiva es la excepción a la regla que es la libertad, "la implementación de esa norma no se llevó a cabo por completo, pues la mayoría de los internos se encontraban procesados sin sentencia". Además los internos procesados sin sentencia no estaban separados de los condenados en el Instituto.

Respecto al hacinamiento consideró que fomentaba la desesperación y las tendencias hacia la violencia de los internos, y que "en

vez de ser rehabilitados en el Instituto para una reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos fueron sometidos a sufrimientos diarios y por lo tanto, a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual, en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los mismos". Como consecuencia de tal estado de hacinamiento se produjeron varios incendios que el Instituto no estaba en condiciones de repeler, ocasionado la muerte de algunos de ellos.

En tal contexto, la Corte Interamericana interpretó los derechos y garantías previstos en el art. 5 de la Convención, el que establece en lo conducente que:

1. "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral".

2. "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

3. "La pena no puede trascender de la persona del delincuente".

4. "Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas".

5. "Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento".

6. "Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados".

44. Que el tribunal interamericano señaló que "quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal, y que es el Estado el que se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una se-

rie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.

45. Que, en cuanto al derecho a la integridad personal, el tribunal señaló que es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia. Agregó que el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el art. 1.1 de la Convención Americana.

46. Que, específicamente en lo referente a los menores, la Corte Interamericana ha analizado la cuestión a la luz del art. 19 de la Convención Americana, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 54 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párr. 54 ("Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay" op. cit.).

Allí consideró que tales instrumentos y la Convención Americana conformaban un plexo normativo, el corpus juris internacional de protección de los niños. El tribunal señaló que cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el art. 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño, particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad.

47. Que, respecto a los presos sin condena, en el mencionado precedente la Corte Interamericana recordó que la prisión preventiva "es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de

inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática" (párrafo 190). Por tales razones consideró que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el art. 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos (párrafo 228).

Sin embargo, al pronunciarse sobre si en el caso paraguayo se había violado el art. 7 del Pacto —que regula las condiciones de la prisión preventiva— consideró que era preciso conocer las particularidades de la aplicación de la prisión preventiva a cada interno para poder analizar si se ha cumplido con cada uno de los extremos señalados por el mismo. Razon por la cual señaló que aunque "la Corte frecuentemente ha utilizado la existencia de patrones o prácticas de conductas como un medio probatorio para determinar violaciones de derechos humanos, en el caso del artículo 7 de la Convención Americana se requiere una información individualizada al respecto de la que carece la Corte en el presente caso" (párrafos 232 y 233), descartando de tal manera declaraciones genéricas o abstractas, y precisando que no podía pronunciarse respecto de presuntas víctimas específicas por carecer de elementos.

48. Que el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que "toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Por su parte los Principios básicos elaborados por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos expresa que "con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos..." (aprobado por Asamblea General, resolución 45-111 del 14 de diciembre de 1990, ap. 5°).

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión prescribe que "Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes. No podrá invocarse

se circunstancia alguna como justificativo para la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Principio Sexto, Asamblea General Resol. 43/173 del 9 de diciembre de 1998).

Por su parte las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos expresan que "Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser reclusos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separados de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos (arts. 8 y 9 aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus res. 663 C 31-7-57 y 2076-13-5-77).

49. Que respecto a los niños, y en igual sentido, la regla 13.5 de 1997 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establece que: "No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad". Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen que: Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria —social, educacional, profesional, psicológica, médica y física— que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.

50. Que también resultan importantes, sobre el agravamiento de las condiciones de detención la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), del 9 de diciembre de 1975), la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos

o Degradantes (Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984), así como las Observaciones del Comité Derechos Humanos respecto Las Torturas y las Penas o Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (art. 7 del 30 de julio de 1982); Trato Inhumano de las Personas Privadas de su libertad (art. 10) del 30 de julio de 1982 Observación General n° 9 del 10 de abril de 1992, la Observación n° 20 y 21 del 10 de abril de 1992, entre otras.

El 15 de noviembre de 2004, Argentina, se convirtió en el sexto país en ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (Naciones Unidas, Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, General 22 de noviembre del 2004 CAT/C/SR. 622, párrafo 6).

Interpretando dicha convención, recientemente las Naciones Unidas, a través del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes dictó "sus Conclusiones y Recomendaciones", respecto del caso Argentino el 10 de diciembre de 2004 (CAT/C/CR/33/1 33° Período de Sesiones 15 a 26 de noviembre de 2004).

Allí señaló los "Factores y dificultades que obstaculizan a aplicación de la Convención" para lo cual tomaba "nota de las dificultades a las que se enfrenta el Estado Parte, especialmente aquellas de tipo económico y social". No obstante, señaló "que no existen circunstancias excepcionales de ningún tipo que puedan invocarse para justificar la tortura". Al establecer las cuestiones que eran motivos de especial preocupación para la situación argentina enumeró entre otras las siguientes:

1. d) La no implementación uniforme de la Convención en las diferentes provincias del territorio del Estado Parte, como asimismo la ausencia de mecanismos para federalizar las disposiciones de la Convención, aun cuando la Constitución del Estado Parte les otorga rango constitucional.

2 (f) Los informes de arrestos y detenciones de niños por debajo de la edad de responsabilidad penal, la mayoría "niños de la calle" y mendigos, en comisarías de policía donde llegan a estar detenidos junto a adultos, y sobre las supuestas torturas y malos tratos padecidos por éstos, que en algunos casos les produjeron la muerte.

3 (h) El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los estable-

cimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados médicos apropiados, que podrían equivaler a tratos inhumanos y degradantes.

4 (i) El elevado número de presos en prisión preventiva, que en el sistema penitenciario bonaerense alcanza un 78% según el Estado Parte.

5 (j) La no aplicación del principio de separación entre condenados y procesados en centros de detención, y entre éstos y los inmigrantes sujetos a una orden de deportación.

6 (m) La falta de independencia del personal médico de los establecimientos penitenciarios, quienes pertenecen a la institución penitenciaria.

A partir de ello el Comité fijó, entre otras, las siguientes recomendaciones:

1 (d) Garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una aplicación uniforme de la Convención en todo el territorio del Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado Nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales;

2 (g) Garantice, como fue asegurado por la delegación del Estado Parte para el caso de la Provincia de Buenos Aires, lo siguiente: la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias policiales; el traslado a centros especiales de los menores que actualmente se encuentran en dependencias policiales; y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por "motivos asistenciales" en todo el territorio nacional; (la comilla simple no es original) (Ver las Estadísticas denunciadas por Country Rapporteur ONU CAT Comité Contra la Tortura. CAT/C/SR. 622, del 22 de noviembre de 2004, párrafo 46).

3 (h) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión, reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;

4 (i) Considere revisar su legislación y prácticas en materia de detención preventiva, a fin de que la imposición de la prisión preventiva se aplique sólo como medida excepcional, tomando en cuenta las recomendaciones

288

de diciembre de 2003 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en cuanto a las medidas alternativas a la detención preventiva; 4 (m) Adopte las medidas necesarias para garantizar la presencia de personal médico independiente y calificado para llevar a cabo exámenes periódicos de personas detenidas;

5 (o) Establezca un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención federales y provinciales a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo de la Convención;

6 (p) Establezca y promueva un mecanismo efectivo dentro del sistema penitenciario para recibir e investigar denuncias de violencia sexual y proveer de protección y asistencia psicológica y médica a las víctimas;

7 (r) Informe al Comité en el plazo de un año sobre las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los aps. e, f, l y o del presente párrafo.

51. Que por su parte el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el año 2002 recomendó al Estado Argentino que revise sus leyes y prácticas relativas al sistema de justicia de menores, y que recurra a la prisión preventiva únicamente como medida extrema por períodos que sean lo más breves posible y medidas alternativas, cuando ello sea posible. También le recomendó que incorpore en sus leyes y prácticas las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y que adopte las medidas necesarias para mejorar las condiciones de encarcelamiento (Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Argentina. 9/10/2002. CRC/C/15/Add. 187 9 de octubre de 2002).

52. Que en relación al estado de la cuestión en los últimos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una serie de resoluciones significativas sobre violaciones al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos por parte de las administraciones penitenciarias de varios países de Europa. En 2001, el Tribunal dictaminó que Grecia había infringido el art. 3 al encerrar a Donald Peers en una celda sobrepoblada sin ventanas ni ventilación, en la que se veía obligado a hacer sus necesidades delante de otro recluso, todo el día transcurría en la cama ante la ausencia de programa para trabajar, educarse o hacer ejercicio y por la carencia de otros espacios físicos para movilizarse, ponderó además

que había más prisioneros que camas. El tribunal señaló que si bien no había evidencias de una intención por parte de las autoridades penitenciarias de humillar al interno, ello no era determinante para considerar que se había violado en art. 3 de la Convención Europea (TEDH Case Peers v. Greece, sentencia del 19 de abril de 2001). También dictaminó que el Reino Unido había violado el mismo artículo al encerrar a Adele Price, una víctima de la talidomida sin brazos ni piernas, durante siete días en una celda no adaptada en modo alguno para sus discapacidades, allí no tenía un lugar adecuado para dormir, ni tampoco para hacer sus necesidades (Caso Price v. The United Kingdom, sentencia del 10 de octubre de 2001).

El mencionado tribunal en el caso "Kalashnikov" expresó que la forma de ejecutar medidas al interior de las cárceles no debe aumentar la intensidad del sufrimiento que lleva aparejado la permanencia en el interior de la prisión. Allí la Corte consideró que en todo momento, la superpoblación era tal que cada interno de la celda del demandante disponía de entre uno y dos metros cuadrados de espacio, que tenían que dormir por turnos de ocho horas que estaba infestada de olores y que los retretes estaban sucios y sin privacidad. La ausencia de una intención de humillar al detenido, aunque es tomada en cuenta, no excluía un trato inhumano y degradante violatorio del art. 3 del Convenio (TEDH en "Kalashnikov v. Russia" sentencia del 15 de julio de 2002).

53. Que, por su parte, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al interpretar la VIII enmienda de la Constitución de ese país, que prohíbe aplicar penas o tratos crueles inhumanos y degradantes, señaló que aunque determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos por las exigencias del encierro, al prisionero no se lo despoja de la protección constitucional por cuanto "no hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de este país" (Wolff v. McDonnell; 418 US 539, 1974). Por ello ha reconocido que las condiciones de confinamiento de los internos pueden, inquestionablemente, en determinadas circunstancias, constituir una pena cruel inhumana o degradante. Así los internos han obtenido respuestas a sus clamores constitucionales por sus condiciones de confinamiento, en lo referente a la comida inadecuada, a poca ventilación, hábitat con roedores o insectos, baños inoperables, pero el más común de todos los reclamos ha sido por las condiciones de hacinamiento, situación que se da en

muchas prisiones de ese país (Lynn S. Branham, The Law of Sentencing, Corrections, and Prisoners' Rights, págs. 284/291, ed. West Group, 2002).

Si bien el gobierno federal y los estatales de dicho país han invertido mucho dinero en la construcción de nuevas cárceles, pese a eso ello no se ha podido solucionar el problema de hacinamiento frente a una tasa de encarcelamiento siempre creciente. En algunos casos las autoridades penitenciarias han tenido que colocar camas en los gimnasios, en los comedores del establecimiento, en pasillos y en otros extraños lugares. Otra forma de responder ha sido aumentar en número de internos por celda diseñadas para albergar a menos personas (Lynn S. Branham, op. cit.).

En el caso Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979) la Corte Suprema consideró que era posible mantener a dos presos en una misma celda teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que se trataba de plazos breves de detención y cuando los detenidos tenían una gran libertad de movimiento dentro del penal. Posteriormente en Rhodes v. Chapman 452 U.S. 337 (1981) juzgó que la presencia de dos presos por celda no significa que sus derechos constitucionales han sido violados siempre que las condiciones de las respectivas celdas resultaran adecuadas en cuanto a la superficie habitada, las condiciones de comida y temperatura y la posibilidad de utilizar otras instalaciones del penal en períodos diurnos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con anterioridad la Corte Suprema también consideró en Hutto v. Finney 437 U.S. 678 (1978) que una corte de distrito estaba facultada para limitar la confinación de detenidos en celdas punitivas aisladas a no más de treinta días como un medio de aliviar las condiciones inconstitucionales de esas celdas. En particular, el máximo tribunal destacó que la decisión de la corte de distrito era una razonable respuesta a las condiciones sórdidas e inconstitucionales de esas celdas. Posteriormente en Wilson c. Seiter 501 U.S. 294 (1991) estableció dos requisitos para considerar que se presentaba un castigo cruel e inusual para las condiciones de confinamiento. El primer requisito —objetivo— requiere que el preso haya sido privado de una "necesidad humana identificable" como comida, clima adecuado o ejercicio. El segundo requisito —subjetivo— supone que el demandante debe demostrar que el demandado actuó con indiferencia deliberada en fallar en la rectificación de las deficiencias de esas condiciones. Cabe aclarar que cuatro de los integrantes de la

corte consideraron este requisito como innecesario y que los oficiales de las prisiones podían evitar su responsabilidad en estos casos echándole la culpa a los legisladores por no haber suministrado los fondos necesarios para superar estos problemas en las prisiones (Lynn S. Branham, op. cit.).

X. La legislación procesal y penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires.

54. Que se ha manifestado que el número creciente de presos en la Provincia de Buenos Aires responde a las reformas legislativas en materia excarcelatoria y penitenciaria, lo que neutraliza los esfuerzos del Poder Ejecutivo provincial para resolver los problemas de capacidad en las prisiones.

55. Que tanto en materia procesal penal como de ejecución penal se plantea la cuestión de la competencia legislativa. Si bien no cabe duda de que los códigos procesales son materia de legislación provincial en función de la cláusula residual, la existencia de disposiciones procesales en el Código Penal y la facultad del Congreso Nacional para dictar las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados, parecen indicar que el Estado Federal ejerce cierto grado de legislación y orientación en materia procesal, con el fin de lograr un mínimo equilibrio legislativo que garantice un estándar de igualdad ante la ley.

56. Que si bien la Constitución Nacional adopta el principio federal, lo hace según lo establece la presente Constitución, es decir, conforme a las modificaciones que la misma introduce respecto de su modelo, que era el norteamericano. Puesto que el federalismo argentino no tiene el mismo origen histórico que el norteamericano, pues procede de un régimen de descentralización administrativa que regía en la colonia, la distribución de competencia legislativa no es idéntica y las provincias delegan en el Estado Federal materias que se reservan en la Constitución de los Estados Unidos. En 1853 y en especial en la fuente norteamericana tomada con preferencia, no se conocían modelos constitucionales de facultades concurrentes en forma de leyes marco, como sucede contemporáneamente.

57. Que respecto de la prisión preventiva, cualquiera sea la tesis que se adopte acerca de su naturaleza, lo cierto es que importa en la realidad un contenido penoso irreparable, lo que lleva a asimilar las controversias a su respecto a casos de sentencia definitiva, según inveterada jurisprudencia de esta Cor-

te. Cualquiera sea el sistema procesal de una provincia y sin desmedro de reconocer su amplia autonomía legislativa en la materia, lo cierto es que si bien no puede llevarse la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el principio federal cancela por completo el derecho a la igualdad ante la ley, pues un principio constitucional no puede borrar o eliminar otro de igual jerarquía.

Una asimetría total en cuanto a la legislación procesal penal destruiría la necesaria unidad en materia penal que se mantiene en todo el territorio en virtud de un único Código Penal. Partiendo de la conocida afirmación de Ernst von Belling, de que el derecho penal no toca un solo pelo al delincuente, es sabido que incumbe al derecho procesal penal tocarle toda la cabellera y, por ello, se debe entender que, sin pretensión de cancelar las asimetrías, para la prisión preventiva —que es donde más incidencia represiva tiene el derecho procesal penal— las provincias se hallan sometidas a un piso mínimo determinado por los estándares internacionales a los que se ajusta la legislación nacional. No es lo mismo que, habiendo dos imputados en igualdad de condiciones y por el mismo delito, uno llegue al juicio libre y otro lo haga después de muchos meses o años de prisión, sin que el Estado Federal se asegure de que en el último caso, al menos, se respete un piso mínimo común para todo el territorio.

Por lo demás, no puede soslayarse, que en esta materia la legislación procesal nacional, receptaría las distintas disposiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos que forma parte de nuestro bloque constitucional federal.

58. Que conforme a lo señalado en el considerando anterior, cabría analizar la eventual constitucionalidad de la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires en materia excarcelatoria, que prima facie parece alejarse del estándar trazado por el derecho internacional y que sigue la legislación nacional. Si bien no corresponde un pronunciamiento de esta Corte sobre este tema en la presente causa, tampoco el Tribunal puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y, por consiguiente, cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales que, a modo de

ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación.

59. Que en materia penitenciaria la cuestión es aún más clara que en lo procesal. El 21 de agosto de 1917, al fundar Rodolfo Moreno (h.) el despacho de la comisión acerca del Código Penal, decía que "es necesario que se dicte una ley carcelaria, una ley en la que se establezca el régimen de la penalidad en primer término, pero el régimen de la penalidad en toda la República, y bajo el sistema progresivo, si fuera posible, porque hoy en cada cárcel, en cada provincia, y en cada lugar se cumplen las penas como les parece oportuno a los gobiernos locales, es decir que, habiendo o debiendo haber un solo código penal, la aplicación de las represiones se hace de manera totalmente diferente en unos y en otros lugares, como si no pertenecieran todos al mismo país".

Después de un largo camino, que se inició en 1933, con la ley 11.833 (Ley de organización carcelaria y régimen de la pena), reglamentada por decreto 35.758 de 1947, reemplazada por el decreto-ley 412 de 1958, conocido como ley penitenciaria nacional, se llegó a la 24.660 de 1996 (Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad), cuyo art. 230 deroga el mencionado decreto-ley 412/58 y cuyo art. 228 dispone: "La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente". Esta disposición es mucho más sabia y respetuosa del principio federal que la consagrada en el decreto-ley precedente, pues, a diferencia de aquél, que se consideraba complementario del Código Penal y por ende, pretendía desconocer la competencia legislativa provincial, en la ley vigente se trata de una clara norma marco que es constitucional pues no impide ni avanza sobre las legislaciones de ejecución penal provinciales, sino que establece su adecuación, debiendo interpretarse que establece un marco mínimo de régimen, más allá del cual pueden avanzar las provincias en sus respectivas legislaciones.

60. Que, conforme a lo señalado en el considerando anterior, y que en esta materia también prima facie la ley provincial parece haberse alejado del estándar internacional y de la legislación nacional, si bien tampoco corresponde pronunciamiento de esta Corte en la presente causa, por iguales razones a las señaladas en el considerando 58, cabe que esta Corte exhorte a los Poderes Legislativo y

Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación de ejecución penal a los marcos mínimos señalados por los estándares internacionales receptados por la legislación de ejecución penal de la Nación.

XI. Excesivo uso de la prisión preventiva

61. Que ya no hay controversias respecto a que el 75% de detenidos en la Provincia de Buenos Aires aun no tiene condena firme. Este hecho puede deberse a distintas razones: parálisis o colapso casi total del sistema judicial, aplicación generalizada a imputaciones por delitos de menor gravedad, etc. Se ha admitido en los autos que este fenómeno creció a partir de las reformas legislativas antes señaladas y cuya eventual inconstitucionalidad corresponderá analizar en caso de ser planteada y de verificarse que viola los estándares internacionales mínimos válidos para toda la Nación.

No consta a esta Corte, si además se produce un uso discrecional muy extendido en las decisiones judiciales, pues es un dato aportado por el Poder Ejecutivo de la provincia y no controlable por este Tribunal.

62. Que el 75% de presos sin condena, en caso de no hallarse colapsado casi totalmente el sistema judicial, está indicando el uso de la prisión preventiva como pena corta privativa de la libertad, contra toda la opinión técnica mundial desde el siglo XIX a la fecha, pues fueron criticadas desde el primer congreso penitenciario internacional de Londres de 1872, en el que se destacaba ya su inutilidad, desatando una cadena de opiniones condenatorias que fue casi unánime a lo largo de todo el siglo XX. Hace casi cincuenta años, en el segundo congreso de Naciones Unidas para la prevención del crimen y tratamiento del delincuente (Londres, 1960), si bien se sostuvo la imposibilidad de suprimirla, se recomendaron los llamados sustitutivos.

63. Que en cualquier caso es dable evocar en esta emergencia —y con el 75% de presos sin condena— la descripción que hace ciento treinta años hacía para España doña Concepción Arenal, para que si no se ha llegado a extremos análogos a la radiografía de la célebre penitenciarista española, todos los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires se esfuercen por evitarlos y, si eventualmente se han alcanzado, hagan lo propio por revertirlo: "Imponer a un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad, una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea ino-

cente, es cosa que dista mucho de la justicia. Si a esto se añade que deja a la familia en el abandono, acaso en la miseria; que la cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece de lo preciso para su vestido y sustento; donde, si no es muy fuerte, pierde la salud; donde, si enferma no tiene conveniente asistencia y puede llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicio y el crimen, espera una justicia que no llega, o llega tarde para salvar su cuerpo, y tal vez su alma; entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza. Sólo una necesidad imprescindible y probada puede legitimar su uso, y hay abuso siempre que se aplica sin ser necesaria y que no se ponen los medios para saber hasta dónde lo es" (Concepción Arenal, Estudios Penitenciarios, 2ª edición, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1877, página 12).

XII. Resolutorio:

Por ello, y oído que fuera el señor Procurador General, corresponde:

1. Declarar admisible la queja y procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.
2. Declarar que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.
3. Disponer que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.
4. Instruir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de esta Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.
5. Ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos, en el término de treinta días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a

fin de que éstos puedan ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Asimismo, se deberá informar en el plazo de cinco días toda modificación relevante de la situación oportunamente comunicada.

6. Disponer que cada sesenta días el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a esta Corte las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia.

7. Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.

8. Encomendar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una mesa de diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como amicus curie, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a esta Corte cada sesenta días de los avances logrados.

Agréguense la queja al principal y extraíganse fotocopias certificadas para su reserva en este Tribunal. — *Enrique S. Petracchi*. — *Carlos S. Fayt* (en disidencia parcial). — *Antonio Boggiano* (en disidencia). — *Juan C. Maqueda*. — *E. Raúl Zaffaroni*. — *Elena I. Highton de Nolasco*. — *Ricardo L. Lorenzetti*. — *Carmen M. Argibay* (en disidencia parcial).

Omissis...

Disidencia parcial de la doctora Argibay:

Considerando: Que la infrascripta coincide con los considerandos 1° a 54 del voto de la mayoría.

55. No hay controversias respecto a que el 75% de detenidos en la Provincia de Buenos Aires aún no tiene condena firme. Este hecho puede deberse a distintas razones: parálisis o colapso casi total del sistema judicial, aplicación generalizada a imputaciones por delitos de menor gravedad, etc. Se ha admitido en los autos que este fenómeno creció a partir de las reformas legislativas antes señaladas y cuya eventual inconstitucionalidad corresponderá analizar en caso de ser planteada y de verificarse que viola los estándares constitucionales e internacionales mínimos válidos para toda la Nación.

No consta a esta Corte, si, además, se produce un uso discrecional muy extendido en las decisiones judiciales, pues es un dato aportado por el Poder Ejecutivo de la Provincia y no controlable por este Tribunal.

56. Sin embargo, el examen de constitucionalidad del régimen de la prisión preventiva y la excarcelación vigente en la Provincia de Buenos Aires debe llevarse a cabo exclusivamente sobre la base de las reglas contenidas en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales que vinculan a las legislaturas provinciales.

La propuesta de utilizar como marco normativo obligatorio el Código Procesal Penal de la Nación importa una severa restricción del principio federal adoptado por nuestro país en el artículo 1° de la Constitución Nacional, pues, fuera del respeto a la Constitución y leyes federales, las provincias no pueden ser obligadas a seguir los criterios legislativos del Congreso Nacional en un tema que no ha sido delegado por las provincias, como lo es, la regulación de la excarcelación y la prisión preventiva. Tanto menos cuando el Congreso al dictar el Código Procesal Penal no lo hizo con la expresa declaración o voluntad de que se utilizase como marco obligatorio para la legislación procesal provincial. En esta medida, considero que tal utilización configura también una desviación del principio democrático, pues se asigna a la voluntad legislativa un efecto y un alcance que no estuvo presente en el proceso deliberativo que precedió a la sanción de la ley y que tampoco es necesario para establecer una recta interpretación de su texto.

57. Todo ello sin perjuicio de que para establecer la constitucionalidad de la legislación procesal en materia de prisión preventiva y excarcelación deba tenerse también en cuenta su impacto sobre el servicio de custodia penitenciaria, en particular, la superpoblación y sus deletéreas consecuencias en términos de derechos humanos de los reclusos. Lo contrario implica admitir el funcionamiento de un sistema ciego a sus efectos, que sigue alimentando cárceles atestadas sin posibilidad de corregirse a partir de la percepción de este dato de la realidad.

Por ello, y oído que fuera el señor Procurador General, corresponde:

1. Declarar admisible la queja y procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

2. Declarar que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones

Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuren las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.

3. Disponer que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.

4. Instruir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de esta Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.

5. Ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos, en el término de treinta días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (característi-

cas de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Asimismo, se deberá informar en el plazo de cinco días toda modificación relevante de la situación oportunamente comunicada.

6. Disponer que cada sesenta días el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a esta Corte las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia.

7. Encomendar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una mesa de diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como amicus curie, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a esta Corte cada sesenta días de los avances logrados. — *Carmen M. Argibay*.

Omissis...

9. GALLI, HUGO

CONFISCATORIEDAD

Bono del Tesoro — Coeficiente de Estabilización de Referencia — Constitucionalidad — Control de constitucionalidad — Decreto de necesidad y urgencia — Decreto nacional — Delegación legislativa — Deuda pública — Discriminación — Dólar — Emergencia económica — Igualdad ante la ley — Inflación — Ley aplicable — Ley de emergencia — Moneda extranjera — Obligación en moneda extranjera — "Pacta sunt servanda" — Pesificación — Principio de razonabilidad — Renegociación de la deuda pública — Título de deuda pública nacional — Títulos Públicos

Hechos:

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que había admitido el amparo tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 471/2002 en la medida en que afecta a los bonos de la deuda pública nacional en dólares estadounidenses que poseían los actores, consistentes en Bonton Previsional segunda serie. BONTES 2002 al 8,75%, BONTES 2003 al 11,75% y BONTES 2004 al 11,25%, al convertirlos a razón de \$1,40 por cada dólar. En consecuencia, la alzada ordenó al Estado Nacional abonar en dólares los

servicios financieros y las amortizaciones de los títulos. El Estado Nacional dedujo recurso extraordinario, el que fue concedido. Argumentó el apelante la constitucionalidad del decreto 471/2002. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admite el recurso y revoca la sentencia.

1. Las medidas que las autoridades implementaron para conjurar la crisis desatada en el año 2001, en su proyección en el decreto 471/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1691) que convirtió a pesos los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal

emitidos en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuando la ley aplicable sea sólo la argentina, encuentran amparo constitucional desde que no son desproporcionadas con relación al objetivo declarado de afrontar el estado de emergencia que perseguían, ni aniquilan el derecho de propiedad del acreedor, considerando la existencia de un estado de cesación de pagos a ese momento (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).

2. La decisión del decreto 471/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1691) de convertir a pesos los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal emitidos en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera cuando la ley aplicable sea sólo la argentina, no vulnera el principio constitucional de razonabilidad en un contexto donde no hay habitante que no haya sufrido las consecuencias de la emergencia, siendo que se previeron mecanismos de compensación tales como la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia a fin de resguardarlos de los efectos de la inflación interna y el reconocimiento de intereses a tasas diferentes de acuerdo con los distintos tipos de obligaciones, lo cual trae aparejado el abandono del sistema de convertibilidad de la ley 23.928 (Adla, LI-B, 1752) (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).
3. No se advierte una manifiesta invalidez en el decreto 471/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1691), que convirtió a pesos los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal emitidos en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuando la ley aplicable sea sólo la argentina, toda vez que es incierta la entidad final del sacrificio impuesto para recomponer una situación crítica que extiende sus efectos a toda la sociedad en diversas formas, a tal punto que no se puede considerar que trascienda los límites que han llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a calificar una medida de confiscatoria y cercenatoria del derecho (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).
4. La disparidad de trato entre la deuda pública sometida a la ley argentina, aprehendida por el decreto 471/2002 del
5. Siendo que durante el transcurso del proceso se dictaron nuevas normas relativas a la conversión a pesos de los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal emitidos en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, aquellas deben ser consideradas para la solución de la cuestión relativa a la constitucionalidad del decreto 471/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1691), en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cuyo tenor sus sentencias deben reparar en las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las cuales no es posible prescindir (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).
6. La legislación de emergencia responde al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya sean económicas, sociales o de otra naturaleza y constituye la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que escoja para remediar aquellas circunstancias, siempre que los medios arbitrados sean razonables y no respondan a móviles discriminatorios o de persecución contra grupos o individuos (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).
7. La decisión que debe dictarse con relación a la constitucionalidad del decreto 471/2002 del Poder Ejecutivo Nacional

Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1691) que convirtió a pesos los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal emitidos en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, y la que se rige por leyes extranjeras, no configura un trato desigual entre acreedores que vulnera el art. 16 de la Constitución Nacional, pues la distinción no se realiza entre nacionales y extranjeros sino entre títulos u obligaciones sometidos a una u otra legislación, de manera que los efectos de la norma alcanzan a todos los acreedores, sin distinciones de nacionalidad, que posean títulos de la deuda pública regidos por las leyes argentinas (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).

(Adla, LXII-B, 1691) se ha de limitar a las cuestiones planteadas en la acción de amparo y resueltas en las instancias inferiores, toda vez que el alcance y consecuencias del decreto 1735/2004 del Poder Ejecutivo Nacional y la ley 26.017 (Adla, LXV-A, 137; Bol. 3/2005, p. 1) no han sido objeto de debate y podrán ser materia de tratamiento por la vía y forma que correspondieren.

8. Las normas que alteraron las condiciones originales de emisión de los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal y suspendieron su pago, no contradicen la garantía de la razonabilidad porque se justifican por los hechos que les han dado origen, esto es, una crisis económica de extrema gravedad y una situación indiscutible de emergencia que colocó a las autoridades competentes del gobierno nacional en la necesidad de proceder de ese modo para asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado Nacional y la atención de servicios esenciales, de acuerdo con criterios consuetudinarios admitidos en el derecho internacional (del voto de los doctores Maqueda y Highton de Nolasco).
9. Las normas que alteraron las condiciones originales de emisión de los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal y suspendieron su pago, han sido establecidas sobre una base razonablemente igualitaria entre los acreedores y atienden a criterios de justicia distributiva, sin perjuicio de las excepciones taxativamente previstas de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborada en torno a la garantía consagrada en el art. 16 de la Constitución Nacional (del voto de los doctores Maqueda y Highton de Nolasco).
10. Es improcedente la tacha de inconstitucionalidad del decreto 471/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1691) que alteró las condiciones originales bajo las cuales se emitieron títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal, ya que la pretensión de mantener incólume el derecho al cobro de los servicios en su integridad, plazos y moneda de origen, importa olvidar que se estaba ante una situación de crisis e impotencia financiera del Estado que debía encontrar respuesta en una solución
11. Corresponde considerar insustanciales las críticas efectuadas por los amparistas a la oferta de canje de títulos de la deuda pública realizada por el decreto 1735/2004 del Poder Ejecutivo Nacional y la ley 26.017 (Adla, LXV-A, 137; Bol. 3/2005, p. 1), toda vez que la adhesión o no adhesión a tal procedimiento es una opción que puede ser libremente ejercida por los tenedores de bonos declarados «elegibles», mientras que el art. 6 del decreto mencionado es inaplicable en el caso porque no concurren ninguno de los supuestos previstos en la norma en tanto no consta que los bonos en cuestión hayan sido depositados judicialmente y ha mediado un enfático rechazo al canje (del voto de los doctores Maqueda y Highton de Nolasco).
12. A los efectos del control de constitucionalidad de la legislación de emergencia que alteró las condiciones originadas de emisión de los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal, lo relevante queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad que, como ha sido configurada por la jurisprudencia, supone que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de iniquidad manifiesta (del voto de los doctores Maqueda y Highton de Nolasco).
13. El principio básico que regula la emisión de los bonos de la deuda pública es el deber de cumplimiento de las obligaciones pactadas, que el Estado debe honrar no sólo en beneficio de quienes contratan con él, sino en su propio interés, ya que de tal modo se produce confianza en los inversores a los que recurre, lo cual implica que sólo situaciones excepcionales habilitarían al emisor a alterar unilateralmente ciertas condicio-

nes de emisión (del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti).

14. La regla general en materia de emisión de bonos de la deuda pública, es el respeto de las condiciones pactadas, las que sólo pueden ser modificadas en situaciones de emergencia excepcional y gravísimas, y ello ocurre cuando el cumplimiento puntual lleva al estado a su propia crisis y al sacrificio de derechos fundamentales de la población que debe proteger (del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti).
15. El perjuicio patrimonial invocado por los tenedores de títulos de la deuda pública cuyas condiciones de emisión fueron modificadas por la legislación de emergencia, debe ser valorado dentro de la relación jurídica que los une con quienes les vendieron dichos bonos como alternativa de inversión, y en ese aspecto cabe considerar que las personas que legítimamente compran títulos de la deuda pública deben ser informadas adecuadamente sobre los riesgos de todo tipo que éstos presentan y aconsejadas sobre las decisiones a tomar en la medida en que la complejidad de esa información les dificulta hacerlo (del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti).
16. La situación de emergencia excepcional y gravísima que llevó al Estado Nacional a modificar las condiciones de emisión de los títulos de la deuda pública, lleva a convalidar las restricciones impuestas a los tenedores de dichos títulos, porque se presentan como razonables en el caso (del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti).
17. El control de constitucionalidad de las normas que modificaron las condiciones originales de emisión de los títulos de la deuda pública nacional, provincial y municipal en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, es específico para el caso y no puede ser basado en analogía con un supuesto de hecho diferente como es la declaración de inconstitucionalidad de las normas referidas a la pesificación en general y de los depósitos bancarios, pues se trata de supuestos de hecho diversos al diferir el objeto de la pretensión, el deudor y la existencia de acreedores que compraron bonos de diversas clases con una inversión con

un riesgo sobre el cual debieron ser informados y aconsejados (del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti).

18. El mecanismo ideado por la ley 25.827 y el decreto 1735/2004 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXIV-A, 44; LXV-A, 137) para reestructurar la deuda pública en cesación de pagos se exhibe como razonable en atención a su virtualidad para amalgamar los distintos elementos que deben meritarse en una operación de este tipo, cual es la posibilidad concreta y real del Estado de afrontar los pagos, instrumentos técnicos hábiles para dicho fin, así como criterios igualitarios en su asignación (del voto de la doctora Argibay).
19. La pretensión de los actores de mantener las condiciones originarias de los títulos de la deuda pública que poseen, así como los modos y plazos en que dichos instrumentos debían ser cancelados, procura la obtención de un privilegio singular y es incompatible con los fines de interés general que inspiran la operatoria llevada adelante por la República Argentina a fin de restablecer los mecanismos de pago de sus obligaciones (del voto de la doctora Argibay).
20. Al estar los títulos públicos que poseen los amparistas están mencionados en los anexos del decreto 1735/2004 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXV-A, 137) entre los elegibles a los fines del canje, y que sus poseedores han rechazado la operatoria de reestructuración de la deuda en default, quedan los bonos sometidos a lo previsto en el art. 4 de la ley 26.017 (Adla, Bol. 3/2005, p. 1), por lo que las consecuencias que pueda acarrear dicha situación sólo les resulta imputable a ellos en tanto conocían que la mencionada ley impedía al Poder Ejecutivo Nacional reabrir el proceso de adhesión y efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada sobre esos títulos (del voto de la doctora Argibay).

CS, 2005/04/05.— Galli, Hugo G. y otro c. Estado nacional (*).

(*) Publicado en: Fallos: 328:690, LA LEY 2005-C-32, con nota de María Angélica Gelli - LA LEY 2005-B-719, con nota de Andrés Gil Domínguez - DJ 2005-1, 940, con nota de Andrés Gil Domínguez - DJ 2005-2, 89, con nota de Alejandro Drucaroff Aguilar - LA LEY 2005-C-335, con nota de Eduardo S. Barcesat y Roberto J. Boico - IMP 2005-A, 1627 - LA LEY 2005-E, 194, con nota de Gustavo Carlos Liendo; Horacio Tomás Liendo (h.).

Buenos Aires, 5 de abril de 2005.

3. Que contra lo así resuelto el Estado Nacional dedujo el recurso extraordinario de amparo, fs. 143/170, que fue concedido mediante el fallo de la Sala IV, fs. 185 en tanto la sentencia interpretó las normas de carácter federal en sentido contrario al postulado por la apelante, y denegado en lo atinente a las causales de arbitrariedad e inseguridad institucional.

Que, por otra parte, la decisión que debió dictarse se ha de limitar a las cuestiones planteadas en la demanda y resueltas en las instancias inferiores, ya que el alcance y consecuencias del decreto 1735/04 y la ley 26.017 no han sido objeto de debate y podrán ser materia de tratamiento por la vía y la forma que correspondieren.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la acción de amparo (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Costas por su orden en todas las instancias en razón de tratarse de una cuestión jurídica novedosa. — *Augusto C. Belluscio*. — *Antonio Boggiano*. — *Juan C. Maqueda* (según su voto). — *E. Raúl Zaffaroni* (según su voto). — *Elena I. Highton de Nolasco* (según su voto). — *Ricardo L. Lorenzetti* (según su voto). — *Carmen M. Argibay* (según su voto).

Voto de los doctores *Maqueda* y *Highton de Nolasco*:

Considerando: 1. Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la instancia anterior que hizo lugar a la acción de amparo promovida por los actores y, en consecuencia, tras declarar la inconstitucionalidad de las normas que dispusieron convertir a pesos los títulos de la deuda pública expresados en moneda extranjera y reducir los intereses pactados — en particular, el decreto 471/02 — ordenó al Estado Nacional (Ministerio de Economía) que pagase a los actores los bonos de los que ellos son titulares — *Boncos Previsionales, Segunda Serie, BONTES 2002 al 8,75%, BONTES 2003 al 11,75%, BONTES 2003 a tasa variable y BONTES 2004 al 11,25%*, todos expresados en dólares estadounidenses — según las condiciones en que tales títulos habían sido emitidos.

2. Que para decidir en el sentido indicado, el a quo afirmó que mediante el referido decreto 471/02 el Estado Nacional modificó compulsiva y arbitrariamente las obligaciones que surgen de los títulos que emitió; y juzgó que tal modificación implica una violación al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.

4. Que en su recurso la representante del Estado Nacional defiende la validez constitucional del decreto 471/02 y la reestructuración de la deuda pública para adecuarla a las reales posibilidades de pago del gobierno nacional. Sostiene, en síntesis, que se trata de medidas adoptadas en el contexto de una grave situación de emergencia económica, y ante la necesidad de superar la crisis teniendo en mira el interés público.

5. Que el recurso extraordinario planteado resulta formalmente admisible puesto que se encuentra en disputa la inteligencia y validez constitucional de normas de carácter federal, y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es adversa al derecho que el apelante sustenta en ellas (art. 14, incs. 1 y 3, de la ley 48). Al respecto cabe recordar que en la tarea de determinar la interpretación y alcances de normas de tal naturaleza, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (Fallos 312:2254; 318:74, entre otros). Asimismo, reiteradamente el Tribunal ha señalado que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de decidir, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos 311:870 y 1810; 314:568; 315:2684, entre otros).

6. Que, en virtud de esto último, corresponde señalar que los actores han efectuado una presentación, a fs. 202/203 vta., mediante la cual manifiestan su voluntad de no adherirse al procedimiento de canje de los títulos de la deuda pública nacional establecido por el art. 62 de la ley 25.827, el decreto 1735/04 y normas complementarias, con relación a los bonos de su propiedad que han motivado este pleito. En tal sentido, afirman que la propuesta efectuada por el Estado Nacional implica una merma sustancial de su derecho de propiedad, por lo cual resulta confiscatoria. Aluden asimismo a la ley 26.017, cuyas disposiciones, a juicio de los presentantes, implican una "presión inconstitucional" encaminada a obtener una mayor adhesión al canje, y en particular a su art. 6° si se lo interpretase como una imposición compulsiva del

canje, ya que —como se señaló— rechazan dicha propuesta.

7. Que el dictamen del señor Procurador General contiene una adecuada reseña de las normas relativas al tratamiento de la deuda pública del Estado Nacional, a partir del anuncio, efectuado el 24 de diciembre de 2001, de que la República Argentina había dispuesto diferir el pago —en relación a sus compromisos externos— de sus intereses y capital, reseña a la que corresponde remitirse por motivos de brevedad.

Sin perjuicio de ello, en virtud de la presentación a la que se hizo referencia en el considerando precedente, cabe ampliar dicha reseña en orden a los aspectos vinculados con tal presentación.

Al respecto es útil destacar, aun cuando esto ya ha sido señalado en el aludido dictamen, que las sucesivas leyes de presupuesto correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004 (números 25.565, 25.725 y 25.827), autorizaron al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción a reestructurar las obligaciones de la deuda del gobierno nacional, en los términos del art. 65 de la ley 24.156, a fin de adecuar sus servicios a las posibilidades de pago del Estado Nacional. Cabe recordar, a su vez, que durante el tiempo que demandase llegar a un acuerdo, el legislador había autorizado al Poder Ejecutivo —a través del mencionado ministerio— a diferir total o parcialmente los servicios de la deuda pública a efectos de atender funciones básicas del Estado Nacional.

Sobre tales bases, el decreto 1735/04 dispuso "la reestructuración de la deuda del Estado Nacional, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional" (art. 1°), con el alcance y en los términos y condiciones establecidos en tal decreto. De tal modo, el Estado Nacional ofreció a los tenedores de los bonos —declarados elegibles en los anexos que integran dicho decreto— su canje por nuevos instrumentos representativos de deuda, junto con "Valores Negociables Vinculados al P.B.I."

A su vez, por la resolución 20/2005 del Ministerio de Economía y Producción, se aprobaron los términos del "Suplemento de Prospecto" (Anexo I) relativo a la oferta internacional, el "Procedimiento Operativo aplicable en la República Argentina" (Anexo II) y las "Con-

diciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la República Argentina" (Anexo III).

En los considerandos del mencionado decreto se consignó que la entrega de un instrumento vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) constituía una forma de compatibilizar los intereses de los tenedores con el objetivo central de la política económica actual, consistente en la consolidación del crecimiento económico, factor determinante, a su vez, de la capacidad de pago de la República Argentina. Asimismo, se expresó que se había evaluado la capacidad de pago del Estado Nacional frente a las obligaciones resultantes del canje de la deuda pública (conf. párrafos catorce y quince).

La propuesta unilateral efectuada por el gobierno nacional fue, en lo sustancial, única para todo el universo de tenedores de bonos de la deuda pública en default emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 para el canje de sus títulos elegibles por otros nuevos (conf. Suplemento de Prospecto del 27 de diciembre de 2004, Traducción Pública, Cap. "Oferta Global", Anexo resol. 20/2005 del Ministerio de Economía y Producción).

Dicha propuesta conlleva una extensión de los plazos y, en su caso, una quita de capital nominal respecto de lo originariamente pactado y exteriorizó —cuando el país "aún está saliendo de la crisis económica más grave de su historia"— la pretensión de alcanzar una reducción de la deuda en la magnitud necesaria para propiciar "la estabilidad fiscal en el futuro y la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo", así como la equidad entre los acreedores (conf. Suplemento de Prospecto del 27 de diciembre de 2004, Traducción Pública, Cap. "Condiciones de la Oferta: Metodología; Recomendación" Anexo resol. 20/2005 del Ministerio de Economía y Producción).

Por su parte, la ley 26.017 estableció las condiciones a las que quedarían sujetos, sin perjuicio de las normas que les resulten aplicables, los bonos del Estado Nacional que, siendo elegibles para el canje establecido por el decreto 1735/04, no hubiesen sido presentados a éste. Asimismo, se dispuso que el Poder Ejecutivo no podría reabrir, en relación a estos bonos, el proceso de canje establecido por el citado decreto, y que, en el marco de las condiciones de emisión de los respectivos títulos y de las normas aplicables a las jurisdicciones correspondientes, debería dictar los actos administrativos y cumplir las gestiones necesarias para retirarlos de cotización en todas las bolsas y mercados de valores

294

nacionales y extranjeros. De igual modo, se prohibió al Estado Nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada sobre estos títulos. Finalmente, para el supuesto de que existieran bonos depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia o jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al canje o no hubieran manifestado en forma expresa en las respectivas actuaciones judiciales su voluntad de no adherir a éste antes de la fecha de cierre, se estableció que aquéllos quedarían reemplazados de pleno derecho por los "Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos Step Up 2038", en las condiciones establecidas para la asignación, liquidación y emisión de los bonos por el decreto 1735/04.

8. Que el examen de la presente causa no puede realizarse sin tener en cuenta que esta controversia tuvo lugar en el marco de una situación de emergencia, que fue producto de la crisis económica de mayor gravedad que ha sufrido la República Argentina a lo largo de su historia, al menos desde su organización nacional a mediados del siglo XIX. Tal situación de emergencia ha sido descripta adecuadamente en el dictamen del señor Procurador General —al que corresponde remitir en este aspecto— y fue reconocida expresamente por los propios demandantes (conf. fs. 4, 4 vta. y 10 vta.). Por lo tanto, resultaría inoficioso que el Tribunal se extendiera en formular consideraciones al respecto. Sólo debe ponerse de relieve que la extraordinaria magnitud de esa crisis haría manifiestamente equivocada cualquier decisión que apreciara las circunstancias de esta causa como si se hubiesen desarrollado en épocas de normalidad y sosiego, y que pasara por alto la desoladora situación financiera del Estado Nacional.

9. Que, por lo tanto, habida cuenta de tal situación de emergencia, resulta necesario indagar las respuestas del derecho de gentes en supuestos en que los estados se han visto en dificultades para hacer frente a sus compromisos internos e internacionales. No se trata, en efecto, de una cuestión retórica o meramente académica ya que, como expresa Alfredo Schoo "el desbarajuste económico y financiero de la post-guerra [en alusión al conflicto bélico de los años 1914 a 1918] produjo una epidemia de suspensiones de servicios y reducciones unilaterales de deuda", de forma que "para elaborar una lista se precisaría una paciencia de benedictino y, por otro lado, sería superflua, pues comprendería a casi todos los estados del globo" (Régi-

men Jurídico de las Obligaciones Monetarias Internacionales, Kraft, Buenos Aires, 1940, pág. 369; las comillas simples no pertenecen al original).

10. Que al respecto cabe recordar que, en el caso "Brunicardi" (Fallos 319:2886) esta Corte —sobre la base del dictamen del señor Procurador General que en este punto hizo suyo— afirmó la existencia de un principio de derecho de gentes "que permitiría excepcionar al Estado de responsabilidad internacional por suspensión o modificación en todo o en parte del servicio de la deuda externa, en caso de que sea forzado a ello por razones de necesidad financiera impostergable" (considerando 16). Este principio se funda, en lo sustancial, en que ningún Estado puede ser obligado al cumplimiento de acuerdos que superen su capacidad de pago ya que, como aplicación del clásico brocardico "ad impossibilia nemo tenetur", se ha señalado que "nadie puede hacer lo imposible" (conf. ap. VII del citado dictamen, pág. 2896).

11. Que se estima conveniente recordar algunas de las razones expresadas en el dictamen al que se hizo referencia —al que corresponden las citas efectuadas en los párrafos que siguen— para sustentar la existencia del mencionado principio, en la inteligencia de que tal criterio resulta relevante para la decisión de la presente causa puesto que, aunque no se trate de un supuesto de endeudamiento externo del Estado, la analogía es evidente, máxime al haberse dado finalmente un tratamiento similar a ambas clases de títulos, según surge del relato efectuado en el ap. 7°.

En tal sentido, cabe precisar que la exclusión de ilicitud en el ámbito del derecho internacional derivada del no pago de la deuda pública fue prevista en el proyecto presentado por el relator Roberto Ago ante la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, la cual aprobó su primera lectura, y de lo que se informó a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones. Aquel proyecto, teniendo en cuenta la práctica de los estados, la jurisprudencia internacional y la doctrina concluyó que son causales excluyentes de ilicitud: la fuerza mayor; el caso fortuito y el estado de necesidad.

Asimismo, resulta útil mencionar el informe que el relator García Amador sometió a la referida comisión, en el ámbito del anteproyecto revisado en materia de responsabilidad del Estado y del que surge que éste la tendrá cuando el desconocimiento de sus obligacio-

nes "no se justifica por razones de interés público 'o se discrimina entre nacionales y extranjeros en perjuicio de los segundos'" (las comillas simples son añadidas).

La concorde opinión de la doctrina en relación a lo expuesto se halla representada, entre otros, por la autoridad de Gaston Jéze, quien ya en su curso de 1935 en la Academia Internacional de La Haya (Recueil, t. 53, pág. 391) expresó categóricamente que "...se justificaría que un gobierno 'suspendiese o redujese' el servicio de su deuda pública cada vez que se hubiesen de comprometer o descuidar los servicios públicos esenciales para asegurar el servicio de la deuda" (las comillas simples no pertenecen al original). De ahí que, en otra oportunidad, expresó, de forma no menos categórica, que "...es evidente que para pagar íntegramente a sus acreedores, un gobierno no va a paralizar los servicios de la defensa nacional, de la policía y de la justicia".

Por otra parte, a propósito del laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya relativo a un conflicto entre los imperios ruso y otomano, el prestigioso internacionalista Alfred von Verdross consideró que los dichos de la Corte testimoniaban "el principio de autoconservación" de los estados en virtud del cual "...los deberes internacionales no deben conducir hasta la destrucción de sí mismo". De igual modo, y con sustento en lo resuelto en dos laudos que tuvieron como protagonistas a los estados del Reino Unido y de Venezuela, los profesores de la Pradelle y Politis expresaron que de "...la circunstancia de que la deuda sea cierta y no controvertida 'no se concluye que el deudor deba satisfacerla en su totalidad; se precisa, además, que el estado de sus finanzas se lo permita'. Por tentados que nos sintamos a hacer abstracción de las particularidades de un empréstito público para someterlo al régimen de las obligaciones ordinarias, no cabe tratar al Estado que no puede pagar sus deudas más rigurosamente que a los particulares que quiebran o se arruinan" (las comillas simples no pertenecen al original).

12. Que esta Corte ha afirmado que "existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiera obrado el cuerpo legislativo ajeno al poder judicial" (Fallos 68:238 y 295). Es que, como también se ha sostenido reiteradamente, "es principio del ordenamiento jurídico que rige en la República que tanto la organización social como política y económica del

país reposan en la ley" (Fallos 234:82, su cita y otros) y que el control judicial deberá ser ejercido con la mayor mesura pues "la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del Estado" (Fallos 282:392 y su cita, entre otros).

De ahí que, también de modo invariable, se haya alertado sobre el peligro que puede resultar de trabar la acción legislativa, cuando una necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, pues si el Congreso se viera impedido de concurrir allí donde es requerida su intervención, el mecanismo gubernativo quedaría sin los medios indispensables para llenar la función que le incumbe (dictamen del señor Procurador General en Fallos 172:21, pág. 31, que esta Corte, en lo pertinente, hizo suyo). Y sobre la base de similar concepto, el Tribunal ha entendido que no les corresponde a los jueces decidir sobre la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos 318:785); ni pronunciarse sobre la oportunidad o discreción en el ejercicio de aquéllas (Fallos 224:810), ni imponer su criterio de eficacia económica o social al Congreso de la Nación (Fallos 311:1565); y asimismo que "el control de constitucionalidad no autoriza a la Corte Suprema a sustituir en su función a los otros poderes del gobierno" (Fallos 256:386 y sus citas).

13. Que, ciertamente, lo antes señalado no excluye el inexcusable deber que pesa sobre los jueces de verificar la compatibilidad constitucional, acorde con el art. 31 de la Constitución Nacional, de las leyes controvertidas en los casos sometidos a su jurisdicción, de modo que, si efectuada esa verificación se comprobara la existencia de desacuerdo o incongruencia, la norma legal sería descalificada. En tal sentido y en cuanto aquí concierne, lo relevante a efectos del control de constitucionalidad que incumbe al Tribunal queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad que, como ha sido configurada por conocida jurisprudencia, supone que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de iniquidad manifiesta (Fallos 248:800; 243:449; 243:467, entre otros).

14. Que, en orden a ello, no se advierte que las normas que alteraron las condiciones ori-

ginales bajo las que se habían emitido los bonos y suspendido su pago contradigan esa garantía, pues resultan justificadas por los hechos que les han dado origen, esto es, una crisis económica de extrema gravedad y una situación indiscutible de emergencia que colocó a las autoridades competentes del gobierno nacional en la necesidad de proceder de ese modo a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado Nacional y la atención de servicios esenciales, de acuerdo con criterios consuetudinarios admitidos en el derecho internacional, según se expresó en los considerandos 10 y 11 de la presente. En efecto, en respuesta a esa situación de emergencia se dictó un conjunto de normas, que implican un acto de soberanía del Estado, según se afirmó en el ya citado precedente "Brunicardi" (confr. considerando 17), y mediante las cuales se procuró contemplar armónicamente las reales posibilidades de pago del Estado Nacional, y los intereses de los acreedores, de modo que, como ha señalado este Tribunal, se tienda a poner premiosamente fin al estado de emergencia, cuya prolongación representa, en sí misma, el mayor atentado a la seguridad jurídica (Fallos 243:467, voto de los jueces Aróz de Lamadrid y Oyhanarte, considerando 11).

15. Que las disposiciones adoptadas en ese contexto se establecieron sobre una base razonablemente igualitaria entre los acreedores, sin perjuicio de las excepciones taxativamente previstas —mencionadas en el dictamen del señor Procurador General— las cuales obedecen a criterios admisibles de acuerdo con la conocida jurisprudencia de esta Corte elaborada en torno de la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional. En efecto, el temperamento adoptado para el cumplimiento ordenado de las obligaciones asumidas por el sector público —que se estructuró desde una perspectiva de crisis e impotencia financiera del Estado— atendió criterios de justicia distributiva sin establecer distinciones entre los acreedores en función de su nacionalidad, domicilio o cualquier otro criterio que trasunte discriminaciones arbitrarias.

16. Que, de tal manera, la tacha de inconstitucionalidad planteada por la actora revela su pretensión de mantener incólume su derecho al cobro de los servicios en su integridad, plazos y moneda de origen, con olvido de que —como se señaló— se estaba ante una situación de crisis e impotencia financiera del Estado que, como tal, debía encontrar respuesta en una solución ordenada que con-

templara a la totalidad de los acreedores, procurando asignar a ellos un trato razonablemente equitativo, ya que en casos de insolvencia no son adecuadas decisiones que agotan su mira en un único acreedor o grupo de acreedores, a sabiendas de que a los restantes —de igual calidad y con créditos de análoga naturaleza— no podría otorgárseles —precisamente por la incapacidad de pago— el mismo tratamiento.

Desde esta perspectiva, la pretensión de la actora no sólo desconoce la práctica internacional antes referida, sino, además, la misma lógica de las relaciones económicas que se verifican en el interior de los estados en caso de insolvencia del deudor.

En efecto, en orden a lo primero, se ha dicho que el deber de cumplimiento de las obligaciones ante una circunstancia de emergencia incuestionable, tiene como límite la capacidad de pago del Estado deudor, entendida ésta del modo antes indicado, es decir, con preservación de lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, la atención de servicios esenciales, y la salvaguarda de las bases presupuestarias y monetarias indispensables para permitir un desarrollo adecuado de la economía.

Y en lo relativo a lo segundo, si bien el Estado es una persona de existencia necesaria, dicha nota no la libera de padecer restricciones financieras de toda índole, algunas de las cuales —como la que ha experimentado y experimenta nuestro país y han sufrido otros a lo largo de la historia— resultan sumamente graves y justifican la adopción de soluciones como la examinada.

17. Que, por otra parte, debe ponerse de relieve —tal como por lo demás surge de la reseña normativa a la que se hizo referencia— que los decretos cuestionados por los actores han sido ratificados mediante las leyes 25.967 (art. 64) y 25.725 (art. 62). Asimismo las suspensiones de pago han sido autorizadas por el Congreso de la Nación, órgano al que la Constitución Nacional encomienda el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación (art. 75 inc. 7°) y la fijación anual del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional (art. 75, inc. 8°).

18. Que, por último, corresponde considerar la presentación efectuada por los actores a fs. 202/203 vta. —reseñada en el considerando 7°— relativa a la oferta de canje efectuada mediante el decreto 1735/04 y a lo prescripto por la ley 26.017.

Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que la adhesión o no adhesión al procedimiento de canje ha sido establecida como una opción que puede ser libremente ejercida por los tenedores de los bonos declarados "elegibles". De ahí que si los actores han decidido no participar de dicho canje, y así lo han manifestado expresamente, no existe ningún mecanismo que compulsivamente los obligue a ingresar en él. Sobre el particular, el art. 6° de la ley —al que específicamente aluden los demandantes— prevé un mecanismo automático de canje sólo en el caso de que concurran las siguientes circunstancias: a) la existencia de bonos del Estado Nacional elegibles, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia o jurisdicción; y b) que sus titulares no hubieran adherido al canje dispuesto por ese decreto o no hubieran manifestado —en forma expresa en las respectivas actuaciones judiciales— su voluntad de no adherir al canje antes de la fecha de cierre de éste. En el sub examine no concurre ninguno de estos supuestos, ya que no consta que los bonos de los actores hayan sido depositados judicialmente y, lejos de mediar el silencio previsto por la norma, los interesados han manifestado enfáticamente su rechazo al canje ofrecido. De este modo, al no resultar aplicable en la especie el mencionado artículo, las críticas efectuadas resultan insustanciales.

19. Que, además, debe destacarse que la República Argentina no repudió su deuda pública. La situación de los titulares de bonos que, como los actores, habiendo podido participar del canje decidieron no hacerlo, no ha sido aún regulada normativamente. De tal manera, y más allá de los "factores de riesgo" señalados al efectuarse la oferta de canje respecto de los títulos "elegibles" que no participaron de ella, se desconoce a la fecha en qué situación éstos quedarán colocados, y resulta, por lo tanto, incierto el perjuicio patrimonial que, eventualmente, podría ocasionar a sus tenedores el tratamiento que se les asigne. Por lo tanto, los agravios expresados sobre el punto resultan inatendibles, en primer lugar puesto que derivarían de la propia conducta discrecional de los actores en tanto decidieron no participar del canje (conf. doctrina de Fallos 275:218, entre otros) y, en segundo lugar, por tratarse de un gravamen conjetural.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se re-

voca la sentencia apelada y se rechaza la acción de amparo (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Costas por su orden en razón de tratarse de una cuestión jurídica novedosa. — Juan C. Maqueda. — Elena I. Highton de Nolasco.

Voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti:

Considerando: Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 6° del voto de los jueces Maqueda y Highton de Nolasco.

7. Que la sentencia en recurso se sustenta en otras decisiones del tribunal a quo que habían declarado la inconstitucionalidad de normas referidas a la pesificación en general y en particular a los depósitos bancarios.

Que esa remisión y la analogía que ella supone, no puede aceptarse, en la medida en que los elementos del caso son esencialmente diferentes, por las siguientes razones: a) el objeto de la pretensión se refiere a títulos representativos de la deuda pública nacional; b) el deudor es el Estado Nacional y no los bancos, sean públicos o privados; c) los acreedores compraron bonos de diversas clases como una inversión con un riesgo sobre el cual debieron ser informados y aconsejados; d) el contrato de empréstito es sustancialmente distinto del depósito bancario.

Que esta calificación de la relación jurídica implica la aplicación de leyes y precedentes distintos a los invocados y propios de la regulación de la deuda pública nacional.

Que, en consecuencia, el control procedimental y sustantivo de constitucionalidad de las normas es específico para este caso y no puede ser basado en analogía con un supuesto de hecho diferente.

8. Que el control constitucional procedimental se refiere a la constatación de una situación de emergencia declarada por el Congreso, la persecución de un fin público y la transitoriedad de las medidas adoptadas.

Que sobre la existencia de una situación de emergencia que motivara la legislación en cuestión no ha mediado discusión relevante en la causa, y es ampliamente admitido que el referido supuesto ha existido. Igual afirmación puede efectuarse con relación a la existencia de un fin público y la transitoriedad de la medida.

Que la intervención del Congreso de la Nación ha sido amplia y en diferentes etapas vinculadas al supuesto de hecho de esta causa y que pueden resumirse de la siguiente

manera: las sucesivas leyes de presupuesto correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004 (números 25.565, 25.725 y 25.827), autorizaron al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción a reestructurar las obligaciones de la deuda del gobierno nacional, en los términos del art. 65 de la ley 24.156, a fin de adecuar sus servicios a las posibilidades de pago del Estado Nacional. Cabe recordar, a su vez, que durante el tiempo que demandase llegar a un acuerdo, el legislador había autorizado al Poder Ejecutivo —a través del mencionado Ministerio— a diferir total o parcialmente los servicios de la deuda pública a efectos de atender funciones básicas del Estado Nacional.

Sobre tales bases, el decreto 1735/04 dispuso "la reestructuración de la deuda del Estado Nacional, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional" (art. 1°), con el alcance y en los términos y condiciones establecidos en tal decreto. De tal modo, el Estado Nacional ofreció a los tenedores de los bonos —declarados elegibles en los anexos que integran dicho decreto— su canje por nuevos instrumentos representativos de deuda, junto con "Valores Negociables Vinculados al P.B.I."

A su vez, por la resolución 20/2005 del Ministerio de Economía y Producción, se aprobaron los términos del "Suplemento de Prospecto" (Anexo I) relativo a la oferta internacional, el "Procedimiento Operativo aplicable en la República Argentina" (Anexo II) y las "Condiciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la República Argentina" (Anexo III).

La propuesta unilateral efectuada por el gobierno nacional fue, en lo sustancial, única para todo el universo de tenedores de bonos de la deuda pública en default emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 para el canje de sus títulos elegibles por otros nuevos (conf. Suplemento de Prospecto del 27 de diciembre de 2004, Traducción Pública, cap. "Oferta Global", Anexo resol. 20/2005 del Ministerio de Economía y Producción).

Dicha propuesta conlleva una extensión de los plazos y, en su caso, una quita de capital nominal respecto de lo originariamente pactado y exteriorizó —cuando el país "aún está saliendo de la crisis económica más grave de su historia"— la pretensión de alcanzar una reducción de la deuda en la magnitud necesaria para propiciar "la estabilidad fiscal en el futuro y la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo", así como la equidad entre los

acreedores (confr. Suplemento de Prospecto del 27 de diciembre de 2004. Traducción Pública. cap. "Condiciones de la Oferta: Metodología; Recomendación" Anexo resol. 20/2005 del Ministerio de Economía y Producción).

Por su parte, la ley 26.017 estableció las condiciones a las que quedarían sujetos, sin perjuicio de las normas que les resulten aplicables, los bonos del Estado Nacional que, siendo elegibles para el canje establecido por el decreto 1735/04, no hubiesen sido presentados a éste. Asimismo, se dispuso que el Poder Ejecutivo no podría reabrir, en relación a estos bonos, el proceso de canje establecido por el citado decreto, y que, en el marco de las condiciones de emisión de los respectivos títulos y de las normas aplicables a las jurisdicciones correspondientes, debería dictar los actos administrativos y cumplir las gestiones necesarias para retirarlos de cotización en todas las bolsas y mercados de valores nacionales y extranjeros. De igual modo, se prohibió al Estado Nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada sobre estos títulos. Finalmente, para el supuesto de que existieran bonos depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia o jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al canje o no hubieran manifestado en forma expresa en las respectivas actuaciones judiciales su voluntad de no adherir a éste antes de la fecha de cierre, se estableció que aquéllos quedarían reemplazados de pleno derecho por los "Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos Step Up 2038", en las condiciones establecidas para la asignación, liquidación y emisión de los bonos por el decreto 1735/04. Por otra parte, debe ponerse de relieve, que los decretos cuestionados por los actores han sido ratificados mediante las leyes 25.967 (art. 64) y 25.725 (art. 62). Asimismo las suspensiones de pago han sido autorizadas por el Congreso de la Nación, órgano al que la Constitución Nacional encomienda el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación (art. 75, inc. 7°) y la fijación anual del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional (art. 75, inc. 8°).

9. Que en relación al planteo sub examen debe distinguirse claramente el análisis de la conveniencia del que se refiere a la constitucionalidad.

Que, en este sentido, esta Corte ha afirmado que "existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que

dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiera obrado el cuerpo legislativo ajeno al poder judicial" (Fallos 68:238, especialmente pág. 295) y que no le corresponde a los jueces decidir sobre la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos 318:785); ni pronunciarse sobre la oportunidad o discreción en el ejercicio de aquéllas (Fallos 224:810), ni imponer su criterio de eficacia económica o social al Congreso de la Nación (Fallos 311:1565); y asimismo que "el control de constitucionalidad no autoriza a la Corte Suprema a sustituir en su función a los otros poderes del gobierno" (Fallos 256:386 y sus citas).

10. Que el control constitucional sustantivo se concentra en el examen de la razonabilidad de la restricción impuesta por la legislación cuestionada.

Que una metodología correcta en esta materia obliga a distinguir entre la constitucionalidad de la regla general y la de su incidencia sobre las relaciones particulares.

Que la legislación cuestionada establece el cambio de valor de la moneda nacional respecto de la extranjera, expresada en una devaluación de la primera. Sobre ello han habido expresiones unánimes acerca de su constitucionalidad fundadas en el principio de la "soberanía monetaria" (Fallos 52:413, especialmente pág. 431; 149:187), el que no ha sido cuestionado a lo largo de la historia del derecho argentino. El Congreso y el Poder Ejecutivo, por delegación legislativa expresa y fundada, están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (arts. 75 inc. 11 y 76 Constitución Nacional).

Que una interpretación contraria a esta regla fundamental del funcionamiento económico, efectuada tres años después de establecida, traería consecuencias institucionales gravísimas, lo cual sería contrario al canon interpretativo que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales (Fallos 312:156). En situaciones similares los tribunales constitucionales no han dudado en respaldar las facultades del congreso en cuanto a su soberanía monetaria (Corte Suprema de los Estados Unidos, "Norman c. Baltimore & O.R. co.", del 18 de febrero de 1935).

Que siguiendo esta centenaria jurisprudencia, la ley 25.561 es, en este aspecto (art. 2 y concs.), constitucional.

Que la afirmación precedente debe ser diferenciada del juicio sobre la constitucionalidad

del impacto que aquélla produce sobre cada una de las relaciones jurídicas afectadas, siendo para ello determinante la calificación de su objeto, del sujeto pasivo obligado y la legislación aplicable.

11. Que el principio básico que regula la emisión de bonos de la deuda pública es el deber de cumplimiento de las obligaciones pactadas, que el Estado debe honrar, no sólo en beneficio de quienes contratan con él, sino en su propio interés, ya que de tal modo produce confianza en los inversores a los que recurre. El respeto de la seguridad jurídica es sustancial para la captación del ahorro público así como para el desarrollo de la Nación.

Que la calificación que cabe dar a este tipo de empréstito no es la de una mera promesa unilateral del Estado que éste puede modificar en cualquier tiempo, ya que, una vez aceptada, se transforma en una obligación jurídica causada por un contrato (Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, t. II, pág. 443, 6ª edición, Ed. La Ley, Bs. As., 1964; Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. III-B, pág. 682, 4ª edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1994).

Que la fuente primordial del contenido regulatorio es el derecho público (Fallos 319:2886 caso "Adriano C. Brunicardi v. Banco Central de la República Argentina"), aunque no caben dudas de que existe una regulación mixta con componentes iusprivatistas. Este último aspecto resulta relevante para la aplicación de principios referidos a la conducta del deudor, el límite del cumplimiento exigible, las eximentes aplicables y su calificación como un contrato en el que se asume un riesgo de inversión, que no puede ser ignorado.

Que dada esta calificación, sólo situaciones excepcionales habilitarían al emisor a alterar unilateralmente ciertas condiciones de emisión.

12. Que en el escrutinio constitucional de la conducta del Estado respecto de la deuda pública en situaciones de crisis extremas es de gran complejidad y debe efectuarse una ponderación razonable entre dos valoraciones diferentes.

Que es un principio aceptado que los estados nacionales se encuentran obligados a cumplir de buena fe con los compromisos que contraen en materia de deuda pública, el que ha sido concretado en reglas que surgen de diversos tratados internacionales.

Que también es un principio recibido que, en situaciones de extrema necesidad o crisis

institucionales gravísimas, dichas obligaciones no pueden ser cumplidas hasta el límite de suprimir servicios esenciales que afectarían derechos primarios de sus ciudadanos. Ello también ha sido plasmado en numerosos tratados internacionales, de rango constitucional, que obligan al Estado Nacional a cumplir con un standard mínimo de derechos humanos.

Que la tensión surge evidente cuando para honrar puntualmente con las obligaciones financieras, el Estado deja de cumplir con otras que asumió en materia de derechos humanos.

Que este conflicto de principios, que debe ser calificado como excepcionalísimo, ha motivado una amplia discusión en el derecho comparado.

Que numerosos países que hoy declaran orgullosos el respeto de sus obligaciones internacionales y las exigen a los demás, tuvieron que enfrentar grandes crisis en el pasado, que resolvieron de modo ponderado y prudente, asumiendo sacrificios basados en el trabajo esforzado y serio, pero con el razonable límite del respeto por la dignidad de sus ciudadanos.

13. Que para la valoración de la conducta del Estado y la razonabilidad de las medidas que adopta, debe tenerse en cuenta un sistema de normas, que incluya tanto el cumplimiento de los tratados internacionales de orden financiero como los de derechos humanos que integran el ordenamiento jurídico.

Que también se ha invocado la aplicación de principios generales del derecho para la valoración de las obligaciones de los estados en crisis económicas. En este sentido se ha recordado la tradición romanista, las elaboraciones de glosadores y posglosadores, así como los juristas cristianos del medioevo que se preocuparon por fijar límites éticos al cumplimiento de las obligaciones, todo lo cual conforma una tradición de principios comunes en la cultura jurídica latinoamericana, de base romanista (Schipani, Sandro, "Principios generales del derecho e inequidad de las obligaciones: perfiles jurídicos de la deuda internacional latinoamericana", en Derecho Económico actual. Homenaje al profesor M. A. Laquis, Buenos Aires, 1992, 815 ss; D. J. Andrés-S. Schipani (compiladores), "Debito Internazionale. Principi generali del diritto. Corte Internazionale di Giustizia. Atti del Seminario giuridico internazionale" 1992, Roma, "Un acercamiento ético a la deuda externa" de la Pontificia Comisión

Iustitia et Pax (1986); Moreira Alves, ex presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, "Principios generales del derecho y desigualdad en las obligaciones contractuales", con referencia a la deuda externa en el VI Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (Mérida, Venezuela, 1987; Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril de 1998; Declaración de Sant Agata dei Goti sobre la Usura y la Deuda Externa del 29 de setiembre de 1997). En Argentina cabe recordar la "Declaración de juristas sobre la deuda externa", promovida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y firmada por importantes publicistas de todo el país en julio de 2002, que mostraron su preocupación por el tema y por la "impotencia de un Estado paralizado por la falta de autonomía para determinar su presupuesto y condicionado por el esfuerzo para cumplir con sus acreencias externas, desvirtúa su rol esencial de garante de los derechos fundamentales en el territorio".

Que esta Corte, en el referido caso "Brunicardi" (Fallos 319:2886) afirmó la existencia de un principio de derecho de gentes "que permitiría excepcionar al Estado de responsabilidad internacional por suspensión o modificación en todo o en parte del servicio de la deuda externa en caso de que sea forzado a ello por razones de necesidad financiera impostergradable" (considerando 16). Este principio se funda, en lo sustancial, en que ningún Estado puede ser obligado al cumplimiento de acuerdos que superen su capacidad de pago ya que, como aplicación del clásico brocardico "ad impossibilia nemo tenetur", se ha señalado que "nadie puede hacer lo imposible" (confr. ap. VII del dictamen del señor Procurador General, pág. 2896).

14. Que la ponderación razonable lleva a la conclusión de que la regla general es el respeto de las condiciones pactadas, las que sólo pueden ser modificadas en situaciones de emergencia excepcional y gravísima, y ello ocurre cuando el cumplimiento puntual lleva al Estado a su propia crisis y al sacrificio de derechos fundamentales de la población que debe proteger.

Que la mencionada situación se ha dado en el caso y ha sido declarada por el Congreso de la Nación en uso de sus atribuciones, y ella fue calificada como histórica, gravísima y excepcional, todo lo cual lleva a convalidar una restricción que se presenta como razonable en el caso, con las precisiones que se hacen en los considerandos siguientes.

15. Que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo pueden haber obrado teniendo como base una interpretación amplia de los poderes de emergencia, consolidada en una extensa interpretación que se desprende de precedentes de esta Corte. Que la prudencia en el juicio obsta a revisar esos fundamentos hacia el pasado, pero es obligación examinar para el futuro la corrección de esa práctica conforme a sus efectos en términos constitucionales.

Que la legislación de emergencia debe tener un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla, y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios.

Que esta fundamentación de la regla de derecho, debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos, y restringe el funcionamiento económico.

Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo contundente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad.

Que la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de precompromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones imprudentes. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rigidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento.

Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho.

16. Que el perjuicio patrimonial que invocan los actores, debe ser valorado dentro de la relación jurídica que los une con quien les ha vendido dichos bonos como alternativa de inversión. En este aspecto, las personas que legítimamente compran títulos de deuda pública deben ser informados adecuadamente sobre los riesgos de todo tipo que estos presentan, y aconsejados sobre las decisiones a tomar en la medida en que la complejidad de esa información les dificulta hacerlo.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la acción de amparo (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Costas por su orden en razón de tratarse de una cuestión jurídica novedosa. — *E. Raúl Zaffaroni. — Ricardo L. Lorenzetti.*

Voto de la doctora Argibay:

Considerando: 1. El señor Hugo Gabriel Galli y la señora Silvia Concepción Attardi, en su condición de tenedores de bonos de la deuda emitidos por el Estado Argentino, iniciaron una acción de amparo a fin de que se les reconociera su derecho a obtener el pago de dichos títulos en las condiciones originalmente establecidas.

Su pretensión fue admitida favorablemente en primera instancia y posteriormente confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que dio origen a la interposición del presente recurso extraordinario por parte del Estado Nacional, el que resulta procedente en cuanto se encuentra en tela de juicio el alcance y la interpretación de normas de carácter federal.

2. Como es de público conocimiento, el 24 de diciembre de 2001 la República Argentina anunció formalmente su imposibilidad de atender los pagos de su deuda pública en virtud de su estado de insolvencia patrimonial.

Con el fin de restablecer las relaciones entre el Estado y sus acreedores, se dictaron una serie de normas tendientes a regular y coordinar los aspectos financieros, presupuestarios y legales destinados a reestructurar los compromisos que se encontraban pendientes de cumplimiento, así como todos aquellos que debieran ser afrontados en el futuro.

3. En tal sentido, se tuvo presente que la posibilidad de llevar a cabo la reestructuración de la deuda debía tener como límite la capacidad de pago del Estado deudor, la que debía ser entendida con los límites que impone la preservación de lo necesario para el cumplimiento de sus funciones y la atención de los servicios fundamentales, ya que ningún Estado puede ser obligado al cumplimiento de acuerdos que superen su capacidad de pago, en detrimento de sus fines esenciales.

Así, el cumplimiento de los propósitos básicos para el desarrollo de la Nación, debe actuar como límite a cualquier tipo de propuesta de acuerdo con los acreedores.

4. En función de ello, y con el fin de superar la situación de falencia, los poderes constitucionalmente investidos de atribuciones han llevado a cabo los actos correspondientes para lograr la recomposición de las relaciones con los acreedores, mediante las que se procuró contemplar armónicamente las reales posibilidades de pago y una base razonablemente igualitaria, atendiendo criterios de justicia distributiva y sin establecer distinciones en función de la nacionalidad, domicilio o cualquier otro criterio que pudiera trasuntar discriminación.

5. Por disposición del art. 62 de la ley 25.827 y el decreto 1735/04, se dispuso llevar adelante un sistema de canje de los títulos representativos de la deuda soberana, estableciéndose cuáles serían los instrumentos que resultaban elegibles para la operación, así como los nuevos que el Estado Nacional ofrecía en su reemplazo, las denominaciones técnicas, plazos, moneda de emisión, etc.

Dicha propuesta conllevó una extensión en los plazos, y en su caso, una quita de capital nominal respecto de lo originalmente pactado, con el fin de alcanzar una reducción de la deuda en la magnitud necesaria para propiciar la estabilidad fiscal en el futuro y su sustentabilidad en el largo plazo.

Asimismo, se previó la emisión —junto con los nuevos bonos— de "Valores Negociables Vinculados al PBI", como una forma de compatibilizar los intereses de los tenedores con el objetivo central de la política económica, consistente en la consolidación del crecimiento, como factor determinante de la capacidad de pagos de la República Argentina.

6. En tales condiciones, se considera que el nuevo mecanismo ideado para reestructurar la deuda en cesación de pagos se exhibe como

razonable en atención a su virtualidad para amalgamar los distintos elementos que deben meritarse en una operación de este tipo: posibilidad concreta y real del Estado de afrontar los pagos, instrumentos técnicos hábiles para dicho fin, así como criterios igualitarios en su asignación.

7. En lo que respecta a la cuestión aquí debatida, los títulos que poseen los amparistas se encuentran mencionados en los anexos del decreto 1735/04 entre los elegibles a los fines del canje, pero éstos han decidido rechazar la operatoria de reestructuración de la deuda en default, (ver escrito de fs. 202/203 vta.) quedando dichos bonos sometidos a lo previsto en el art. 4 de la ley 26.017, por lo que las consecuencias que pueda acarrear esta situación sólo les resulta imputable a ellos.

Y ello es así, por cuanto al momento de extirpar su expresa voluntad de permanecer al margen de la operatoria de canje, los actores conocían que la mencionada ley impedía al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de adhesión al mismo, así como la posibilidad de efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada sobre esos títulos.

8. Por lo tanto, la pretensión de mantener las condiciones originarias de sus títulos así como los modos y plazos en que dichos instrumentos debían ser cancelados, procura la obtención de un privilegio singular y resulta incompatible con los fines de interés general que inspiran la operatoria llevada adelante por la República Argentina a fin de restablecer los mecanismos de pago de sus obligaciones.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia y se rechaza la demanda. Costas por su orden en atención a la complejidad de las cuestiones debatidas. — *Carmen M. Argibay.*

10. BUSTOS, ALBERTO

ACCION DE AMPARO

Causa de fuerza mayor — Coeficiente de Estabilización de Referencia — Confiscación — Constitucionalidad — Daño cierto — Delegación legislativa — Depósito bancario — Derecho de propiedad — Discriminación — Dólar — Ejecución de sentencia — Emergencia económica — Entidad financiera — Hecho del príncipe — Intereses — Ley de emergencia — Medidas cautelares — Obligación en moneda extranjera — Pesificación — Recurso extraordinario — Requisitos de la acción de amparo — Tasa de interés — Títulos públicos

Hechos.

Se promovió acción de amparo tendiente a obtener la restitución de imposiciones banca-

rias alcanzadas por las restricciones financieras de emergencia, motivadas por la crisis de fines de 2001, en la moneda extranjera pactada, pre-